

國立中正大學法律學系
碩士論文

The logo of National Sun Yat-sen University is a blue circular emblem with a white stylized 'S' and 'Y' in the center, surrounded by a sunburst pattern.

論住宅租賃契約當事人權益保障—
兼評租賃住宅市場發展及管理條例

研究生：何震謙 撰

指導教授：楊宏暉 博士

中華民國 108 年 6 月

國立中正大學碩士學位論文考試審定書

法律學系

研究生 何震謙 所提之論文

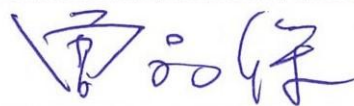
論住宅租賃契約當事人權益保障—
兼評租賃住宅市場發展及管理條例
經本委員會審查，符合碩士學位論文標準。

學位考試委員會
召集人



簽章

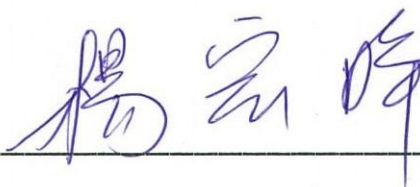
委員



楊宏暉

羅俊瑋

指導教授



簽章

中華民國 108 年 5 月 27 日

謝辭

努力了好些日子，終於來到論文完成的時刻。在論文寫作過程中，除了拽著倔強與怠惰對抗外，總是在各種學說與實務案例間徘徊斟酌，花了好一番功夫才得以下筆。論文初稿完成後，又經歷三番五次來回修改與訂正，並且度過難熬忐忑、災難連連的學位論文考試，總算成功解鎖碩士生涯的最終任務。

首先，感謝指導老師楊宏暉老師秉持寬宏的態度接納學生不成熟的見解，並且仔細、反覆的分析與論證，同時謝謝學位論文考試時兩位口試委員羅俊瑋老師及曾品傑老師撥冗協助與提供意見，以完善論文的不足之處。另外，謝謝公證人與朋友義氣相助才能順利完成論文，包含：Yu Zhen 在公證經驗的分享、Meng Han 在案例事實的說明、Yung Ching 在交易成本概念的解釋、Wei Shin 在外文寫作的建議、Yi Chih 與 Zong Xun 在資料收集的支持，以及過去任職士林法院公證處期間同仁的包容、朋友的加油打氣，甚至是身邊親戚在論文進度的頻頻打探，都是論文寫作過程中不可或缺的推進劑。最後，感謝家人一路走來默默支持，在論文進度困頓之際總是給予關心及鼓勵，才能順利完成學位，尤其是能有辛勤慈愛的媽媽作為後盾，是世界上最溫暖的幸福。

回首就讀碩士期間，經歷學業工作的南北征討、考試報告的交雜轟炸以及論文進度的壓力追趕，過程不乏徬徨與艱辛，甚至數度面臨擇一放棄的念頭，但一想到過去的努力將歸零，就決定堅毅不放棄，畢竟有些事本來很遙遠，若選擇開始和持著毅力終究能夠走到終點。在告別學校後，將會面臨更多的挑戰，希望未來永遠保有現在不畏挫折的精神，就像《Tomorrow》歌詞：「日出前的凌晨最為黑暗，在遙遠的未來也絕對不要忘記你現在的樣子！」同時鞭策自己精進學習新的事物及用心認識新的朋友，期許未來不僅能和新、舊朋友「帶著笑容一起牽手用『搖搖晃晃』的開心姿態『Beyond The Scene』一輩子」，還能夠當個有專業、有溫度的法律工作者。

何震謙 於 2019 年孟夏 謹識

中文摘要

「居住」不單是人們生活上的物質條件，更是滿足人們安全、隱私、發展人格與維護尊嚴等心理需求，重要性不言而喻。過去以來，居住爭議在台灣層出不窮，更催生社會團體以督促政府落實相關居住政策的主因。為了處理爭議，政府調整過去緩不濟急的居住政策，希冀透過健全租賃住宅市場來解決居住問題，以作為保障居住權益的一環。本文將探討2017年12月立法院通過《租賃住宅市場發展及管理條例》對居住權益保護的貢獻，包含是否解決過去住宅租賃法制殘留的問題以及新法可能延伸的其他問題。另外，透過介紹德國住宅租賃法制並與我國法制比較，期以完善我國住宅租賃法制，落實保障居住權益的目的。

整體而言，新條例雖然主要致力於保障當事人權利義務關係及建構租賃住宅服務業之管理制度兩大面向，以達到維護人民居住權，但細觀新條例內容可以窺探立法政策的態度，包含：租金去管制化、租稅優惠的賦予等，仍以降低租賃交易成本來鼓勵發展租賃住宅服務業為重。此種不同於德國法制，以自由經濟市場發展來達到維護人民居住權益的政策手段，其結果容易在「維護人民居住權益」之效果上大打折扣，實屬可惜。至於，新法在未來實務適用的態度及整體租賃住宅市場發展成效為何，由於施行不久，則尚須觀察。

關鍵詞：居住權、住宅租賃、租金、押租金、終止權

Abstract

"Housing" is not only the material requirement of people's life, but the psychological needs of safety, privacy, personality development, and dignity maintenance. Its importance is self-evident. Housing disputes have constantly occurred in Taiwan and it's the main reason that triggers social groups to urge the Government to implement housing-related policies. To deal with the disputes, the Government has adjusted the previous unsatisfying housing policy and hopes to solve the housing problem and protect housing rights and interests through a robust rental housing market. Thus, this study will discuss the contribution of "Rental Housing Market Development and Regulation Act" passed by Legislative Yuan in December 2017 to the protection of housing right, including whether it resolves the problems of the old Rental housing legal system and other issues that may occur because of the new Act. In addition, it will introduce German rental housing legal system and compare with Taiwan's, aiming to improve the Rental housing legal system and protect the housing rights and interests.

In general, the new Act engages in protecting the rights of the lease parties and establishing a management system for the rental housing service industry to protect people's housing right, however, from the details of the Act, including the deregulation of rents and the tax incentives, it can be found that the legislative policy still encourages the development of rental housing service industry by reducing the cost of rental housing transactions. It's a pity that the policy, different from the German legal system, protecting people's housing right through the development of free market economy, actually reduces its effect. As for the applicability of the Act in practice and the effect of the rental housing market development, they still need to be observed because the new Act has not been implemented for long.

Keywords : housing rights 、 Rental housing 、 Rent 、 rent deposit 、 Termination rights

目錄

第一章 緒論.....	1
第一節 研究背景與目的.....	1
第一項、 研究背景.....	1
第二項、 研究目的.....	7
第二節 研究範圍與用語.....	9
第一項、 研究範圍.....	9
第二項、 研究用語.....	9
第三節 研究方法與架構.....	9
第一項、 研究方法.....	9
第二項、 研究架構.....	10
第二章 租賃的理論基礎.....	12
第一節 租賃契約概要.....	12
第一項、 意義與特性.....	12
第二項、 性質.....	14
第三項、 種類.....	17
第二節 住宅租賃契約.....	25
第一項、 意義.....	25
第二項、 性質-要式契約與登記制度採行必要性探討.....	26
第三節 私法自治與管制理論.....	28
第一項、 私法自治.....	28
第二項、 管制理論.....	30
第三項、 小結.....	33
第三章 租賃住宅市場發展及管理條例.....	35
第一節 立法背景.....	35

第二節 適用對象.....	35
第三節 立法特色.....	36
第一項、保障當事人雙方的權益.....	36
第二項、健全租賃住宅市場發展.....	42
第三項、小結.....	46
第四章 資訊地位平等.....	47
第一節 資訊充分的締約環境.....	47
第二節 廣告內容真實.....	47
第一項、立法目的.....	47
第二項、立法政策-以填補損害為主.....	49
第三項、立法分析.....	49
第三節 資訊主動揭露.....	52
第一項、法理基礎.....	52
第二項、揭露範圍.....	52
第三項、請求權依據.....	53
第四節 小結.....	54
第五章 經濟地位平等.....	56
第一節 收入水準與居住對價相稱.....	56
第一項、管制的必要原因.....	56
第二項、管制的手段選擇.....	56
第三項、租金.....	57
第四項、押租金.....	67
第五項、小結.....	72
第二節 穩定持續的契約關係.....	74
第一項、重要意義.....	74
第二項、可能方法.....	74

第三項、合憲問題.....	75
第四項、所有權讓與不破租賃.....	76
第五項、出租人終止權之限制.....	80
第六項、租期屆滿後續租問題.....	88
第七項、小結.....	89
第六章 德國住宅租賃法制探討.....	91
第一節 住宅租賃政策的發展.....	91
第一項、政策起源.....	91
第二項、規制基礎.....	91
第二節 住宅租賃契約的規範制度.....	92
第一項、租金管制規範.....	93
第二項、租賃擔保規範.....	100
第三項、穩定持續契約關係的手段.....	102
第四項、小結.....	108
第七章 德國法制與我國法制之比較.....	109
第一節 資訊地位平等.....	109
第一項、德國民法締約上過失制度規範.....	109
第二項、重新修訂我國締約上過失.....	110
第二節 經濟地位平等.....	111
第一項、收入水準與居住對價相稱.....	111
第二項、穩定持續的契約關係.....	115
第八章 結論與建議.....	119
第一節 結論.....	119
第一項、資訊地位平等.....	119
第二項、經濟地位平等.....	119
第二節 建議.....	121

第一項、 重新修定締約上過失制度.....	121
第二項、 施行因地制宜的租金管制.....	122
第三項、 檢討押租金契約性質認定.....	122
第四項、 加強穩定持續租約的手段.....	122
參考文獻.....	125
中文文獻.....	125
德文文獻.....	130



詳目

第一章 緒論.....	1
第一節 研究背景與目的.....	1
第一項、研究背景.....	1
一、居住權益概述.....	1
(一) 形成背景.....	1
(二) 意義.....	1
(三) 性質.....	2
(四) 我國居住權益的探求.....	3
1. 憲法保障居住權益.....	3
2. 具體事例.....	3
二、我國居住政策發展.....	4
(一) 住者「有」其屋.....	5
(二) 住者「適」其屋.....	5
1. 落實社會住宅政策.....	6
2. 強化租賃住宅市場.....	6
三、居住權益在住宅租賃之實踐.....	7
第二項、研究目的.....	7
第二節 研究範圍與用語.....	9
第一項、研究範圍.....	9
第二項、研究用語.....	9
第三節 研究方法與架構.....	9
第一項、研究方法.....	9
一、文獻分析法.....	9
二、歷史研究法.....	10
三、比較研究法.....	10
第二項、研究架構.....	10
第二章 租賃的理論基礎.....	12
第一節 租賃契約概要.....	12
第一項、意義與特性.....	12
一、意義.....	12
二、特性.....	12
(一) 人格性.....	13
(二) 物權化.....	13
(三) 社會化.....	14
第二項、性質.....	14
一、債權契約.....	14

二、 有名契約.....	15
三、 不要式契約.....	15
四、 諾成契約.....	16
五、 有償契約.....	16
六、 雙務契約.....	16
七、 繼續性契約.....	16
第三項、 種類.....	17
一、 一般租賃與特種租賃.....	17
(一) 社會化之強化.....	17
1. 租金總額的限制與減免.....	17
2. 押租金額度的限制或禁止.....	18
3. 租約終止的限制.....	18
4. 優先承買權之賦予.....	19
(二) 人格性之貫徹.....	20
二、 動產租賃與不動產租賃.....	20
(一) 視為不定期租賃.....	21
(二) 所有權讓與不破租賃.....	21
(三) 法定租賃權.....	22
(四) 情事變更原則.....	22
(五) 法定留置權.....	23
(六) 終止契約之通知.....	23
(七) 特別委任.....	23
(八) 時效期間.....	23
三、 定期租賃與不定期租賃.....	24
(一) 存續期限之限制.....	24
(二) 終止權之行使.....	24
(三) 所有權讓與不破租賃.....	24
(四) 情事變更原則.....	25
第二節 住宅租賃契約.....	25
第一項、 意義.....	25
一、 租賃物客體.....	25
二、 使用收益權限供與之範圍.....	25
第二項、 性質-要式契約與登記制度採行必要性探討.....	26
一、 不要式契約性質之維持.....	26
二、 現行公示方法之維持.....	27
第三節 私法自治與管制理論.....	28
第一項、 私法自治.....	28
一、 私法自治與契約自由.....	28

(一) 私法自治.....	29
(二) 契約自由.....	29
二、 私法自治的失靈.....	30
第二項、 管制理論.....	30
一、 管制層面.....	30
(一) 資訊地位不平等.....	31
(二) 結構地位不平等.....	31
二、 合適的手段標準.....	32
(一) 適宜解決私法自治失靈.....	32
(二) 調和處理基本權利衝突.....	33
第三項、 小結.....	33
第三章 租賃住宅市場發展及管理條例.....	35
第一節 立法背景.....	35
第二節 適用對象.....	35
第三節 立法特色.....	36
第一項、 保障當事人雙方的權益.....	36
一、 出租人的修繕義務.....	36
(一) 修繕項目及範圍事前說明.....	37
(二) 修繕義務的免除範圍.....	37
二、 租賃住宅轉租制度.....	37
(一) 採取不許轉租為原則.....	38
(二) 同意轉租之要件.....	38
三、 住宅租賃契約管制.....	38
(一) 住宅租賃契約應約定及不得約定事項效力.....	38
(二) 嚴密管制契約的質疑.....	39
1. 交易市場僵化.....	39
2. 法律適用複雜化.....	40
3. 不利個案正義.....	40
四、 免費調處爭議機制.....	40
(一) 土地法第 101 條調處制度現況.....	40
(二) 民事訴訟法爭端解決機制問題.....	41
(三) 立法建議.....	42
第二項、 健全租賃住宅市場發展.....	42
一、 設計市場交易模式.....	43
(一) 代管業.....	43
(二) 包租業.....	43
二、 建立專業服務市場.....	44
(一) 引進專業證照制度.....	44

(二) 公司經營組織型態.....	44
(三) 確立服務業務內容.....	45
三、 規範服務市場責任.....	45
(一) 損害賠償.....	45
(二) 行政監督.....	46
第三項、 小結.....	46
第四章 資訊地位平等.....	47
第一節 資訊充分的締約環境.....	47
第二節 廣告內容真實.....	47
第一項、 立法目的.....	47
一、 現行規制基礎.....	47
二、 現行規制困境.....	47
第二項、 立法政策-以填補損害為主.....	49
第三項、 立法分析.....	49
一、 廣告為要約之引誘.....	50
二、 廣告成為契約內容之條件.....	50
三、 廣告不得約定僅供參考.....	51
第三節 資訊主動揭露.....	52
第一項、 法理基礎.....	52
第二項、 揭露範圍.....	52
第三項、 請求權依據.....	53
一、 故意違反揭露義務.....	53
二、 過失違反揭露義務.....	54
第四節 小結.....	54
第五章 經濟地位平等.....	56
第一節 收入水準與居住對價相稱.....	56
第一項、 管制的必要原因.....	56
第二項、 管制的手段選擇.....	56
第三項、 租金.....	57
一、 租金管制規定.....	57
(一) 適用客體.....	57
1. 房屋.....	57
2. 城市地方.....	59
(1) 定義.....	59
(2) 非城市地方應無類推適用的空間.....	59
(二) 租金最高額度.....	60
1. 土地價額.....	60
2. 建築物價額.....	60

(三) 法律效果.....	61
二、 租金去管制化.....	62
(一) 土地法第 97 條之規定適用問題.....	62
1. 租金管制計算基準失真.....	62
(1) 房地評定價值與市場價值存有落差.....	62
(2) 解決辦法.....	62
2. 租金總額管制設定過高.....	63
(二) 租賃住宅管理條例第 6 條.....	63
三、 租金調整.....	65
(一) 要件.....	65
(二) 方式.....	65
(三) 效果.....	66
1. 調整依據.....	66
2. 調整生效日.....	67
第四項、 押租金.....	67
一、 概說.....	67
(一) 意義.....	67
(二) 類型.....	68
1. 區分依據.....	68
2. 區分實益.....	69
3. 立法者預設類型.....	69
(三) 擔保範圍.....	70
二、 性質.....	70
(一) 實務見解.....	70
(二) 學說見解.....	71
三、 效力.....	72
四、 押租金的限制.....	72
第五項、 小結.....	72
一、 檢討租金管制取代去管制化.....	72
二、 押租金契約性質重新認定.....	73
第二節 穩定持續的契約關係.....	74
第一項、 重要意義.....	74
第二項、 可能方法.....	74
第三項、 合憲問題.....	75
一、 所有權讓與不破租賃.....	75
二、 出租人終止權行使限制.....	75
三、 租期屆滿後續約問題.....	75
第四項、 所有權讓與不破租賃.....	76

一、 須出租人將所有權移轉讓與第三人.....	76
(一) 承租人締約對象為受所有權人委任或得其同意出租之人.....	76
(二) 次承租人締約對象為所有權人同意轉租之第一承租人.....	77
二、 租期逾五年或未定期限者須經公證.....	77
(一) 立法理由.....	78
(二) 立法評析.....	78
1. 增加交易成本不利追求穩定的住宅租賃契約關係... ..	78
2. 公證制度無法補充占有作為公示方法之缺點.....	78
3. 防堵逃避債務及減少訟源成效有限.....	79
三、 小結.....	79
第五項、 出租人終止權之限制.....	80
一、 民法規定.....	80
二、 土地法第 100 條之規定.....	80
(一) 適用範圍.....	81
1. 僅適用於住宅租賃契約.....	81
2. 不限於不定期租賃契約類型.....	81
(二) 收回條件.....	82
1. 可歸責於承租人之事由.....	82
2. 出租人收回自住或重新建築.....	82
(1) 收回自住.....	82
(2) 重新建築.....	84
(三) 程序要件.....	84
三、 租賃住宅管理條例第 10 條.....	85
(一) 承襲一貫終止事由.....	85
(二) 踐行終止程序要件.....	86
(三) 延伸法律適用疑義.....	86
四、 小結.....	87
第六項、 租期屆滿後續租問題.....	88
一、 土地法未竟之志.....	88
二、 租賃住宅管理條例捨進而退.....	88
三、 住宅租賃政策未來方向.....	89
第七項、 小結.....	89
第六章 德國住宅租賃法制探討.....	91
第一節 住宅租賃政策的發展.....	91
第一項、 政策起源.....	91
第二項、 規制基礎.....	91
第二節 住宅租賃契約的規範制度.....	92

第一項、租金管制規範.....	93
一、德國法之租金概念.....	93
(一) 意義.....	93
(二) 區分實益.....	93
二、租金價格上限機制.....	94
三、租金漲幅的控制.....	95
(一) 意定情形.....	96
1. 分級式租金(德國民法第 557 條之 1 參照).....	96
2. 指數式租金(德國民法第 557 條之 2 第 1 項參照) ..	96
(二) 法定情形.....	97
1. 租金提高至當地通常之參考租金.....	97
(1) 實體要件.....	97
(2) 程序要件.....	97
(3) 說明理由內涵.....	98
2. 現代化措施調漲租金.....	99
(1) 實體要件.....	99
(2) 程序要件.....	99
第二項、租賃擔保規範.....	100
一、「租賃擔保」額度管制.....	100
(一) 管制目的.....	100
(二) 違反效果.....	100
二、現金擔保.....	101
三、「租賃擔保」性質.....	101
(一) 舊法時期.....	101
(二) 新法時期.....	102
第三項、穩定持續契約關係的手段.....	102
一、出租人終止權之限制.....	102
(一) 特別終止權.....	103
1. 重大事由.....	103
2. 列舉事由.....	103
3. 遲延給付租金之特殊要件.....	104
4. 程序要件.....	105
(二) 一般終止權.....	105
1. 正當利益.....	105
2. 承租人之異議.....	105
(1) 實體要件.....	105
(2) 程序要件.....	106
(3) 法律效果.....	106

二、 原則上住宅租賃為不定期租賃.....	107
第四項、 小結.....	108
一、 保護承租人利益並尊重市場規律的租金管制.....	108
二、 以保護承租人利益為中心的租賃擔保.....	108
三、 維持穩定持續契約關係的手段選擇.....	108
第七章 德國法制與我國法制之比較.....	109
第一節 資訊地位平等.....	109
第一項、 德國民法締約上過失制度規範.....	109
一、 締約上過失制度概括規範.....	109
二、 德國民法締約上過失法律效果.....	109
第二項、 重新修訂我國締約上過失.....	110
一、 締約上過失存在的功能價值.....	110
二、 我國現行法制存在的缺陷.....	110
第二節 經濟地位平等.....	111
第一項、 收入水準與居住對價相稱.....	111
一、 租金.....	111
(一) 作業費用管制成本手段不同.....	111
(二) 決定租金總額管制主體不同.....	111
(三) 租金漲幅管制與程序要求不同.....	112
(四) 租金管制的計算基準不同.....	112
二、 租賃擔保.....	112
(一) 租金擔保管制目的不同.....	112
(二) 違反租金擔保管制效果不同.....	113
(三) 租賃擔保持有方式不同.....	113
(四) 租賃住宅轉讓後有關租賃擔保的解決不同.....	113
三、 檢討我國租金及押租金之法制.....	113
(一) 租金管制部分.....	114
1. 以法律限制作業費用收取.....	114
2. 採取因地制宜的租金總額管制.....	114
3. 增設租金漲幅的管制規範.....	114
4. 管制計算基準契合市場行情.....	114
(二) 租賃擔保管制部分.....	115
1. 繼續保留我國租賃擔保持有擔保的方式及違反的效果.....	115
2. 重新認定押租金契約性質.....	115
第二項、 穩定持續的契約關係.....	115
一、 出租人終止權之限制.....	115
(一) 終止原因寬嚴不同.....	115

(二) 終止契約程序不同.....	116
二、住宅租賃關係存續期間設定不同.....	116
三、所有權讓與不破租賃.....	116
(一) 租期逾五年及不定期住宅租賃契約適用要件不同...	116
(二) 法律效果不同.....	116
四、檢視我國穩定持續住宅租賃關係的手段.....	117
(一) 出租人終止權之限制.....	117
1. 調整終止正當理由認定.....	117
2. 賦予承租人對於出租人終止權異議程序.....	117
(二) 鼓勵出租人與承租人定期續約.....	117
(三) 所有權讓與不破租賃.....	118
1. 刪除公證要件.....	118
2. 增設法律效果.....	118
第八章 結論與建議.....	119
第一節 結論.....	119
第一項、資訊地位平等.....	119
第二項、經濟地位平等.....	119
一、收入水準與居住對價相稱.....	119
(一) 租金管制問題.....	119
(二) 押租金性質認定問題.....	120
二、穩定持續的契約關係.....	121
第二節 建議.....	121
第一項、重新修定締約上過失制度.....	121
第二項、施行因地制宜的租金管制.....	122
第三項、檢討押租金契約性質認定.....	122
第四項、加強穩定持續租約的手段.....	122
參考文獻.....	125
中文文獻.....	125
一、專書.....	125
二、期刊論文.....	125
三、專書論文.....	129
四、博(碩)士論文.....	129
德文文獻.....	130
一、專書.....	130
二、期刊論文.....	130

第一章 緒論

第一節 研究背景與目的

第一項、研究背景

一、居住權益概述

(一) 形成背景

在 1948 年聯合國發表《世界人權宣言》中，指出「居住權益」是每人應該享有的基本權益，是第一部關注居住問題的人權憲章¹。然而，隨著全球人口攀升、都市化快速，致「居住」問題更加惡化且棘手，國際之間深感「居住權益」的重要性，在 1966 年簽訂《經濟社會文化權利國際公約》(以下簡稱：經社文公約)，其中第 11 條第 1 項及經濟社會文化確立委員會之第 4 號及第 7 號一般性意見，除了再次宣示「居住權益」是人民享有的基本權益外，深化「居住權益」保護內容，為「居住權益」概念確立基礎，並且賦予締約國有確實履行居住權益的義務，實為展現解決居住問題的決心²。

(二) 意義

「居住權益」目的在保障個人在社會中擁有居住之基本條件的權利，但要明

¹ 《世界人權宣言》(Universal Declaration of Human Rights)聯合國大會經第 217A 號決議，於 1948 年 12 月 10 日巴黎宣布，其第 25 條規定：「(1) Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control. (2) Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection.」取自：聯合國(UNITED NATIONS，縮寫 UN)，<http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/> (最後瀏覽日：05/03/2018)

² 《經濟社會文化權利國際公約》(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)於 1966 年開放簽署並於 1976 正式生效，其第 11 條第 1 項規定：「The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to an adequate standard of living for himself and his family, including adequate food, clothing and housing, and to the continuous improvement of living conditions. The States Parties will take appropriate steps to ensure the realization of this right, recognizing to this effect the essential importance of international co-operation based on free consent.」取自：聯合國人權事務高級專員辦事處(Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights，縮寫為 OHCHR)，<http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx> (最後瀏覽日：05/03/2018)

確描述意義是困難，主要依賴經濟社會文化確立委員會之第 4 號及第 7 號一般性意見將內涵具體化。論者從國家履行居住權益的行為，分別從積極面與消極面來界定其內涵³。從積極面觀察，強調人人不僅皆能擁有房屋使用權，並且享有之房屋須具備衛生、安全、舒適和營養等基礎設施服務，座落地點合宜、方便，以及為符合適宜居住的條件所支付的對價與收入水準相稱而言⁴。相對於此，消極面則指保障住房使用權，免遭國家或第三人非法強制驅逐⁵。所為「非合法強制驅逐」應從「合法驅逐」來界定，指國家行為具有正當理由及比例原則，同時踐行正當程序，包含：事前通知、提供協商機會、享有合理履行時間、確認有替代居住場所等⁶。基此，就整體行為特徵瞭解，所稱「居住權益」內涵，實為個人在社會中擁有適宜的住居所及免於非法強制驅逐。

(三) 性質

從「居住權益」作為基本權利的意義可以發現，其具有傳統憲法防禦及給付的功能，亦即國家不得侵犯人民之居住權益外，在維護人性尊嚴最低限度前提下，國家有給付之義務⁷。然而給付功能涉及預算施政的分配及國家資源的有限性，並非藉基本權利的解釋就可以直接向國家請求滿足權利內容，原則上仍應由立法者基於考量國家之經濟及財政狀況，依資源有效利用之原則，決定國家何時以何種方式完成此一任務⁸。並且，給付方式及額度亦應力求與受益人之基本生活需求相當，不得超過達成立法目的所需必要限度而給予明顯過度之照顧⁹。

除了傳統憲法功能外，從消極面可以更進一步發現具有國家保護義務及組織與程序保障作用，前者強調國家有義務採取一定措施，保護人民之居住權益免遭第三人侵害，後者強調國家合法強制驅逐須透過一定組織與正當程序，保障及實

³ 陳珮好，適足居住權於我國司法裁判之建構與落實，頁 47-55，國立政治大學法律學系碩士班碩士論文，2017 年 2 月。

⁴ 經濟社會文化確立委員會(1991)，第 4 號一般性意見。

⁵ 經濟社會文化確立委員會(1991)，第 4 號一般性意見。

⁶ 經濟社會文化確立委員會(1998)，第 7 號一般性意見。

⁷ 法治斌、董保城，憲法新論，元照，頁 133-134，2012 年 9 月 5 版。

⁸ 法治斌、董保城，前揭註 7，頁 134-138。

⁹ 大法官釋字 485 號解釋。

現居住權益¹⁰。

(四) 我國居住權益的探求

1. 憲法保障居住權益

憲法上「居住權益」並未明列為基本權利，在大法官釋字第 709 號解釋首次提出並引用《經社文公約》有關「適足居住環境」概念以降，仍舊未明¹¹。不過，藉此推認「居住權益」不受我國憲法保障，則稍嫌速斷。相對地，在釋字第 709 號解釋，多數大法官意見書試圖從憲法第 10 條居住遷徙自由與第 15 條生存權及財產權作為居住權益的立足點，肯認「居住權益」受我國憲法保障¹²。即使「居住權益」是否得作為獨立之權利存在，以及內涵和其他基本權利關係為何，在公法上仍具爭議¹³。但不可否認，隨著我國於 2009 年 12 月 10 日公布施行具約束力之內國法《公民與政治權利國際公約及經濟社會文化權利國際公約施行法》(以下簡稱：兩公約施行法)以及相關法規的修訂，《經社文公約》不僅得作為解釋我國憲法基本權利內涵之重要考量依據，亦為我國憲政帶入新的人權思想，強化對人民之基本權利保障，包含「居住權益」的保障觀點，逐漸落實於我國¹⁴。

2. 具體事例

對此，為能遵循憲法保障人民居住權益及實踐兩公約施行法，故我國增訂《住宅法》作為我國首部保障居住權益為核心內容的基本法。按住宅法第 1 條之規定：「為保障國民居住權益，健全住宅市場，提升居住品質，使全體國民居住於適宜之住宅且享有尊嚴之居住環境，特制定本法。」及同法第 53 條之規定：「居住為

¹⁰ 法治斌、董保城，前揭註 7，頁 141-144。

¹¹ 許宗力，2013 年憲法發展回顧，臺大法學論叢，第 43 卷第 5 期，頁 1048，2014 年 11 月。

¹² 湯德宗，大法官釋字第 709 號協同意見部分不同意見書，頁 16-17。葉百修，大法官釋字第 709 號協同意見書，頁 1-9。羅昌發，大法官釋字第 709 號部分協同意見書，頁 13-15。蘇永欽，大法官釋字第 709 號一部不同意見書，頁 7-9。陳新民，釋字第 709 號提出之部分不同意見書，頁 5-7。李大法官震山釋字第 709 號協同意見書，頁 10。

¹³ 陳冠瑋，憲法上居住權之建構與實現——以司法審查為核心，頁 89-132，國立台灣大學法律學院法律學系碩士論文，2016 年 8 月。

¹⁴ 立法院公報處(2009)，〈立法院第 7 屆第 3 會期第 6 次會議紀錄〉，《立法院公報》，第 98 卷第 14 期，頁 527。
https://lci.ly.gov.tw/LyLCEW/communique/final/pdf/98/14/LCIDC01_981401_00027.pdf (最後瀏覽日：05/03/2018)

基本人權，其內涵應參照經濟社會文化權利國際公約、公民與政治權利國際公約，及經濟社會文化權利委員會與人權事務委員會所作之相關意見與解釋。」皆能再次明確得知，我國肯認「居住權益」值得被保護並願以貫徹之決心。

綜上，我國憲政除了具有保障居住權益的人權思想，國家為履行居住權益的保障義務，依住宅法第 5 條之規定於 2015 年提出《整體住宅政策》，以建構「健全租售住宅市場」、「提供多元居住協助」及「提昇居住環境品質」為政策內涵¹⁵。其中，有關健全住宅市場之政策，政府機關不單僅注意於買賣住宅市場供給及需求等市場資訊，亦同時須研擬住宅租賃發展政策，提升租屋市場健全發展(住宅法第 52 條參照)，改變我國以往居住政策的發展方向。

二、我國居住政策發展

「居住」是人們的基本需求，每個人都需有棲身之所。居住不單是生活上的物質條件，更是滿足人們安全、隱私、發展人格與維護尊嚴等心理需求，重要性不言而喻。過去以來，居住爭議在台灣層出不窮，不論是投機炒作房地產所致的高房價，或伴隨而來的社會住宅不足、不透明的租屋資訊等議題，也頻頻成為大眾的關注焦點¹⁶。台灣薪資的漲幅停滯造成收入水準與支付居住相關的對價不相稱，更使居住權益雪上加霜¹⁷。此皆是政府與人民所共同面臨的切身問題，亦是催生社會團體以督促政府落實相關居住政策和解決問題的主因¹⁸。

¹⁵ 整體住宅政策(2015)，行政院 104 年 9 月 15 日院臺建字第 1040049577 號函核定。取自：內政部營建署，[https://www.cpami.gov.tw/%E6%9C%80%E6%96%B0%E6%B6%88%E6%81%AF/%E6%A5%AD%E5%8B%99%E6%96%B0%E8%A8%8A/41-%E5%9C%8B%E6%B0%91%E4%BD%8F%E5%A%E85%E7%B5%84/19281-%E6%95%B4%E9%AB%94%E4%BD%8F%E5%AE%85%E6%94%BF%E7%AD%96\(104-9-15%E6%A0%B8%E5%AE%9A%E7%89%88\).html](https://www.cpami.gov.tw/%E6%9C%80%E6%96%B0%E6%B6%88%E6%81%AF/%E6%A5%AD%E5%8B%99%E6%96%B0%E8%A8%8A/41-%E5%9C%8B%E6%B0%91%E4%BD%8F%E5%A%E85%E7%B5%84/19281-%E6%95%B4%E9%AB%94%E4%BD%8F%E5%AE%85%E6%94%BF%E7%AD%96(104-9-15%E6%A0%B8%E5%AE%9A%E7%89%88).html) (最後瀏覽日：05/03/2018)

¹⁶ 朱慶倫，社會住宅新作為，國土及公共治理季刊，第 5 卷第 3 期，頁 122，2017 年 9 月。李永然，我國如何落實「居住權」的保障？—從台灣實施《租賃住宅市場發展及管理條例》談起，人權會訊，第 131 期，頁 9-11，2019 年 1 月。

¹⁷ 江明芸，社會住宅，從民間倡議到政府爆衝，新社會政策，第 14 期，頁 8，2011 年 2 月。胡勝正，從房價所得比看臺灣的社會不公，臺灣經濟預測與政策，第 45 卷第 2 期，頁 39-40，2015 年 3 月。

¹⁸ 1989 年無殼蝸牛組織發起「萬人夜宿忠孝東路」後，關注居住問題的社會團體，如：崔媽媽基金會、社會住宅推動聯盟、巢運等團體隨之成立。取自：崔媽媽基金會，<https://www.tmm.org.tw/contents/text?id=43> (最後瀏覽日：05/03/2018)

(一) 住者「有」其屋

為了處理爭議，回顧我國早期居住政策多以「住者有其屋」為發展理念，主要分為國宅生產與住宅補貼政策。1975 年頒布《國民住宅條例》政府自行興建國宅並多以出售取代出租方式供與收入較低之民眾；1982 年修訂《國民住宅條例》，國家得透過貸款讓人民自建並獎勵投資興建住宅；1989 年公布《輔助人民貸款自購住宅辦法》後，貸款利息補貼及租稅優惠，成為主要的居住政策¹⁹。然而，以「住者有其屋」理念所延伸之政策，不論是國宅生產或住宅補貼政策，解決弱勢家庭住宅問題有限，包含國宅設計不佳與區位不良等不符合實際需求、市中心之國宅售價與市價相差不大以及住宅補貼未必能夠減輕購屋的高額門檻等等，對於社經弱勢族群無太大實益²⁰。

(二) 住者「適」其屋

自 2005 年政府核定《整體住宅政策》後，2011 年通過《住宅法》並逐漸取代《國民住宅條例》，從過去「住者有其屋」理念，開始轉為「住者適其屋」概念²¹。其乃指全體國民居住於適宜之住宅且享有尊嚴之居住環境之謂(住宅法第 1 條參照)。質言之，保障國民居住在適當的環境，並透過健全的住宅市場，使不同所得水準之人都能順利買到或租到合適的住宅。因此，居住政策不再強調「房屋自有」概念，取而代之的是協助大眾皆有適宜的居住處所得以「使用」。實然，早在 1994 年時即有學者提出此概念，遲以至今方才實現²²。

¹⁹ 陳怡伶、黎德星，新自由主義化、國家與住宅市場－臺灣國宅政策的演變，地理學報，第 59 期，頁 113-123，2010 年 8 月。

²⁰ 張雅惠，國民住宅轉型社會住宅之課題分析，土地問題研究季刊，第 8 卷第 2 期，頁 81-82，2009 年 6 月。黃麗玲，社會住宅政策與社會轉型的新視野，新社會住宅政策，第 14 期，頁 14，2011 年 2 月。

²¹ 整體住宅政策(2005)，行政院 94 年 5 月 24 日院臺建字第 0940021921 號函核定。取自：內政部營建署，[https://www.cpami.gov.tw/%E6%9C%80%E6%96%B0%E6%B6%88%E6%81%AF/%E6%A5%AD%E5%8B%99%E6%96%B0%E8%A8%8A/10032-%E6%95%B4%E9%AB%94%E4%BD%8F%E5%AE%85%E6%94%BF%E7%AD%96\(94-5-24%E6%A0%B8%E5%AE%9A%E7%89%88\).html](https://www.cpami.gov.tw/%E6%9C%80%E6%96%B0%E6%B6%88%E6%81%AF/%E6%A5%AD%E5%8B%99%E6%96%B0%E8%A8%8A/10032-%E6%95%B4%E9%AB%94%E4%BD%8F%E5%AE%85%E6%94%BF%E7%AD%96(94-5-24%E6%A0%B8%E5%AE%9A%E7%89%88).html) (最後瀏覽日：05/03/2018)

²² 張金鶚，住者適其屋-我國住宅政策與問題之探討，律師通訊，第 181 期，頁 12-18，1994 年 10 月。

1.落實社會住宅政策

其中，呼籲政府興建社會住宅的聲音，與此同時應運而生²³。所謂社會住宅是指由政府興辦或獎勵民間興辦，專供「出租之用」之住宅及其必要附屬設施，與國民住宅多以出售不同(住宅法第3條第2款參照)。亦即，採取只租不賣的模式，又稱「社會出租住宅」(Social Rented Housing)²⁴。不過，目前社會住宅仍存有問題，從客觀層面而言，包含：政府資源有限、供給數量不足等等，主觀層面則含有避情節及國宅不良印象的殘存，造成政策推行時程過長，對於人民居住權益的保護有限²⁵。

2.強化租賃住宅市場

面對緩不濟急的居住政策，政府希冀透過健全租賃住宅市場來解決居住問題，並鼓勵閒置住宅加入，以作為保障居住權益的一環。在2015年最新的《整體住宅政策》及2017年修正全文之住宅法第五章住宅市場可以得知，執行措施除了對於購屋需求之弱勢家庭及青年續行住宅補貼外，對於無力購屋者以社會住宅模式取代國民住宅，同時注意到建立公平的租賃住宅市場以保障國民居住品質及權益²⁶。

過去政府未能正視租賃住宅市場，造成缺乏完善的市場制度，阻卻欲透過租賃住宅市場尋覓棲身處所者，反而使潛在承租戶被迫承擔超過收入水準的購屋成本，以尋求安全、穩定的居住空間²⁷。另外，法律規範落後不符合現實需求，導致對於一般承租戶保障不足。因此，2017年12月立法院通過《租賃住宅市場發展及管理條例》(以下簡稱：租賃住宅管理條例)期以保障住宅租賃雙方權益及健全租賃

²³ 朱慶倫，前揭註16，頁123-129，2017年9月。

²⁴ 江穎慧，社會住宅迷思，新社會政策，第15期，頁30，2011年4月。

²⁵ 王增勇，以住宅「社會化」對抗貧窮「污名化」，台灣社會研究季刊，第81期，頁491-499，2011年3月。李子瑋、李長晏，社會住宅政策問題建構與對策提出，中國地方自治，第66卷第6期，頁36-38，2013年6月。江穎慧，前揭註24，頁30-31，2011年4月。

²⁶ 整體住宅政策(2015)，前揭註15。

²⁷ 華昌宜、賴碧瑩，我國租賃住宅市場之發展與推動，住宅學報，第10卷第1期，頁71-72，2001年2月。

住宅市場發展，以完善我國居住政策，故以此作為本文研究的動機²⁸。

三、居住權益在住宅租賃之實踐

從居住權益積極面之描述可以發現居住權益之內涵要件，除了強調每人享有居住權之概念外，主要有三：為符合適宜居住的條件所支付的對價與收入水準相稱、住宅區位與生活機能距離方便適宜以及具備基礎設施的住宅品質。由此觀之，國家除了有適時且必要使承租人「住得起」外，由於承租人居住地點通常與承租人之就業及就學等其他因素具有密切關聯，須建構承租人「穩定持續的契約關係」，避免每次租期屆滿皆須另尋房屋或受出租人任意終止租約，並且在此基礎上協助承租人追求「適宜的生活住宅品質」。因此，居住政策既選擇以住宅租賃之私法契約作為保障居住權益的一環，則在建構住宅租賃之私法契約內容方向，包含：租金、押租金、出租人終止權限制等須扣緊上述內涵，方為落實國家保障居住權益之義務。而由於「收入水準與居住對價相稱」及「穩定持續的契約關係」是重要的居住權益內涵，更是追求「適宜的生活住宅品質」之前提，故本文將以「收入水準與居住對價相稱」及「穩定持續的契約關係」概念作為研究重心。

第二項、研究目的

《租賃住宅管理條例》乃作為保障居住權益的一環，從租賃住宅管理條例第1條立法目的之規定：「為維護人民居住權，健全租賃住宅市場，保障租賃當事人權益，發展租賃住宅服務業，特制定本條例。」即可得知，該條例之立法政策是能否夠達到健全租賃住宅市場及保障住宅租賃雙方權益以維護人民居住權益是本文研究的目的。整體觀察《租賃住宅管理條例》倘傾向以健全租賃住宅市場為目的，鼓勵空屋加入租賃住宅市場恐怕損及人民居住權益。相反，若以維護人民居住權益為重，則可能造成租賃住宅短缺。對此，有待詳實討論。

²⁸ 立法院公報處(2017)，〈立法院第9屆第4會期第10次會議紀錄〉，《立法院公報》，第106卷第108期，頁98-101。
https://lci.ly.gov.tw/LyLCEW/communique1/final/pdf/106/108/LCIDC01_10610801_00007.pdf（最後瀏覽日：05/06/2018）

過去，對於住宅租賃契約多以《民法》、《土地法》作為依據。惟民法債編各論第五節租賃為一般原則性之規定，並不區分標的屬性、使用方法，對於住宅租賃契約之承租人保護有限。另外，土地法第三編第三章房屋及基地租用之規定，雖然加強承租人之保護，但是並未區分房屋使用目的而一律適用，對於商業用之房屋租賃是有過度保護之嫌不無疑問。在《租賃住宅管理條例》中是否注意過去法律制度殘留的問題，並加以完善改進，亦是本文值得觀察的重點。對此，初步提出以下問題：

(1)租賃住宅管理條例第13條之規定有關出租人違反租賃住宅廣告內容真實義務的法律責任為何，尤其廣告內容何時構成契約一部，甚而發生民事責任有必要進一步說明。

(2)租賃住宅管理條例第6條之規定排除適用土地法第97條之規定租金限制條款是否侵蝕承租人之居住權益，以及租賃住宅管理條例第6條之規定排除適用的立法理由是否妥適，容有討論餘地。另外，土地法第97條之規定是否凡房屋租賃皆得適用，倘適用範圍過度擴張，恐過於偏袒承租人，實非無疑。

(3)租賃住宅管理條例第7條之規定有關押租金之性質，學說爭論不休，實務見解多以押租金契約，即獨立於租賃契約而存在闡釋，此項見解是否合宜，值得討論。對押租金契約以要物契約的性質解釋，倘遇有房屋轉讓之情勢，由誰承擔對出租人請求返還押租金風險較為合理，亦值得探究。

(4)租賃住宅管理條例第10條有關出租人終止權之行使規定，是否注意過去土地法第100條之規定適用範圍爭議，以及兩者立法模式之差異，是否影響承租人居住權益，值得留意。另外，新法規範是否設有條件鼓勵出租人與承租人續約，給予承租人安穩的居住保障，同時補償出租人房屋財產權長久限制所造成的損失，亦有討論的必要。

最後，遍查我國文獻針對住宅租賃的發展多以討論美國、日本及中國大陸法制為主，少有針對德國法有關住宅租賃政策為完整介紹，所謂「以銅為鏡，可以正衣冠。以古為鏡，可以知興替。以人為鏡，可以明得失。」欲透過此次機會整

理德國法文獻，比較我國法之差異，以求我國法上之進步。故本文將試圖著眼出租人財產權之保障及承租人之居住權益，探討住宅租賃契約當事人間權利義務衡平。並將透過德國法文獻檢視我國法，尋找該法未完盡之處，以供研究及實務運作之參考，並希冀於住宅租賃法律關係上之闡釋能有所助益。

第二節 研究範圍與用語

第一項、研究範圍

誠如上述，本文以討論住宅租賃法律關係為主要範圍。除了針對《民法》、《土地法》及各法施行細則為研究對象，尚包含《租賃住宅管理條例》及其施行細則。同時，在住宅租賃實務，租賃契約之角色，亦不容忽視，故針對內政部公布的《住宅租賃契約應約定及不得約定事項》為歸納、分析，檢視契約內容有否合宜。另外，對於實務發生之諸多爭議問題，透過判例、判決與學說之相關見解互相比較，並參酌德國法有關文獻，以釐清法律問題。

第二項、研究用語

為了避免「住宅租賃」及「租賃住宅」用詞混淆，在研究探討前有必要界定釐清。鑑於現行法制與一般習慣用法，如：動產租賃或不動產租賃等租賃稱法，前者主要指本文論述法律關係「以一方將建築物租與他方居住使用，他方支付租金之租賃關係」稱為「住宅租賃契約」或「住宅租賃關係」等(租賃住宅管理條例第3條的2款參照)。後者，則指出租供居住使用之建築物，強調租賃物本身(租賃住宅管理條例第3條的1款參照)。兩者在法律意義有別，不可不辨。

第三節 研究方法與架構

第一項、研究方法

為能達到研究目的，以釐清住宅租賃法律關係，本文將以下列三種主要方式，作為研究方法：

一、文獻分析法

文獻分析法是指以調查、整理文獻方式來獲得資料，從而全面地、正確地了解掌握所要研究問題的一種方法。透過文獻分析法，能夠幫助瞭解問題的爭議所在。有關住宅租賃契約的書籍文獻資料豐富，不乏有學者針對特定議題有自身的觀點與想法。因此本文透過學者著作、教科書及文獻討論住宅租賃契約的體系架構、法理基礎。同時，將現時實務判例、判決見解，進行彙整、分析，充實本文研究，以得出研究結果。

二、歷史研究法

歷史研究法是透過研究過去發生的事件，以瞭解整體事件或制度的來龍去脈，即是鑑古知今。立法者決定採取何種的立法模式，往往受當時國家經濟、社會發展等背景因素影響，故瞭解我國有關住宅租賃的制度發展過程以及新制度形成的因素，歷史研究法是不可忽略的方法，透過歷史背景歸納、檢證窺探立法政策與所欲實踐之目的。

三、比較研究法

比較研究法是著重於跨國家、跨社會或跨文化之間的異同比較，是有助於理論的建立以及發現問題。不同國家法律制度的發展、規範模式，各有特色，得相互比較作為參考。因此，本文擬就我國現行住宅租賃制度與德國的法律制度進行比較。由於我國民法與德國民法關係密切，透過瞭解德國住宅租賃制度，對於此次住宅租賃法律關係研究將有所助益，並期能借鏡我國，提供立法政策不同的方向思考。

第二項、研究架構

本文將研究主題分為八章：第一章緒論、第二章租賃的理論基礎、第三章租賃住宅市場發展及管理條例、第四章資訊地位平等、第五章經濟地位平等、第六章德國住宅租賃法制探討、第七章德國法制與我國法制之比較及第八章結論與建議，合先序明。各章節之內容簡述如下：

第一章 緒論，揭示本文研究的主題、背景、目的、範圍及方法，使讀者能夠

快速掌握本文研究的重心。

第二章 租賃的理論基礎，闡述租賃契約的定義、性質及種類。透過理論基礎的探討，瞭解住宅租賃契約意涵，並且突顯與其他租賃契約的不同。另外，國家以透過出租人之租賃住宅，作為提供居住權益保障之一環，存有國家公權力的干涉，由於住宅租賃契約之屬於私法規範之範圍，故當自有必要檢視政府介入私法自治的正當性基礎和管制效率。

第三章 租賃住宅市場發展及管理條例，觀察新條例之立法特色，並以主要兩大面向：保障當事人雙方權益及健全租賃住宅市場發展分別探討現今住宅租賃的政策手段。

第四章 資訊地位平等，從出租人與承租人之交易地位呈現的狀態出發，依地位不平等之原因，分作二節主題：資訊地位平等及經濟地位平等，開展當事人權利義務關係，本章先行探究廣告內容真實義務之目的、要件、法律解釋適用問題，再探尋資訊主動揭露的法理依據。

第五章 經濟地位平等，接續開展當事人權利義務關係，以經濟地位平等為內容，分別探討政策手段是否能夠達到居住權益保障的重要內涵，包含：收入水準與居住對價相稱及穩定持續的契約關係，並且討論各該手段之要件、法律解釋適用的問題。

第六章 德國住宅租賃法制探討，認識德國法上居住政策的發展與施政措施，了解德國透過住宅租賃契約保障人民居住權益實踐的方法。

第七章 德國法制與我國法制之比較，透過上述德國法制之介紹，與我國政策及法律制度的比較，作為我國法之參考，以求我國法之進步。

第八章 結論與建議，扼要回顧本文各章研究的重要論旨，並呼應本文研究目的初步觀察所提出的問題，並作成結論與提出建議，期於住宅租賃法律關係上之闡釋能有所助益。

第二章 租賃的理論基礎

第一節 租賃契約概要

第一項、意義與特性

一、意義

稱租賃契約，民法第 421 條第 1 項之規定：「謂當事人約定，一方以物租與他方使用收益，他方支付租金之契約而言」觀之，以物租與他方使用收益者，稱出租人，支付租金之對價者，則稱承租人。當事人是一人或多人、自然人或法人及本國人或外國人，則非所問。租賃物是動產或不動產，甚至是權利均可(民法第 421 條、第 422 條及第 463-1 參照)。從該條文義固能釐清租賃之意義，不過以「租與」解釋，有落入循環論證之謬誤，法條所稱之「租與」，實應為「使用收益權限的供與」，亦即出租人將租賃物的使用收益供與承租人，由承租人依租賃物的性質與通常用法加以使用收益²⁹。故所謂租賃契約，指當事人約定，一方以物供與他方使用收益，他方支付租金之契約而言。

同以「使用收益權限供與」作為必要之點之使用借貸契約(民法第 153 條第 2 項參照)。其謂當事人約定，一方以物交付他方，他方無償於使用後返還其物之契約(民法第 464 條參照)。兩者類型特徵極為相似，但其根本差異在於以「交付」作為契約成立生效要件及「支付對價」之有無，租賃契約以雙方意思表示和致即可成立，並須支付租金作為對價，性質屬於諾成契約及有償契約，借貸契約則以交付借用物為成立生效要件，且無以支付對價之必要，性質為要物契約及無償契約³⁰。因此，兩者雖同為「用益權供與」之契約，但兩者性質有所差異，而發展出不同的權利義務關係。

二、特性

²⁹ 吳秀明，租賃，載：黃立（編），民法債編各論（上），元照，頁 275，2004 年 10 月。

³⁰ 李淑明，債法各論，元照，頁 235，2013 年 1 月 6 版。

租賃契約，除與借貸契約不同外，相較買賣、互易與贈與等以移轉權利為內容之債權契約更有不同。因此，其建構的租賃契約內容與效力異於其他債權契約，表現具有強烈的獨特內涵。學理上，整體歸納其特色有三：人格性、物權化及社會化，前者側重出租人利益保護，後兩者則是承租人利益³¹。

(一) 人格性

出租人為履行契約內容，須交付租賃物供與承租人使用收益，致有相當時間處於間接占有的狀態，無法親自使用、收益甚至管理，故對於租賃物狀態的維持，將繫餘承租人之人格良窳有關，故「人格」因素為租賃契約成立之因素³²。因此，所謂人格性，強調在租賃契約之「承租人」主體，不得擅自更換。

在處理轉租與租賃權轉讓的議題，從民法第 443 條第 1 項本文之規定：「承租人非經出租人承諾，不得將租賃物轉租於他人。」及最高法院 37 年上字第 6886 號判例：「租賃關係之成立與存續，係基於當事人間之信任，故租賃權通常為不得讓與之債權，如房屋之承租人未得出租人之同意，擅將租賃權讓與第三人時，其情形有甚於全部轉租，出租人自得終止租約。」分別體現租賃契約存有人格性之內涵，其中「係基於當事人間之信任」如斯其旨。

(二) 物權化

租賃契約為債權行為，所延伸出之廣義租賃權，含「租賃物交付請求權」及「租賃物用益權」，性質與一般債權無異³³。惟「租賃物用益權」，即一般狹義租賃權所指稱之概念，具有物權性質的色彩，蓋為占有租賃物而使用收益，確發生一定支配權利之事實，此情乃是物權的典型特徵³⁴。

再者，觀察民法第 425 條之規定：「出租人於租賃物交付後，承租人占有中，縱使將其所有權讓與第三人，其租賃契約，對於受讓人仍繼續存在。」及民法第

³¹ 邱聰智，新訂債法各論（上），頁 314-316，自版，2008 年 8 月。

³² 邱聰智，前揭註 31，頁 314。

³³ 邱聰智，前揭註 31，頁 338-339。

³⁴ 吳啟賓，租賃法論，頁 13-17，新學林，2018 年 3 月 2 版。

426 條之規定：「出租人就租賃物設定物權，致妨礙承租人之使用收益者，準用第四百二十五條之規定。」捨「所有權讓與破租賃」，採行「所有權讓與不破租賃」之立法政策，強化租賃權具有對抗效力，皆彰顯租賃權具有其他債權所無之物權特性。故所謂物權化乃指租賃契約之租賃權本質為債權，卻具有支配及對抗效力之物權特徵而言。

(三) 社會化

基於私法自治及契約自由原則，當事人權利義務關係原則上任由當事人約定，租賃契約亦不例外。但考量部分租賃現實交易上，出租人多為經濟強者，為保護弱勢承租人，民法設有多種法律規定，平衡出租人及承租人權益，以避免契約自由原則之濫用³⁵。換言之，社會化是指藉著強制規定以保障承租人，達到契約實質平等之謂。

此情，在民事法規中並不陌生，如：消費者保護法(以下簡稱：消保法)、勞動基準法(以下簡稱：勞基法)等，皆具社會化之精神。然而，在民法債編中體現此精神，除民法第 247 條之 1 有關定型化契約之規定外，僅有租賃一節直接設有相關規定，如：民法第 457 條之 1、第 458 條及第 459 條之規定等，使租賃的社會化特性更為濃厚。一般而言，租賃的社會化之內涵通常存在於特種租賃，此部分於下文詳述(本節第三項、一、一般租賃與特種租賃)。

第二項、性質

從租賃契約之意義，可以得知租賃契約之性質，具有以下七種：

一、債權契約

債權契約(又稱負擔契約)指當事人意思表示合致，約定以發生私法上一定債之關係為目的之契約，不同於以發生物權或其他權利之變動為目的之(準)物權契約(又稱處分契約)³⁶。租賃契約乃約定出租人以租賃物供與承租人使用收益為目的，

³⁵ 邱聰智，前揭註 31，頁 315-316。

³⁶ 王澤鑑，債法原理：基本理論債之發生，頁 114，自版，2012 年 12 月增訂 3 版。

僅容許承租人為租賃物使用收益，既非以物權或其他權利之變動成立契約，自屬債權契約³⁷。基此，其僅產生負擔行為之效果，並不以所有權或處分權為必要³⁸。

二、有名契約

基於債權契約自由原則，民法雖然不採類型強制，但對日常生活常見之契約，為了保護當事人利益及補充當事人約定之不備設有相關規定並賦予一定名稱，稱之為有名契約或典型契約；反之，民法無規定之事項內容則為無名契約或非典型契約³⁹。租賃契約規定於民法第 421 條之規定以下，就形式而言為有名契約，甚為明顯⁴⁰。

三、不要式契約

基於契約自由，契約締約方式以不要式為原則，並循是否踐行一定的方式為區別基準，分為要式契約與不要式契約⁴¹。租賃契約之成立，不以履行一定方式為必要，為不要式契約⁴²。最高法院 37 年台上字第 6762 號判例：「租賃契約在法律上並無必須訂立字據之規定，自不容上訴人以未經訂立字據，主張未與被上訴人發生租賃關係，不負給付租穀之義務。」揭示同旨。

至於最高法院 40 年台上字第 304 號判例曾謂：「租賃契約之成立除不動產之租賃契約，其期限逾一年者，應以字據為之外，並無一定之式。苟合於民法第四百二十一條所謂當事人約定一方以物租與他方使用收益，他方支付租金之情形，即令未經訂立書面，仍不得謂當事人間之關係尚未成立。」其中有關「不動產之租賃契約，其期限逾一年者，應以字據為之」乃涉及租賃期限為定期或不定期之認定，與契約成立與否無干。參照民法第 422 條之規定：「不動產之租賃契約，其

³⁷ 吳秀明，前揭註 29，頁 285。林誠二，債編各論新解—體系化解說（上），頁 298-299，瑞興，2007 年 3 月 2 版。邱聰智，前揭註 31，頁 311-315。

³⁸ 最高法院 33 年上字第 84 號判例：「租賃，就出租人無所有權之物，亦得成立。」其他三則判例：最高法院 48 年台上字第 1258 號、50 年台上字第 284 號及 64 年台上字第 424 號判例揭示同旨。

³⁹ 王澤鑑，前揭註 36，頁 118-127。

⁴⁰ 林誠二，前揭註 37，頁 298。

⁴¹ 王澤鑑，前揭註 36，頁 127-128。

⁴² 吳秀明，前揭註 29，頁 285-286。林誠二，前揭註 37，頁 299-304。

期限逾一年者，應以字據訂立之，未以字據訂立者，視為不定期限之租賃。」既
可得知。故租賃契約，除法律另有規定外，原則上為不要式契約。

四、諾成契約

契約之成立生效，除意思表示合致外，是否尚須其他要件之履行，分為諾成
契約及要物契約，前者意思表示合致即謂成立生效，後者尚須其他要件之踐行，
方可成立生效⁴³。租賃契約不以交付租賃物為必要，雙方意思表示合致，即告成立
⁴⁴。參照最高法院 19 年上字第 343 號判例：「使用租賃為諾成契約，一造約明以某
物租與相對人使用，其相對人約明支付租金，即生效力。」及最高法院 33 年台上
字第 637 號判例：「使用租賃為諾成契約，當事人約定一方以物租與他方使用，他
方支付租金，即生效力，不以押金之交付為成立要件。」採相同意旨。

五、有償契約

契約以當事人是否因給付而取得對價分為有償契約及無償契約⁴⁵。租賃契約以
支付租金作為必要，性質屬有償契約⁴⁶。因此，除法律另有規定或租賃契約性質所
不許者，自得準用買賣契約之規定(民法第 347 條參照)。

六、雙務契約

契約依作用可分為片務契約及雙務契約，前者指一方當事人負擔給付義務的
契約，後者為雙方基於給付與對待給付關係，互負給付義務的契約⁴⁷。租賃契約既
互負義務，故屬雙務契約，並有危險負擔(民法第 266 至 267 條參照)、同時履行抗
辯(民法第 264 至 265 條參照)之適用⁴⁸。

七、繼續性契約

繼續性契約，指契約內容之履行，非一次行為即可完成，而是主觀上有繼續

⁴³ 王澤鑑，前揭註 36，頁 136。

⁴⁴ 吳秀明，前揭註 29，頁 286。林誠二，前揭註 37，頁 305。

⁴⁵ 王澤鑑，前揭註 36，頁 153。

⁴⁶ 吳秀明，前揭註 29，頁 285。林誠二，前揭註 37，頁 299。邱聰智，前揭註 31，頁 311。

⁴⁷ 王澤鑑，前揭註 36，頁 160-163。

⁴⁸ 吳秀明，前揭註 29，頁 286。林誠二，前揭註 37，頁 299。邱聰智，前揭註 31，頁 311。

實現，客觀上契約內容繫於履行時間的長度，不同於契約內容一次行為即可完成之「一時的契約」⁴⁹。租賃契約履行涉及時間的長度，並非一次性交付租賃物及一次交付租金，租賃關係即為消滅，故屬繼續性契約⁵⁰。

第三項、種類

租賃契約依特徵型態的不同，有不同的分類方式，諸如：依租賃物是否有民事特別法適用區分一般租賃與特種租賃、依租賃物客體區分為動產租賃與不動產租賃、依契約存續期限區分為定期租賃與不定期租賃、依租賃物的型態區分為有體物租賃與權利租賃、依租賃目的區分為營業租賃與非營業租賃或依租賃是否存有融資性區分固有租賃與融資租賃等等⁵¹。其中，前三者的分類型態在租賃契約權利義務關係，具有重大的區分實益，適用上應注意之。

一、一般租賃與特種租賃

一般租賃與特種租賃與動產租賃與不動產租賃之區分有密切關聯。一般而言，對於不動產租賃為了保護承租人之利益在適用法律上常有特別規定，故而形成特種租賃。所謂不動產租賃含有住宅租賃及基地租賃(如：土地法第三編土地使用)與耕地租賃(如：耕地三七五減租條例)等等。特種租賃不同於一般租賃更致力於社會化之強化及人格性之貫徹兩方面，前者主要包含：租金總額的限制與減免、押租金額度的限制或禁止、租約終止的限制及承租人優先承買權之賦予⁵²。後者，則源自於特種租賃著眼於承租人之利益，故出租人與承租人之信賴則更為要求，以平衡出租人之利益⁵³。

(一) 社會化之強化

1. 租金總額的限制與減免

住宅租賃與基地租賃，依土地法第 94 條、第 97 條及第 105 條之規定，受有

⁴⁹ 王澤鑑，前揭註 36，頁 144-152。

⁵⁰ 吳秀明，前揭註 29，頁 286-287。林誠二，前揭註 37，頁 305。邱聰智，前揭註 31，頁 311。

⁵¹ 林誠二，前揭註 37，頁 305-315。

⁵² 邱聰智，前揭註 31，頁 458-484。

⁵³ 邱聰智，前揭註 31，頁 455-458。

租金總額的限制，超過規定者，該管直轄市或縣（市）政府得依所定標準強制減定之。不過，現行針對住宅租賃部分，依租賃住宅管理條例第 6 條，排除租金額度限制之適用，此項立法是否妥適，則待後文討論(第五章第一節第三項、租金)。

耕地租賃，依土地法第 110 條第 1 項及耕地三七五減租條例第 2 條第 1 項之規定，租金受有不同額度之限制。在民法第 457 條之 1、土地法第 112 條第 1 項及耕地三七五減租條例第 14 條之規定，皆明文出租人不得預收地租。此外，遇有不可抗力因素致農作物歉收，得請求減少或免除租金，諸如：民法第 457 條第 1 項之規定賦予承租人對出租人之租金減免形成權、土地法第 123 條之規定授與政府裁量租金減免決定權及耕地三七五減租條例第 11 條之規定賦予承租人請求耕地租佃委員會議定租金減免或免除辦法。後者耕地三七五減租條例第 11 條之規定相較土地法第 123 條之規定明確具體，且《耕地三七五減租條例》為《土地法》之特別法，自應先適用之⁵⁴。

2.押租金額度的限制或禁止

住宅租賃與基地租賃，對於擔保之金額設有限制，前者不得超過二個月房屋租金之總額，土地法第 99 條及租賃住宅管理條例第 6 條定有明文；後者，不得超過二年基地租金之總額，參照土地法第 105 條之規定。已交付之擔保金，超過前項限度者，承租人得以超過之部份抵付房租。耕地租賃，依土地法第 112 條之規定：「耕地出租人不得預收地租，但因習慣以現金為耕地租用之擔保者，其金額不得超過一年應繳租額四分之一。」押租金之收取原則採取禁止，例外許可。惟，耕地三七五減租條例第 14 條之規定：「出租人不得預收地租及收取押租。」採取完全禁止之立法政策。故除耕地租賃不得收取押租金之限制，住宅租賃與基地租賃僅受押租金額度的限制。

3.租約終止的限制

考量住宅租賃及基地租賃之使用性質，原則上不容許當事人任意終止契約，

⁵⁴ 最高法院 45 年台上字第 894 號判例：「耕地三七五減租條例第十一條之規定，為土地法第一百二十二條(此處法院疑似誤植，應為土地法第一百二十三條)之特別法，自應先於土地法第一百二十三條之規定而適用之。」

除承租人有不合宜之行為得作為終止租賃契約事由，土地法第 100 條第 2 款至第 6 款及第 103 條第 2 款至第 4 款之規定定有明文，針對住宅租賃新法租賃住宅管理條例第 10 條亦有相同規定。另外，住宅租賃依土地法第 100 條第 1 款之規定「出租人收回自住或重新建築時」得作為正當理由終止住宅租賃契約。不過，應注意的是土地法第 100 條之規定實務一方面認為適用住宅租賃以外之所有房屋租賃，另一方面僅適用於不定期租賃，其是否妥適容有爭議，詳見第五章第二節第五項、出租人終止權之限制。

在耕地租賃分為定期租賃及不定期租賃適用不同規定。前者依民法第 458 條及耕地三七五減租條例第 17 條第 1 項之規定，主要以承租人對於耕地使用不符、不能續行耕作目的，或有欠租、違法轉租之行為，出租人得作為終止契約之事由。後者依民法第 459 條及土地法第 114 條之規定，除適用上述事由外，增列「出租人收回自耕」及「耕地或耕作附屬物未盡善良管理注意」作為終止事由。特別的是為維持農民生計，土地法第 109 條之規定及耕地三七五減租條例第 19 第 1 項及第 20 條之規定，耕地租約於租期屆滿時，除了出租人之收益不足以維持一家生活而能自任耕作，並且收回耕地承租人家庭生活仍有依據者，得收回自耕外，如承租人願繼續承租者，應續訂租約，否則視為不定期繼續契約。換言之，「出租人收回自耕」也變相成為定期租賃終止契約之事由。

4. 優先承買權之賦予

除住宅租賃外，針對基地租賃、耕地租賃之當事人皆賦有優先承買權。前者，係為達到土地使用與房屋所有合一之目的，促進物之利用並減少糾紛，故民法第 426 條之 2 及土地法第 104 條定有相同規定，租用基地建築房屋，出租人出賣基地時，承租人有依同樣條件優先承買之權；承租人出賣房屋時，基地所有人有依同樣條件優先承買之權⁵⁵。後者，乃貫徹憲法第 143 條第 4 項之規定扶植自耕農之基

⁵⁵ 立法院公報處(1999)，〈立法院第 4 屆第 1 會期第 5 次會議紀錄〉，《立法院公報》，第 88 卷第 13 期，頁 334。
http://twinfo.ncl.edu.tw/tiqry/hypage.cgi?HYPAGE=search/merge_pdf.hpg&sysid=G9905252&jid=79001516&type=g&vol=8804070a&page=%E9%A0%811-513 (最後瀏覽日：12/08/2018)

本國策，民法第 460 條之 1 第 1 項、土地法第 107 條第 1 項及耕地三七五減租條例第 15 條第 1 項亦同規定，耕作地出租人出賣或出典耕作地時，承租人有依同樣條件優先承買權或優先承典權⁵⁶。

在特種租賃建構優先承買權，雖然對於弱勢承租人而言實益不大，但承租人享有優先承買權，確實有機會能夠減少租賃物買賣可能產生的交易糾紛，並且得以藉此追求使用權與所有權合一，發揮租賃物最大效益⁵⁷。故除了在基地租賃與耕地租賃建構優先承買權外，經濟價值相較低之住宅租賃則更應賦與承租人享有優先承買權，相關規定在中國與德國皆有立法例可循⁵⁸。

(二) 人格性之貫徹

一般租賃在違反轉租之情形，至多構成終止契約事由，而轉租契約並不當然無效(民法第 443 條第 2 項參照)。然而，在特種租賃不僅構成終止契約事由，並且轉租契約為無效。按土地法第 108 條之規定：「承租人縱經出租人承諾，仍不得將耕地全部或一部轉租於他人。」違者，原租賃契約得依法終止契約外，最高法院 39 年台上字第 1107 號判例謂：「土地法第一百零八條載承租人縱經出租人承諾，仍不能將耕地全部或一部轉租於他人，是承租人與該他人訂立之轉租契約，顯係違背禁止規定當然無效。」換言之，轉租契約自始無效。

更甚者，三七五減租條例第 16 條第 1 項及第 2 項之規定：「承租人應自任耕作，並不得將耕地全部或一部轉租於他人(第 1 項)。承租人違反前項規定時，原訂租約無效，得由出租人收回自行耕種或另行出租(第 2 項)。」不但轉租契約無效，原租賃契約一併無效，更顯租賃之人格性特徵。

二、動產租賃與不動產租賃

⁵⁶ 釋字第 124 號：「查耕地三七五減租條例第十五條第一項規定……(略)其立法意旨乃本於憲法所定扶植自耕農之基本國策，使承租人於耕地出賣或出典時，依當時之賣典條件，有優先承受之權；並就賣典條件通知承租人，限定以書面為之，以確保承租人之權益。」

⁵⁷ 林清汶，兩岸房屋租賃法制比較與效益研究，臺灣土地研究，第 21 卷第 1 期，頁 14-15，2018 年 5 月。黃健彰，房屋承租人優先購買權的承認與建構，政大法學評論，第 128 期，頁 85-95，2012 年 8 月。

⁵⁸ 黃健彰，前揭註 57，頁 95-103。

動產租賃與不動產租賃，自以租賃物客體為區分。不動產租賃者，謂以土地及其定著物為客體(民法第 66 條參照)。動產租賃，謂以不動產以外之物為客體(民法第 67 條參照)。考量不動產相較動產具有較高的經濟價值，法律常有特別規定，主要有四：

(一) 視為不定期租賃

民法第 422 條之規定：「不動產之租賃契約，其期限逾一年者，應以字據訂立之，未以字據訂立者，視為不定期限之租賃。」易言之，動產租賃不分期限及字據訂立與否，皆無本條適用。

(二) 所有權讓與不破租賃

其指民法第 425 條第 1 項之規定：「出租人於租賃物交付後，承租人占有中，縱其所有權讓與第三人，其租賃契約，對於受讓人仍繼續存在。」質言之，原則上不分租賃物客體動產及不動產皆有適用。但同條第 2 項之規定，不動產租賃契約，其期限逾五年或未定期限倘未經公證者，不適用之(民法第 425 條第 2 項前段參照)。

不過，對於租賃契約不分租賃物客體動產及不動產皆有所有權讓與不破租賃適用之立法體例，似有超越設立該制度「保護經濟上地位之弱勢」之本旨，蓋一般而言動產租賃並無經濟上強者之關係，實無保護之必要⁵⁹。然而，隨著時代變遷，凌駕於不動產價值之動產值並非罕見，以船舶為例，即於海商法第 41 條規定所有權讓與不破租賃之適用，因此否認動產無保護必要則過於直斷⁶⁰。再者，所有權讓與不破租賃之設立，不單純僅是保護經濟上地位之弱勢，其考量租賃物具有占有公示方法，能夠維護動態的交易安全，並不影響未來租賃物之受讓人原本即須負擔的資訊成本，故為了不額外增加承租人監督出租人忠實履行契約之交易成本，基於「法律經濟原則」，國家選擇保護承租人優先於受讓人，故是否限縮於

⁵⁹ 吳秀明，前揭註 29，頁 450-451。

⁶⁰ 陳玫君，論買賣不破租賃之修正與公證制度之引進，頁 28-30，國立成功大學法律學研究所碩士論文，2003 年 7 月。

不動產方有適用，值得再三推敲⁶¹。

(三) 法定租賃權

民法第 425 條之 1 規定：「土地及其土地上之房屋同屬一人所有，而僅將土地或僅將房屋所有權讓與他人，或將土地及房屋同時或先後讓與相異之人時，土地受讓人或房屋受讓人與讓與人間或房屋受讓人與土地受讓人間，推定在房屋得使用期限內，有租賃關係。其期限不受第四百四十九條第一項規定之限制。前項情形，其租金數額當事人不能協議時，得請求法院定之。」本條僅適用於不動產租賃，自文義即可得知。

(四) 情事變更原則

民法第 227 條之 2 第 1 項規定：「契約成立後，情事變更，非當時所得預料，而依其原有效果顯失公平者，當事人得聲請法院增、減其給付或變更其他原有之效果。」為情事變更總則性規定，原則上適用於所有租賃之契約型態。又，民法第 442 條針對租金調整設有特別規定：「租賃物為不動產者，因其價值之昇降，當事人得聲請法院增減其租金。但其租賃定有期限者，不在此限。」是情事變更原則態樣之一，僅適用於不動產租賃。不過，應注意的是民法第 422 條之規定並未排除不動產租賃除上開情形外，於有其他之情事變更，非契約成立當時所得預料，而依其原有效果顯失公平者，或動產租賃之當事人不得依民法第 227 條之 2 第 1

⁶¹ 胡天賜，買賣不破租賃制度之法律經濟分析，臺大法學論叢，第 33 卷 1 期，頁 176-178，2004 年 1 月。簡資修，讓與(買賣)不破租賃及其類推適用：長期投資保障觀點之分析，政大法學評論，第 78 期，頁 141-142，2004 年 4 月。

項規定聲請法院增減其租金⁶²。

(五) 法定留置權

民法第 445 條之規定：「不動產之出租人，就租賃契約所生之債權，對於承租人之物置於該不動產者，有留置權。」此條法定留置權僅有不動產出租人方可適用，故動產租賃不適用之。

(六) 終止契約之通知

不定期租賃，各當事人得隨時終止契約，但應依習慣先期通知(民法第 450 條第 3 項參照)。又依民法第 450 條第 3 項但書之規定：「不動產之租金，以星期、半個月或一個月定其支付之期限者，出租人應以曆定星期、半個月或一個月之末日為契約終止期，並應至少於一星期、半個月或一個月前通知之。」針對終止不動產契約之部分另設有規定。

(七) 特別委任

民法第 534 條但書第 2 款之規定：「受任人受概括委任者，得為委任人為一切行為。但不動產之租賃其期限逾二年者，須有特別之授權。」易言之，受任人代為處理訂立租約期限於二年者，客體為不動產須有特別授權，方為適法。

(八) 時效期間

有關租賃契約法律關係之時效，僅民法第 456 條之規定：「出租人就租賃物所受損害對於承租人之賠償請求權，承租人之償還費用請求權及工作物取回權，

⁶² 最高法院 93 年台上第 2446 號判例：「契約成立後，情事變更，非當時所得預料，而依其原有效果顯失公平者，當事人得聲請法院增、減其給付或變更其他原有之效果，民法第二百二十七條之二第一項定有明文。同法第四百四十二條規定：租賃物為不動產者，因其價值之昇降，當事人得聲請法院增減其租金。但其租賃定有期限者，不在此限。乃有關情事變更原則態樣之一，非調除上開情形外，於有其他之情事變更，非契約成立當時所得預料，而依其原有效果顯失公平者，當事人亦不得聲請法院增減其租金。故未定期限之基地租賃，契約當事人約定租金按基地申報地價之固定比率計算者，雖所約定之租金係隨基地申報地價之昇降而調整，惟倘契約成立後，基地周邊環境，工商繁榮之程度，承租人利用基地之經濟價值及所受利益等項，已有變更，非當時所得預料，而租金依原約定基地申報地價之固定比率計算顯失公平者，出租人自得依民法第二百二十七條之二第一項規定，訴請法院調整其租金。」最高法院 97 年度台上字第 625 號判決同旨。

均因二年間不行使而消滅。前項期間，於出租人，自受租賃物返還時起算。於承租人，自租賃關係終止時起算。」其餘請求權則回歸民法第 125 條以下規定適用，15 年間不行使而消滅。惟，有關租金請求權部分屬定期給付債權，其各期給付請求權，因 5 年間不行使而消滅(民法 126 條參照)。又，租賃客體屬動產並且為營業者之租價，因 2 年間不行使而消滅(民法 127 條參照)。

三、定期租賃與不定期租賃

定期租賃，指當事人約定租賃契約設有存續期限之限制；反之，未設有存續期限之限制，則為不定期租賃。兩者在成立、效力內容至消滅等層面，均有不同，主要有四：

(一) 存續期限之限制

為了充分發揮租賃物之使用價值，發展國民經濟，民法第 449 條第 1 項之規定：「租賃契約之期限，不得逾二十年。逾二十年者，縮短為二十年。」觀之，該條僅適用於定期租賃，不定期租賃不受租賃最長期限之限制。最高法院 65 年台上字第 2722 號判例：「民法第四百四十九條第一項之規定，不適用於不定期租賃，此觀之該條項所定『逾二十年者縮短為二十年』，可以瞭然。」採相同意旨。另外，定期租賃於期限到期，當事人得更新之，同條第 2 項定有明文。

(二) 終止權之行使

定期租賃之租賃關係，於期限屆滿時消滅；反之，不定期租賃，除有利於承租人之習慣者，從其習慣外，各當事人得隨時終止契約。(民法 450 條第 1 項及第 2 項參照)。

(三) 所有權讓與不破租賃

承如前述(本項二、(二)所有權讓與不破租賃)，原則上不分租賃物客體動產及不動產皆有所有權讓與不破租賃原則適用。但同條第 2 項之規定，租賃未定期限之不動產租賃契約未經公證，不適用之(民法第 425 條第 2 項後段參照)。

(四) 情事變更原則

民法第 442 條第 1 項之規定：「租賃物為不動產者，因其價值之昇降，當事人得聲請法院增減其租金。但其租賃定有期限者，不在此限。」換言之，定有期限之租賃契約，不論是動產租賃或不動產租賃，皆無本條適用。不過，此規定並未排除定期之動產租賃或不動產租賃有其他之情事變更，非契約成立當時所得預料，而依其原有效果顯失公平者，不得依民法第 227 條之 2 第 1 項規定聲請法院增減其租金，如前文所述(本項二、(四)情事變更原則)。

第二節 住宅租賃契約

第一項、意義

一、租賃物客體

住宅租賃契約，按租賃住宅管理條例第 3 條第 2 款之規定：「指當事人約定，一方以建築物租與他方居住使用，他方支付租金之契約。」所稱建築物，參考建築法第 4 條之規定，指「定著於土地上或地面下具有頂蓋、樑柱或牆壁，供個人或公眾使用之構造物或雜項工作物」。依最高法院 70 年台上字第 2221 號判例：「系爭房屋原計畫蓋建二樓，而建築之程度，二樓結構業已完成，僅門窗尚未裝設及內部裝潢尚未完成，此項尚未完全竣工之房屋，已足避風雨，可達經濟上之使用目的，即成為獨立之不動產。」易言之，圍有牆壁及上有屋頂以足避風雨並具經濟上使用目的方可稱為建築物。因此，針對樓層隔間及室內市場攤位實務亦承認得為建築物^{63、64}。

二、使用收益權限供與之範圍

⁶³ 最高法院 49 年台上字第 148 號判例：「走廊乃房屋之一部，上訴人於走廊內所隔之板屋，既係以被上訴人之二樓為屋頂，而以其屋柱為牆壁，則本件租賃即與土地法第一百零三條所謂租用建築房屋之基地有別，而屬同法第一百條規定適用之範圍。」

⁶⁴ 最高法院 72 年度台上字第 283 號判決：「(民國 64 年至 66 年間台北市石牌綜合市場)市場攤位租賃為房屋租賃之一種，而房屋租賃如約定承租人欠租時，出租人得逕行終止租約，與土地法第一百條第三款之強制規定有違，依民法第七十一條規定，此項約定應屬無效。」最高法院 85 年度台上字第 2068 號、85 年度台上字第 2069 號判決同旨。

不過，住宅租賃契約除了須以建築物作為租賃物客體外，同時限縮使用收益權限供與之範圍，以供與他方「居住使用」為限。故承租人承租建築物，須以居住使用為目的，倘基於其他目的，如：旅居娛樂、營業設廠、公司設址及室內的市場攤位等，則非住宅租賃契約。另外，學者從文義認為租賃住宅管理條例第 3 條第 2 款之定義規定容易造成承租人如非「自己」居住使用，如：轉租，則非住宅租賃契約之誤會，因此在立法技術上，提出「指當事人約定，一方以供居住使用之建築物租與他方，他方支付租金之契約。」建議，值得參考⁶⁵。

第二項、性質-要式契約與登記制度採行必要性探討

住宅租賃契約為租賃契約之一種型態。因此，租賃契約通常所具有之性質，包含：債權契約、不要式契約、諾成契約、有償契約、雙務契約及繼續性契約，住宅租賃契約自有之。不過，有論者基於租賃權物權化特性及維護交易安全之考量，針對住宅租賃契約提出採行要式行為並踐行登記制度之建議，是否必要值得討論⁶⁶。

一、不要式契約性質之維持

一般而言，要式行為之要求，是為達一定法政策之保護目的，如：警示目的、證據目的、公示目的及登記目的(行政目的)，否則基於契約自由，法律行為原則上不以踐行一定方式為必要⁶⁷。對此，住宅租賃契約是否存有一定法政策理由，而改為要式契約，實有探討必要。由於公示目的及登記目的，同時涉及登記制度之建議，故一併於下文(本項二、現行公示方法之維持)討論。

住宅租賃契約之締結，將使租賃物使用權限受到限制，對於當事人權益影響固然重大，似應促其注意以避免輕率。但與現行民法要求踐行要式行為之債權契

⁶⁵ 姚志明，概覽「租賃住宅市場發展及管理條例」，月旦法學雜誌，第 277 期，頁 12，2018 年 6 月。

⁶⁶ 王啟旭，房屋租賃問題之理論與實用，頁 9-12，國防管理學院法律學研究所碩士論文，1996 年 6 月。

⁶⁷ 王澤鑑，民法總則，頁 328，自版，2011 年 8 月。黃茂榮，契約法各論-買賣法，頁 149-153，植根，2004 年 12 月 6 版。

約相比，如：不動產交易契約(民法第 166 條之 1 參照)、合會(民法第 709 條之 3 參照)及人事保證契約(民法第 756 條之 1 參照)，則似沒有警示的問題。蓋不動產交易契約涉及物權之移轉、設定或變更之義務，其權益影響更大，但自民法第 166 條之 1 制定迄今對於該條要求要式行為是否妥適仍存有爭議以致尚未生效，更遑論僅以使用權授與之住宅租賃契約⁶⁸。又，合會契約通常牽涉當事人之人數為多，自須製作會單，使其權利義務關係臻於明確，而住宅租賃契約之當事人之人數較為單純，似無要求要式行為之必要⁶⁹。人事保證契約之性質原則屬無償契約，基於非自利行為，法律自設有保護或優待之規定，故為示慎重，期減少糾紛，以書面訂立為成立要件⁷⁰。住宅租賃契約為有償契約，屬自利行為，法律無須設有保護或優待之規定，更無改變不要式行為性質之需求。

另外，若基於證據功能而使住宅租賃契約為要式契約似嫌薄弱。一般而言，法律證明的方法甚多，包含：證人及物證等(民事訴訟法第 277 條以下參照)，並無改為要式契約之必要。在進一步言，民法第 166 條之規定：「契約當事人約定其契約須用一定方式者，在該方式未完成前，推定其契約不成立。」故當事人約定踐行一定的方式作為保全證據方法，非警示或保護作用者，僅生「推定」契約不成立效力，雖未踐行，契約亦非不成立。由是可知，基於證據目的作為改變不要式行為性質之理由則更嫌薄弱。

二、現行公示方法之維持

除此之外，鑑於「租賃權物權化」之特性，為維護交易安全，有使不特定之第三人得知法律行為內容之必要，並藉登記制度施以貫徹，使租賃契約內容透明化，故採行要式行為以達公示目的及登記目的⁷¹。職此，以俾使未來受讓人得以考慮交易或調整交易條件，亦得避免在強制執行事件中以成立假租約行妨害執行之

⁶⁸ 高欽明，不動產契約要式性與公證制度關聯性之研究——以民法第 166 條之 1 之施行作為探討，月旦法學雜誌，第 277 期，頁 192-198，2018 年 6 月。

⁶⁹ 立法院公報處(1999)，前揭註 55，頁 421-425。

⁷⁰ 王澤鑑，前揭註 36，頁 154-159。

⁷¹ 王啟旭，前揭註 66，頁 10-12。

實，固非無見⁷²。惟，從法理角度，「租賃權」之特性，名為「物權化」。換言之，本質為債權之一種，何以施行物權變動之公示方法。質言之，租賃權固然有對抗他人效力之物權特徵，為透明其法律關係，減少交易成本，避免第三人遭受損害，保護交易安全，尚得透過「占有」外觀作為公示方法，似乎沒有改為登記之必要。從現實角度，購買房屋必然親自前往探查實體樣貌，僅止於書面契約之討論，殊難想像，故不採登記方法並不影響受讓人調整交易條件之機會。如此，為達公示目的及登記目的而改為要式行為之理由即失所附麗。至於，在強制執行事件中以成立假租約行妨害執行之實，尚有其他法律救濟途徑，如：民法第 87 條之規定，不致使債權人的權益不能獲得保護。

除此之外，過去住宅租賃契約多以口頭約定，縱然簽訂書面契約，亦僅是形式程序⁷³。故若採行要式契約及踐行登記制度，恐增加簽約成本，非但不利租賃住宅市場的建立，當事人亦因要式行為之欠缺，導致契約無效，無法保障承租人之居住權益，實非妥適。整體而言，仍然維持住宅租賃契約之性質，毋庸改變。

第三節 私法自治與管制理論

住宅租賃契約，在租賃契約分類屬性上屬於特種租賃(住宅租賃)、不動產租賃、有體物租賃、非營業租賃及固有租賃，並依個案契約存續期限區分為定期租賃與不定期租賃。須注意的是，由於特種租賃常因租賃關係性質內容之需要調整當事人權利義務關係，尤其是與居住權益息息相關之住宅租賃契約，更顯而易見。由於此情有關國家權力介入住宅租賃契約權利內容，形成契約自由的限制，並且牽涉出租人之財產權，有必要探討其適法性。

第一項、私法自治

一、私法自治與契約自由

⁷² 王啟旭，前揭註 66，頁 10-12。

⁷³ 花敬群、呂秉怡、郭曜達，租賃住宅市場需求行為與市場區隔，載：中華民國住宅學會第十二屆年會論文集，中華民國住宅學會，頁 208，2003 年 12 月。

(一) 私法自治

私法自治為私法領域的重要指導原則，根基「個人自主」的自由思想，其係指個人得依其意思自由形成其私法上權利義務關係⁷⁴。質言之，私法自治即指個人得自由選擇對其利益最大的方式從事經濟活動，促進社會經濟發展與文化進步，國家必須予以尊重⁷⁵。個人創造私法上權利義務的主要方式便是法律行為，而其中「締結契約」為最常見的法律行為，同時亦是私法自治的最大展現，故尚有「契約自由」之名，亦有稱之「契約自治」⁷⁶。由是可知，為落實私法自治，契約自由為不可或缺的重要原則。依大法官釋字第 576 號解釋：「契約自由為個人自主發展與實現自我之重要機制，並為私法自治之基礎。契約自由，依其具體內容分別受憲法各相關基本權利規定保障，例如涉及財產處分之契約內容，應為憲法第十五條所保障，又涉及人民組織結社之契約內容，則為憲法第十四條所保障；除此之外，契約自由亦屬憲法第二十二條所保障其他自由權利之一種。⁷⁷」不僅明白承認契約自由為私法自治之基礎，更屬憲法保障的權利。

(二) 契約自由

契約自由強調在個人自主原則及之契約嚴守原則前提下，當事人得以契約自由安排個人私生活領域，契約的履行內容對當事人具有拘束力，並且基於私法自治，不受國家或第三人之侵擾⁷⁸。換言之，契約自由指在當事人雙方符合意思自主的狀態，得透過契約所創制的權利義務關係，國家或第三人無法介入當事人之權利義務關係。

契約自由具體內容的表現，依大法官釋字第 580 號解釋指：「使契約當事人得自由決定其締約方式及締約內容，以確保與他人交換生活資源之自由。⁷⁹」換言之，

⁷⁴ 王澤鑑，前揭註 67，頁 264-266。

⁷⁵ 孫森焱，民法債編總論(上冊)，三民，頁 3-5，2012 年 2 月修訂版。

⁷⁶ 謝哲勝，契約自治與管制，月旦法學雜誌，第 125 期，頁 30，2005 年 10 月。

⁷⁷ 大法官釋字第 602 號解釋。

⁷⁸ 陳聰富，契約自由與定型化契約的管制，月旦法學雜誌，第 91 期，頁 51-52，2002 年 12 月。

陳聰富，社會問題與契約管制的界限，月旦法學雜誌，第 125 期，頁 83-85，2006 年 07 月。

⁷⁹ 大法官釋字第 716 號解釋。

契約自由具有方式及內容兩種自由面向。學說更將契約自由內容歸納出五種面向：締約自由、相對人選擇自由、方式自由、內容自由及變更或廢棄自由⁸⁰。

二、私法自治的失靈

理想的私法自治運作，須以當事人自由平等為前提，確保自由競爭及機會均等始足確保契約內容的妥當性⁸¹。一般情形，市場外部環境失去有效競爭，乃至於當事人內部間存有資訊地位或經濟地位落差，易導致當事人間失去平等，甚至一方成為任由宰割的犧牲者⁸²。此情，早期常見於大地主與小佃農的耕地租賃契約(耕地三七五減租條例參照)，近期則發生於資本主與勞動者締結的僱傭契約(勞動基準法參照)與企業主與消費者締結的買賣契約(消保法參照)等，國家即須介入，以追求契約正義，避免私法自治失靈及契約自由之濫用。

在住宅租賃契約關係，出租人掌握租賃住宅的資訊並且擁有承租與否之決定權，相比之下承租人對於租賃住宅具有高度需求，在締約、履約或結束契約的過程中，事實上皆處於地位不對等的狀態，以致可能發生出租人隱匿重要資訊、任意調漲租金、提前終止租約等相關問題。職此，國家如何彰顯保護承租人，彌平地位不對等的狀態，避免私法自治失靈及契約自由之濫用，並且確切履行人民居住權益保障的義務確實為當務之急⁸³。

第二項、管制理論

一、管制層面

對於私法自治失靈及契約自由濫用之情形，國家藉由行政及司法在不同層面，於外部環境及內部當事人間，設有不同管制手段，以恢復當事人自由平等之前提，維持私法自治運作功能。前者主要是公平交易法的任務，透過建制有效正當的競爭環境，使市場提供維持充足的交易選擇對象，防止地位力量的形成；後

⁸⁰ 王澤鑑，前揭註 67，頁 266-267。詹森林，民事法理與判決研究，元照，頁 12-14，1998 年 11 月。鄭冠宇，民法債編總論，新學林，頁 34，2017 年 9 月 2 版。

⁸¹ 王澤鑑，前揭註 67，頁 267。

⁸² 楊宏暉，市場經濟秩序下的契約失靈調整模式，法學新論，第 25 期，頁 74-76，2010 年 8 月。

⁸³ 林旺根，論制定住宅租賃專法之必要性，月旦法學雜誌，第 245 期，頁 168-171，2015 年 10 月。

者，主要彌平當事人內部地位落差，調整權利義務關係，以平衡當事人雙方權益，此乃是民事法關心的重點⁸⁴。一般而言，在當事人權利義務關係中，依據地位落差的原因，民事法有不同的補救方法，在住宅租賃契約的法律關係亦不例外。

(一) 資訊地位不平等

在住宅租賃的法律關係，出租人對於租賃住宅的資訊，包含：坪數、格局、樓層及區域環境機能等訊息，由於是自身提供或受他人信任委託出租，相較於承租人清楚。再加上，以租賃為業的包租公(婆)在租賃住宅管理的相關事務有豐富經驗，則對初次承租住宅之人或從外地遷居之人，往往因欠缺經驗、知識，在交易地位呈現落差，是有必要彌平資訊取得不對等，以避免產生糾紛。

因此，當雙方利用資訊地位落差，致生當事人意思表示瑕疵，如：意思表示錯誤(民法第 88 條參照)、被詐欺或脅迫(民法第 92 條參照)，當事人得享有撤銷權利，以排除契約效力。此外，不同於一般締約階段為了強化個人自主決定權之機會，確保當事人意思表示是在資訊充分與思慮周全的前提下完成，採取強化資訊告知義務或賦予猶豫期間(悔約權)之方式，租賃住宅管理條例第 13 條第 1 項採取廣告真實義務，要求出租人提供之租賃住宅廣告內容應與事實相符，來保障當事人雙方之權益⁸⁵。

(二) 結構地位不平等

然而，縱使充分揭露資訊，當遇有經濟、武器地位等結構性不平等時，如：自然獨占事業，容易發生被迫接受不利條件之情事，仍舊存在不能完全消弭地位落差的情形。再加上，若意思表示健全無瑕疵，契約內容是否公平、對價是否相當，法院原則上尊重當事人之間的約定並不介入，將使弱勢一方權益雪上加霜。

因此，一般民事法為消弭結構性不平等落差，將對契約內容於事前劃清契約自由的界限，如：強制締約規定(如：自來水法第 61 條、電信法第 22 條參照)、公

⁸⁴ 楊宏暉，前揭註 82，頁 70-74。

⁸⁵ 陳聰富，前揭註 78，頁 52-53。

布契約範本(如:消保法第 11 條之 1、租賃住宅管理條例第 5 條參照)；或事後在個案中藉司法程序審查契約，以維護契約正義，一旦契約內容違反法律強制規定(民法第 71 條參照)、公序良俗(民法第 72 條參照)或誠信原則(消保法第 11 條及第 12 條參照)得透過法院確認無效⁸⁶。至於如何於司法程序審查契約內容，學說上在此亦多所著墨，成果蔚藍，足資參照⁸⁷。

在住宅租賃契約關係當中，由於租賃住宅出租與否為出租人之自由，相比承租人因不易尋求合宜的居住處所，容易被迫接受各種承租條件，故在結構上出租人享有優勢地位。國家在住宅租賃政策手段的抉擇上，除了契約內容違反法律強制規定或公序良俗回歸民法適用外，特別採取事前公布《住宅租賃契約應約定及不得約定事項》，透過行政管制監督住宅租賃契約全部內容，解決結構地位不平等的問題，不在僅止過去租金、押租金額度管制與租約終止權行使限制的問題。

二、合適的手段標準

(一) 適宜解決私法自治失靈

國家介入私法自治，限制契約自由，皆以恢復制度功能為最大目標，依大法官釋字第 580 號解釋：「憲法第二十二條保障人民之契約自由……。惟因個人生活技能強弱有別，可能導致整體社會生活資源分配過度不均，為求資源之合理分配，國家自得於不違反憲法第二十三條比例原則之範圍內，以法律限制人民締約之自由，進而限制人民之財產權。」觀之，國家介入手段除具有正當理由外，並須合於比例原則，方符合憲法第 23 條保障人民權益之意旨。故在私法自治失靈之前下，國家介入私法自治之管制手段須對私法自治負擔最小，且產生的效益須大於管制成本，包含制度建制、效率犧牲等其他成本總合，方可運用⁸⁸。

⁸⁶ 黃立，契約自由的限制，月旦法學雜誌，第 125 期，頁 8-10，2005 年 10 月。楊宏暉，前揭註 82，頁 81-90。

⁸⁷ 陳聰富，前揭註 78，頁 54-62。黃立，前揭註 86，頁 12-22。詹森林，定型化契約條款效力之規範—最高法院 90 年臺上 2011 號、91 年臺上 2220 號、92 年臺上 39 號判決之商榷，律師雜誌，第 239 期，頁 21-40，2004 年 2 月。詹森林，民事法理與判決研究(四)消費者保護法專論(2)，元照，頁 122-142，2003 年 8 月。

⁸⁸ 謝哲勝，前揭註 76，頁 26-28。

基於居住權益保障，國家有義務提供住宅租賃契約承租人良善的居住環境。因此，國家在透過住宅租賃政策實現居住權益保障的過程，不可迴避的必須介入當事人住宅租賃權利義務關係，以切合特種租賃特別強調租賃社會化之特性。對於國家介入私法自治除了具備足夠的正當理由方能介入外，其手段須合於比例原則，否則任意介入將適得其反，使整體社會經濟活動效率降低，而損及公共利益。

(二) 調和處理基本權利衝突

除此之外，藉助出租人之租賃住宅提供保障，則緊接必須面對出租人無法自由決定契約內容如何處分、收益及管理租賃住宅，造成憲法財產權保障弱化之事實⁸⁹。此觀，大法官釋字第 400 號解釋：「憲法第十五條關於人民財產權應予保障之規定，旨在確保個人依財產之存續狀態行使其自由使用、收益及處分之權能，並免於遭受公權力或第三人之侵害，俾能實現個人自由、發展人格及維護尊嚴。」既可得知。職此，承租人之居住權益與出租人之財產權產生衝突，國家實有必要進行利益衡量。

由於此情使得國家在形塑住宅租賃政策的過程中，須周旋於「禁止保護不足」與「禁止過度侵害」兩方面，一旦偏頗，皆可能成為違憲法律⁹⁰。一般在基本權衝突解決理論中，常以「視狀況而定的利益權衡原則」(situationsabhängige Güterabwägung)作為解決方法⁹¹。居住權益涉及人民基本的生活需求，是維持自身生命的最基本權利，更是享受財產權保護之前提，故居住權益享有優先的保護。但縱然財產權在基本權衝突中讓步，並不代表得侵害其權利的核心內容。因此，國家透過住宅租賃契約來履行承租人之居住權益保障，相對而言可能犧牲出租人之權益，若犧牲之強度已達徵收或類似徵收的情形，國家仍應給予補償。

第三項、小結

在正常的住宅租賃契約關係中，由於出租人能夠掌握租賃住宅的資訊，並且

⁸⁹ 程明修，契約自由與國家之保護義務，憲政時代，第 30 卷第 2 期，頁 200，2004 年 10 月。

⁹⁰ 程明修，前揭註 89，頁 216-219。

⁹¹ 李震山，基本權利之衝突，月旦法學雜誌，第 1 期，頁 60-61，1995 年 5 月。

以租賃為業的包租公(婆)在租賃住宅管理的相關事務有豐富經驗，對承租人而言，往往因欠缺經驗、知識，在交易地位呈現落差，有必要彌平資訊取得不對等。再者，租賃住宅既為出租人所有，其得自由選擇承租與否，相比承租人對於租賃住宅具有高度需求之下，在結構上出租人享有優勢地位。因此，國家實有介入之必要。

在土地法第三編第三章及租賃住宅管理條例第二章中，立法者專設規範調整住宅租賃契約當事人之權利義務關係，以充分保護承租人，目的在於落實人民居住權益的保障及實踐居住公平。不過，即使以保護為目的之立法，亦不能對出租人之契約自由造成過度的限制。此外，居住權益涉及人民基本的生活需求，是享受財產權保護之前提，因此承租人之居住權益相對出租人之財產權享有優先的保護，但並不代表得侵害其權利核心內容，若出租人之權益犧牲強度已達徵收或類似徵收的情形，國家仍應給予補償。至於國家住宅租賃政策所採取手段是否符合上述標準，實有必要檢視，則待第四章資訊地位平等及第五章經濟地位平等分述。

第三章 租賃住宅市場發展及管理條例

第一節 立法背景

現行住宅租賃契約主要規範於《民法》與《土地法》，但前者對於租賃並不區分標的、使用屬性，以營業目的為例，自與居住為目的之租賃所顧慮的事項不同，故對於住宅租賃契約易有保護不周的問題⁹²。後者雖強調租賃權社會化特性，著重承租權之保護，因時空遞嬗，長久未予檢討修正，顯得不切實際⁹³。鑑於住宅租賃契約是落實居住權益保障之一環，為改善租賃環境並確保雙方權益，因此制定《租賃住宅市場發展及管理條例》(以下簡稱：租賃住宅管理條例)。

《租賃住宅管理條例》分別為總則(第 1 條)、健全住宅租賃關係(第 5 條)、租賃住宅服務業(第 19 條)、罰則(第 36 條)與附則，共計五章。其中，第三章租賃住宅服務業，則又分三節，含設立登記(第 19 條)、租賃住宅管理人員(第 26 條)與業務及責任(第 28 條)。縱觀本法，是第一部規範住宅租賃法律關係的專法，以保障住宅租賃雙方權益及健全租賃住宅市場發展為規範內容。

第二節 適用對象

《租賃住宅管理條例》以住宅租賃契約為規範對象，故適用的範圍與舊有《民法》及《土地法》相較狹隘。反面而論，住宅租賃契約除有《租賃住宅管理條例》適用，亦有《民法》及《土地法》適用，惟以《租賃住宅管理條例》為特別法優先適用，自屬當然。特別注意的是，《租賃住宅管理條例》既是以保障居住權益為目的，若當事人雙方屬於住宅租賃契約但租賃期間未達 30 日，考量受《租賃住宅管理條例》之特別保護的效益並不大，故排除適用(租賃住宅管理條例第 4 條參照)。

另外，租賃住宅管理條例第 4 條第 2 款及第 3 款之規定基於出租人的性質，考量其屬於其他法律規定範疇，亦排除本條例之適用。如出租人為政府、其設立之專責法人或機構，其經營管理之租賃住宅多為公有財產管理範疇，並且大多涉

⁹² 謝哲勝，土地法，翰蘆，頁 259，2013 年 9 月 3 版。

⁹³ 林旺根，前揭註 83，頁 185-186。

及執行社會住宅等相關政策，屬住宅法等相關規定範疇，故予以排除⁹⁴。又，合作社經營租賃住宅服務者，則考量其經營型態，多以服務社員使用為限，其運作、資金及盈餘係由社員透過民主方式開會決定，依合作社法第 23 條及第 24 條之規定提列公積金及公益金，得按社員交易額比例攤還予社員，此方式更可保障租賃當事人權益，故回歸該法規範合作事業經營管理之範疇，排除適用本條例⁹⁵。

有關住宅租賃契約，倘具有消費關係時，依消保法第 1 條第 2 項之規定：「有關消費者之保護，依本法之規定，本法未規定者，適用其他法律。」換言之，具消費關係之住宅租賃契約，應優先適用消保法。從租賃住宅管理條例第 5 條第 1 項之規定：「租賃契約具消費關係者，適用消費者保護法相關規定；非具消費關係者，其應約定及不得約定事項，由中央主管機關定之。」亦能得到相同答案。

第三節 立法特色

第一項、保障當事人雙方的權益

概覽《租賃住宅管理條例》特別強調租賃住宅資訊的透明且真實，包含：修繕義務的說明、同意轉租的證明及租賃住宅廣告的真實，以彌平租賃住宅資訊不平等的現象。並且，明確授權行政機關透過行政管制監督住宅租賃契約全部內容，解決結構地位不平等的問題(租賃住宅管理條例第 5 條參照)。換言之，國家干涉範圍，不單侷限於過去租金或押租金額度管制與租約終止權行使限制的問題。除此之外，新條例之規定亦透過法條明文化之方式釐清過去法律爭議，以達到保障當事人之權益。

以下依主題羅列探討新法特色，其餘問題，如：租賃住宅廣告、租金、押租金及租約終止權行使，則待第四章資訊地位平等及第五章經濟地位平等詳述。

一、出租人的修繕義務

⁹⁴ 立法院公報處(2017)，前揭註 28，頁 84。

⁹⁵ 立法院公報處(2017)，前揭註 28，頁 84-85。

（一）修繕項目及範圍事前說明

依民法 423 條之規定：「出租人應以合於所約定使用收益之租賃物，交付承租人，並應於租賃關係存續中，保持其合於約定使用、收益之狀態。」此乃出租人主給付義務，於住宅租賃亦當然適用，故租賃住宅管理條例第 8 條第 1 項之規定：「在出租人應以合於所約定居住使用之租賃住宅，交付承租人，並應於租賃期間保持其合於居住使用之狀態。」兩者大致相同。不同的是，出租人修繕義務依租賃住宅管理條例第 8 條第 2 項之規定：「出租人應於簽訂租賃契約前，向承租人說明由出租人負責修繕項目及範圍，並提供有修繕必要時之聯絡方式。」即出租人負責修繕項目及範圍應於簽訂租賃契約前說明，透過事前分配風險責任，降低糾紛發生率，減少交易成本，此乃呼應過去論者透過交易成本分析所得之成果⁹⁶。

（二）修繕義務的免除範圍

不過，依民法第 429 條第 1 項之規定：「租賃物之修繕，除契約另有訂定或另有習慣外，由出租人負擔。」原則由出租人負修繕義務，是否可以依約定免除全部修繕義務，不無疑問。從新法及《住宅租賃契約應約定及不得約定事項》之出租人負責修繕項目及範圍確認書，並無明文限制免除義務的範圍。但出租人負有保持合於住宅義務，故租賃住宅毀壞程度達不能住居使用時，出租人仍應負修繕義務，不宜任由出租人排除全部修繕義務⁹⁷。再進一步言，若從承租人追求適宜的生活住宅品質之居住權益內涵角度觀察，對於出租人修繕義務免除之範圍沒有限制，容易產生出租人利用優勢地位透過契約約定將修繕義務迫使承租人負擔，對承租人之保護實在不周。

二、租賃住宅轉租制度

⁹⁶ 馬翊峰，房屋租賃契約之交易成本分析，頁 42-43，立德大學地區發展管理研究所論文，2008 年 6 月。

⁹⁷ 陳冠甫，評租賃住宅市場發展及管理條例——以健全住宅租賃關係法為中心，月旦法學雜誌，第 277 期，頁 51，2018 年 6 月。

(一) 採取不許轉租為原則

住宅租賃契約屬於特種租賃，基於住宅租賃政策強化承租人之保護，故特別貫徹租賃人格性之特性，是出租人平衡承租人之利益的手段。換言之，欲限制住宅租賃承租人任意轉租之權利，以承租人在權利義務關係中享有特別保護為前提。在轉租問題上，依租賃住宅管理條例第 9 條第 1 項之規定：「轉租人應經出租人書面同意，始得轉租其租用之住宅全部或一部。」不同於民法第 443 條但書之規定：「……。但租賃物為房屋者，除有反對之約定外，承租人得將其一部分轉租於他人。」換言之，住宅租賃契約採取不許轉租為原則。違者，出租人得提前終止租賃契約，且承租人不得要求任何賠償(租賃住宅管理條例第 10 條第 3 款參照)。因此，現行法制嚴格限制住宅租賃承租人任意轉租之權利，但適宜與否則須視住宅租賃政策是否強化承租人之保護，對此於本章第三項、小結詳述。

(二) 同意轉租之要件

另外，過去出租人同意轉租之意思表示，方法並無限制⁹⁸。為了確立轉租制度，提昇資訊透明化，應事前取得出租人同意轉租之書面文件，於簽訂轉租契約時，向次承租人出示該書面文件，並於轉租契約載明其與出租人之租賃標的範圍、期間及得終止租賃契約之事由(租賃住宅管理條例第 9 條第 2 項參照)。並且，簽訂轉租契約後三十日內，轉租人應以書面通知出租人(租賃住宅管理條例第 9 條第 3 項參照)。

三、住宅租賃契約管制

(一) 住宅租賃契約應約定及不得約定事項效力

市面上充斥各種住宅租賃契約的版本，提供或販售的住宅租賃契約內容繁簡不一，有時條款前後矛盾、責任歸屬含糊不清及內容過於偏袒一造等，導致糾紛

⁹⁸ 最高法院 32 年上字第 5859 號判例：「承租人非經出租人承諾，固不得將承租之房屋全部轉租於他人，但此項為承諾之意思表示，則不以訂立書據為必要。其由出租人或經其授權之代理人口頭承諾者，出租人即不得更依民法第四百四十三條之規定終止租約。」

四起、亂象叢生。為了促進交易便捷、避免爭議及訟累，針對非具消費關係之住宅租賃契約內容，如：非企業經營者之出租人(二房東)或承租人非消費者(員工宿舍)，租賃住宅管理條例第 5 條之規定授權中央主管機關訂定應約定及不得約定事項內容，違反應約定及不得約定事項者，無效；而應約定事項未記載於契約者，仍構成契約之內容。應注意的是，立法者授權公布的《住宅租賃契約應約定及不得約定事項》性質屬於法規命令，是否拘束私法上之契約關係，依憲法第 80 條之規定及釋字 216 號解釋司法機關握有最後決定權⁹⁹。換言之，當行政機關公告《住宅租賃契約應約定及不得約定事項》不符租賃住宅管理條例第 5 條之規定授權意旨時得適當表示不同見解，法官並不受其拘束，故縱使當事人使用行政機關公告《住宅租賃契約應約定及不得約定事項》作為契約條款，仍得宣告無效¹⁰⁰。

(二) 嚴密管制契約的質疑

1. 交易市場僵化

不過，此種行政機關透過行政權直接介入私法契約關係，應自我節制，同時司法機關應積極審查行政機關所公告契約條款的效力，避免法律斷喪適用彈性與自由的空間¹⁰¹。查立法者授權公告的《住宅租賃契約應約定及不得約定事項》與消保法第 17 條第 5 項之規定授權擬訂《房屋租賃定型化契約應記載及不得記載事項》，大致相同，至多為法規命令的重申。在過去消保法為解決結構性地位平等問題，透過行政權管制契約內容一直遭受多方質疑，包含：法律授權不明確、私法自治過度侵蝕，更遑論是在非消費關係之租賃契約，恐怕將導致交易市場僵化，不利承租人談判交換其他有利的交易條件¹⁰²。

⁹⁹ 蕭文生，行政機關公告行為之法律性質，月旦法學教室，第 40 期，頁 22-23，2006 年 2 月。

¹⁰⁰ 詹森林，消費者保護法與預售屋買賣定型化契約，臺大法學論叢，第 27 卷第 4 期，頁 103-105，1998 年 7 月。詹森林，消費者保護法發展專題回顧：定型化契約之理論與實務發展，國立臺灣大學法學論叢，第 43 卷特刊期，頁 1384-1385，2014 年 11 月。詹森林，民事法理與判決研究(三)消費者保護法專論，元照，頁 94-96，2003 年 8 月。

¹⁰¹ 張嘉麟，行政機關對定型化契約內容管制之探討－以定型化契約應記載或不得記載事項為中心，消費者保護研究，第 20 輯，頁 141-142，2016 年 2 月。

¹⁰² 胡華泰，消費定型化契約條款之行政規制，消費者保護研究，第 17 輯，頁 144-145，2011 年 12 月。曾品傑，論不動產不誠實廣告之契約效力(下)－最高法院相關判決評釋，台灣本土法學雜誌，第 82 期，頁 33-35，2006 年 5 月。

2. 法律適用複雜化

再者，嚴密的管控可能造成住宅租賃契約法律適用更加複雜，以「轉租」為例，在《住宅租賃契約應約定及不得約定事項》第 7 點第 3 項規定為：「出租人 □ 同意 □ 不同意承租人將本租賃標的之全部或部分轉租出借或以其他方式供他人使用，或將租賃權轉讓於他人。」由此觀之，出租人是否同意承租人轉租，在《住宅租賃契約應約定及不得約定事項》為住宅租賃契約之應約定事項，如當事人有清楚約定固然沒有問題，然若對於其應約定而未為約定，究竟是依租賃住宅市場管理條例第 5 條第 4 項前段為無效，抑或是同條項後段構成契約內容，不無疑問¹⁰³。

對於上述問題，由於得否轉租之規範既然設計開放方式，於雙方當事人在未約定的情形下，則回歸租賃住宅管理條例第 9 條第 1 項之規定，當事人既未於住宅租賃契約中約定承租人得否轉租，不應構成契約之內容，亦沒有無效問題¹⁰⁴。由此觀之，對於住宅租賃政策一方面欲全面管制契約內容，二方面又無意強制規範當事人間之權利義務，確實造成住宅租賃契約法律適用更加複雜¹⁰⁵。

3. 不利個案正義

此外，行政機關預先評斷契約內容的公平性，具有一定的外觀或假象，將使法院在處理複雜的危險分配問題多不再挑戰其公平性，導致行政機關的行政命令具有高度規制力，將不利個案正義的實行¹⁰⁶。是否堅守現行法制嚴密的管控，或者於法律作原則性的規範標準，如：消保法第 11 條 1 項、第 12 條及其施行細則第 14 條之規定，藉由司法審查調和當事人權益，實有討論的空間。

四、 免費調處爭議機制

(一) 土地法第 101 條調處制度現況

依土地法第 101 條之規定：「因房屋租用發生爭議，得由該管直轄市或縣（市）

¹⁰³ 徐婉寧，住居租賃轉租之效力，月旦法學教室，第 192 期，頁 15-17，2018 年 10 月。

¹⁰⁴ 徐婉寧，前揭註 103，頁 17。

¹⁰⁵ 徐婉寧，前揭註 103，頁 17。

¹⁰⁶ 陳自強，契約之成立與生效，元照，頁 209，2014 年 2 月 3 版。

地政機關予以調處，不服調處者，得向司法機關訴請處理。」依直轄市縣（市）不動產糾紛調處委員會設置及調處辦法（以下簡稱：調處辦法）第 21 條之規定，調處須按年租金額度繳交 3000 元至 15000 元四級調處費用。然而，依土地法 101 條及調處辦法第 19 條第 3 項之規定，其結果不如法院判決具有確定力，至多發生法律上擬制合意之私法上和解契約效力¹⁰⁷。考量調處程序並非起訴條件並且住宅租賃糾紛通常涉及金額較低，實對當事人而言意義不大¹⁰⁸。故租賃住宅管理條例第 16 條之規定將調處費用予以免費，以減輕爭議處理的成本負擔。

（二）民事訴訟法爭端解決機制問題

縱觀租賃爭議處理，有論者分析除了自行協商處理爭議，所花費成本最低外，不論是一般訴訟程序、簡易訴訟程序或小額訴訟程序投入金錢、時間及人力皆高，對降低交易成本幫助有限¹⁰⁹。另外，調解部分因當事人兩造或一造未必皆如期到場者，尤其是故意違約之一方，如於司法調解依民事訴訟法第 420 條之規定法官得酌量情形視為調解不成立，或如於行政調解依鄉鎮市調解條例第 20 條之規定將逕自視為不成立，此皆再次導引當事人回訴訟制度，實不利當事人降低交易成本。縱然民事訴訟法第 409 條第 1 項前段之規定：「當事人無正當理由不於調解期日到場者，法院得以裁定處 3,000 元以下之罰鍰。」以強化調解，發揮其疏減訟源之功能。但若於該次調解期日即當庭諭知調解視為不成立而不再另訂調解期日時，將

¹⁰⁷ 目前針對直轄市縣（市）不動產糾紛調處委員會設置及調處辦法第 19 條第 3 項發表見解之最高層級的法院判決為臺北高等行政法院 104 年度訴字第 834 號裁定：「……即調處程序僅係調處委員會協助當事人以協議方式解決其私權之爭議，於雙方協議不成時，依調處辦法第 19 條第 1 項之規定，調處委員會雖應就有關資料及當事人陳述意見，予以裁處，作成調處結果，惟該調處結果並不對外直接發生法律效果，故當事人之任何一方均得於 15 日內不服該調處結果，向民事法院訴請審理，此時調處結果失其效力，應依民事判決結果解決當事人間之私權爭議。依調處辦法第 19 條第 3 項之規定，僅於雙方當事人均同意調處結果，即當事人均逾期未提起民事訴訟，當事人間之爭議可依調處結果辦理，此時調處結果發生效力，乃法律上擬制同意協議之效果，並非基於調處結果係可直接對外發生公法效力之行政處分所致。」臺北高等行政法院 106 年度訴字第 758 號裁定、臺中高等行政法院 103 年度訴字第 83 號、103 年度訴字第 252 號及 108 年度訴字第 4 號裁定同旨，由於此等案件皆無上訴，故無法取得最高行政法院之看法。

¹⁰⁸ 最高法院 68 年台上字第 1340 號判例：「土地法第一百零一條雖規定：『因房屋租用發生爭議，得由該管市縣地政機關予以調處』，既僅定為『得』由該管地政機關調處，自非『應』由地政機關調處之強制規定，則被上訴人未經該項調處程序，逕行起訴，仍為法之所許。」

¹⁰⁹ 馬翊峰，前揭註 96，頁 58-59。

失去強制抗告人到場調解之立法目的，則不得罰鍰¹¹⁰。如此，使本條顯得無用武之地。

(三) 立法建議

針對當事人兩造或一造未必皆如期到場調解部分者，似可參考仲裁法第 1 條第 4 項之規定：「當事人間之文書、證券、信函、電傳、電報或其他類似方式之通訊，足認有仲裁合意者，視為仲裁協議成立。」緩和現行法制的僵化。另外，由於仲裁制度採行一裁終局，毋庸花費過多的時間、金錢，並與法院之確定判決，有同一效力(仲裁法第 37 條第 1 項參照)，得鼓勵當事人約定使用仲裁制度。一方面補足調處與訴訟制度的不足。二方面仲裁容許當事人可以選任具有特殊專業知識的專業人士相較於法官更能處理複雜及專業的爭議，似較符合當事人之需求。

第二項、健全租賃住宅市場發展

過去臺灣租賃住宅市場一直未能發展，主要歸究於國內房屋投資市場習慣多以持有不動產之期間增值作為報酬來源¹¹¹。租金收益對於房屋投資者，受限於房屋租賃交易成本過高，包含：搜尋成本、協商成本、執行成本及糾紛成本等等，不足支應成本，使多數人放棄租金收益，間接導致閒置的空屋數量極高，實在浪

¹¹⁰ 目前針對民事訴訟法第 409 條發表見解之最高層級的法院判決為臺灣高等法院 105 年度抗字第 1795 號裁定：「按民事訴訟法第 409 條第 1 項固規定當事人無正當理由不於調解期日到場者，法院得以裁定處 3,000 元以下之罰鍰。觀其立法理由乃為強化調解，發揮其疏減訟源之功能，故有促請當事人到場之必要，然而如當事人不到場時，因法條規定為『得』以裁定裁處罰鍰，其應否裁罰，自應由法院就具體事件斟酌實際情況為適當之裁量，本非必須裁處罰鍰。本件抗告人雖未於上開調解期日到場，但相對人到場後亦表明不願意調解，請求移民事庭審理，此有調解程序筆錄附卷可稽（見司調卷第 35 頁），可見本件調解本顯無成立之望，與抗告人是否到場，並無必然關連性。且依民事訴訟法實務與學說向來之見解，咸認當事人具有程序主體權，得以自由選擇民事程序以解決紛爭，如當事人不同意以調解方式處理，自無強令其於調解期日到場進行調解程序之必要。況依民事訴訟法第 420 條之規定，當事人兩造或一造於期日到場者，法官酌量情形，得視為調解不成立或另訂調解期日，倘原法院司法事務官認本件尚有調解之必要，本得另訂調解期日，再次促請當事人到場。但原法院司法事務官於該次調解期日即當庭諭知本件視為調解不成立，而不再另訂調解期日，則原法院司法事務官嗣後再對抗告人處以罰鍰，亦失去強制抗告人到場調解之立法目的，顯無必要。本件抗告人係初次調解期日未到場，即遭原法院司法事務官逕處以最高額之罰鍰，其裁量實非妥適，容有斟酌餘地。原裁定駁回抗告人對於該處分所聲明之異議，亦有未合。抗告意旨指摘原裁定不當，聲明廢棄，為有理由，爰由本院廢棄原裁定及原法院司法事務官所為之處分。」參照。

¹¹¹ 華昌宜、賴碧瑩，前揭註 27，頁 71。

費資源及不利國家經濟發展¹¹²。故為了促進閒置的房屋資源有效運用以健全租賃住宅市場之目的，「降低房屋租賃交易成本」為《租賃住宅管理條例》主要政策手段。

一、設計市場交易模式

鑑於現行法制對於租賃住宅服務業相關規範付之闕如，租賃住宅管理條例第 3 條第 3 款之規定，將租賃住宅服務業明文設計兩種交易模式，分別為「租賃住宅代管業」（簡稱代管業）及「租賃住宅包租業」（簡稱包租業），透過建制市場交易模式釐清租賃住宅服務業與租賃住宅服務當事人間權利義務關係，以避免產生租賃住宅管理業務糾紛成本。此外，為鼓勵個別房東將住宅委託代管業或出租予包租業轉租，提供居住使用一年以上之契約約定者，地價稅、房屋稅得予適當減徵，租金所得稅依收入亦有不同程度的減徵規定，使租賃住宅代管及包租服務市場得以建立。

（一）代管業

其指受出租人之委託，經營租賃住宅管理業務之公司（租賃住宅管理條例第 3 條第 4 款參照）。因此，代管業應與出租人簽訂委託管理住宅租賃契約書後，始得執行租賃住宅管理業務，並親自執行租賃住宅管理業務不得委託他代管業（租賃住宅管理條例第 28 條參照）。此模式乃代管業者收取代管費用後，負擔租賃住宅管理業務，出租人僅自負租金收益的盈虧，不須負擔房屋租賃交易成本。

（二）包租業

其指承租租賃住宅並轉租，及經營該租賃住宅管理業務之公司（租賃住宅管理條例第 3 條第 5 款參照）。故包租業應經出租人同意轉租其租賃住宅並與其簽訂租賃契約書，並於該契約書載明包租業與出租人之住宅租賃標的範圍、租賃期間及得終止租賃契約之事由後，始得刊登廣告及執行業務（租賃住宅管理條例第

¹¹² 曾義權，尋找台灣住宅市場中潛藏的鍊節－專業租屋企業，國立臺灣大學建築與城鄉研究所碩士班論文，頁 64-66，2002 年 6 月。

29 條第 1 項及第 2 項參照)，同時負擔租賃住宅管理業務及租金收益的盈虧，對出租人而言不但不須負擔房屋租賃交易成本且具有投資色彩。

另外，包租業以轉租作為經營模式，故與次承租人簽訂租賃契約書時，應提供住宅租賃標的現況確認書、包租業與出租人簽訂的租賃契約書及出租人同意轉租之書面文件，並於簽訂後三十日內，將該契約轉租標的範圍、租賃期間及次承人資訊以書面通知出租人（租賃住宅管理條例第 29 條第 2 項參照）。如遇出租人提前終止租賃契約者，包租業除應於知悉終止租賃契約之次日起五日內通知次承租人終止轉租契約，協調返還租賃住宅、執行屋況及附屬設備點交事務、退還預收租金及全部或一部押金外，並應協助次承租人優先承租其他租賃住宅（租賃住宅管理條例第 30 條參照）。

二、建立專業服務市場

（一）引進專業證照制度

對於租賃住宅服務業之管理人員，包含從事代管業務或包租業務之人員，要求參加全國聯合會所舉辦的資格訓練，並且測驗合格取得專業證照方可執業（租賃住宅管理條例第 3 條第 8 款、第 26 條及第 27 條參照）。目的確管理人員具備知識技能和瞭解法令規範，有效協助處理龐雜之租賃住宅管理事務，諸如：租賃住宅之屋況與設備點交、收租與押金管理、日常修繕維護、糾紛協調處理及其他與租賃住宅管理有關之事項（租賃住宅管理條例第 3 條第 6 款參照），解決住宅所有權人不願或無法釋出房屋至租賃市場之問題，如：管理成本高、無力管理等因素¹¹³。

（二）公司經營組織型態

另外，基於租賃住宅服務業內容之性質複雜屬於持續性服務，須以公司組織型態經營（租賃住宅管理條例第 19 條至第 24 條參照），並於營業處所與網站應揭示

¹¹³ 立法院公報處(2017)，〈立法院第 9 屆第 4 會期第 7 次會議紀錄〉，《立法院公報》，第 106 卷 第 90 期，頁 268。
https://lci.ly.gov.tw/LyLCEW/communique1/final/pdf/106/108/LCIDC01_10610801_00007.pdf（最後瀏覽日：11/03/2018）

合法執業證明文件資訊，包含：登記證、同業公會會員證書、租賃住宅管理人員證書(租賃住宅管理條例第 33 條第 1 項參照)。基於代管業之性質，代管費用收取基準及方式亦應揭示(租賃住宅管理條例第 33 條第 2 項參照)。須注意的是，租賃住宅服務業應僱用具備租賃住宅管理人員資格者從事租賃住宅服務之業務(租賃住宅管理條例 25 條參照)，以確保專業化永續經營及服務品質¹¹⁴。因此，透過具備專業與規模之公司管理經營，有助於消化房東之房屋租賃交易成本，使閒置的房屋資源有效投入租賃住宅市場。

(三) 確立服務業務內容

租賃住宅服務業負有指派專任租賃住宅管理人員於相關業務文件簽章義務，包括：屋況與附屬設備點交證明文件、租金、押金及相關費用收據、退還租金、押金證明(租賃住宅管理條例第 32 條第 1 項參照)。另外，因代管業與包租業之性質不同，前者之委託管理住宅租賃契約書與後者之租賃契約書與住宅租賃標的現況確認書，分別皆須專任租賃住宅管理人員之簽章(租賃住宅管理條例第 32 條參照)。以促使業務人員履行應注意義務，以保障租賃住宅服務當事人權益及落實專業服務品質。

三、 規範服務市場責任

(一) 損害賠償

因可歸責於租賃住宅服務業之事由不能履行契約，致租賃住宅服務當事人受損害時，由該租賃住宅服務業負賠償責任(租賃住宅管理條例第 31 條第 1 項參照)。租賃住宅服務業因其受僱人執行業務之故意或過失致租賃住宅服務當事人受損害者，該租賃住宅服務業應與其受僱人負連帶賠償責任(租賃住宅管理條例第 31 條第 2 項參照)。租賃住宅服務當事人求償無助時，得轉向全國聯合會於該租賃住宅服務業繳存營業保證金及提供擔保總額內請求代為賠償。(租賃住宅管理條例第 31 條第 3 項參照)

¹¹⁴ 立法院公報處(2017)，前揭註 113，頁 268。

(二) 行政監督

租賃住宅服務業應於每季結束後十五日內，將其受託管理、承租或轉租租賃住宅之相關資訊，定期報送主管機關(租賃住宅管理條例第 34 條參照)。另外，如遇主管機關檢查租賃住宅服務業之業務時，租賃住宅服務業不得規避、妨礙或拒絕(租賃住宅管理條例第 35 條參照)。違反者，依租賃住宅管理條例第 37 條及第 38 條之規定分別受主管機關罰鍰，並限期改正。

第三項、小結

綜合上述，住宅租賃契約除有《民法》及《土地法》適用，亦有新條例《租賃住宅管理條例》適用，且以其為特別法優先適用。初步觀察新條例之立法特色可以發現其主要致力於保障當事人雙方權益及健全租賃住宅市場發展兩大面向，以降低租賃交易成本為手段，達到維護人民居住權益的立法目的。

在保障當事人雙方權益之部分，除了調整過去法律適用的問題，以貼合現實交易的運作外，並且嚴格管控契約內容，平衡住宅租賃契約當事人之權利義務關係。而在健全租賃住宅市場發展之部分，則以建構租賃住宅服務業之管理制度為主要內容。然而，細觀新條例內容可以窺探立法政策的態度，包含：租賃人格性的強化、租稅優惠的賦予，似仍以鼓勵發展租賃住宅服務業為重，對於承租人權益的保障反而沒有特別著墨。值此，其對於承租人居住權益的保障的貢獻為何，不免令人懷疑。由此觀之，從整體住宅租賃政策方向，承租人在權利義務關係並無享有特別保護，新法反而限制承租人轉租之權利，實非妥適。至於，新法對於未來整體租賃住宅市場發展的成效為何，由於施行不久，則尚須觀察。

第四章 資訊地位平等

第一節 資訊充分的締約環境

在正常的住宅租賃契約關係，首要面對的是處理資訊地位落差之問題。為彌平資訊取得不對等，要求當事人在締約契約開始接觸、準備或磋商時，因兩造進入特殊信賴關係，對於重要資訊義務存有說明、告知及保護義務。所謂的信賴，實然是對於出租人的角色期待、廣告資訊主動提供等所創設的信賴基礎，值此承租人的利益在合理的主觀信賴，應受保護¹¹⁵。此義務存立的目的是在於維護個人自主，是實現私法自治的手段。但仍須注意義務要求的範圍，避免過分限制私法自治的問題，造成出租人之權利限制不符合比例原則。

然而，目前《民法》及《土地法》並無特別處理資訊地位落差之規定，僅租賃住宅管理條例第 13 條第 1 項之規定涉及住宅租賃資訊廣告的問題，明文出租人提供之租賃住宅廣告內容應與事實相符，來保障當事人雙方之權益。

第二節 廣告內容真實

第一項、立法目的

一、現行規制基礎

在住宅租賃契約締約階段，出租人若主動告知或經詢問提供正確的交易資訊，不論以何種形式：口頭、書面或者廣告，是有助於承租人作出理智且正確的交易。但出租人若有虛偽不實或引人錯誤時，法律應有保護承租人之必要，以符合私法自治及當事人自主原則精神。遍查民法，承租人得視契約成立與否分別主張因受詐欺撤銷意思表示（民法第 92 條參照）與締約上之過失責任（民法第 245 條之 1 參照），以獲得救濟機會。另外，亦有瑕疵擔保責任與債務不履行之主張，自不待言。

二、現行規制困境

¹¹⁵ 楊宏暉，對預售屋廣告的契約期待與保護，財產法暨經濟法，第 25 期，頁 72-74，2011 年 3 月。

惟如今廣告成為現實交易出租人提供租賃住宅資訊吸引承租人的主要方式，同時也是承租人取得租賃住宅資訊並決定是否租賃之重要依據。鑑於廣告不僅是傳播資訊的工具，可以降低雙方蒐尋資訊的交易成本，更是開啟雙方交易接觸的關係(geschäftlicher Kontakt)，但若當事人間存在資訊地位不對稱，可能導致一方憑藉自身資訊的優勢，遂行投機行為影響對造的交易決定，基於誠信原則，有要求他方落實資訊揭露正確的義務¹¹⁶。

但是，針對出租人廣告虛偽不實或引人錯誤所生之責任，民法現行規定尚難提供充分的規範。除了現行民法規定的要件適用多為困難及狹隘，如：民法第 245 條之 1 第 1 款之規定適用前提限於「對他方之詢問」，並不包含「主動告知」的情形，同條第 3 款之規定「其他顯然違反誠實及信用方法者」縱然得概括補充「主動告知」的情形，但本條必須「契約不成立」時方得適用，若因不實廣告而成立契約者，即無從適用該規定¹¹⁷；民法第 92 條之規定撤銷意思表示，須舉證意思表示的作成與詐欺行為具有因果關係，在主觀要件的要求之下，尚須證明對造具有故意，由於承租人通常不易證明，導致責任成立不易¹¹⁸。

再論契約責任部分，出租人常以不同於廣告內容之契約內容作為約定，或者以不完整的廣告資訊引人錯誤，造成瑕疵擔保責任與債務不履行責任範圍不及廣告內容。故考量廣告特性及避免租賃住宅廣告不實導致承租人權益受損，租賃住宅管理條例第 13 條第 1 項參照消保法第 22 條之規定出租人提供之租賃住宅廣告內容應與事實相符，希冀透過民事的契約責任減輕主觀要件的舉證責任並補充瑕疵擔保責任與債務不履行責任的保護範圍。

另外，考量媒體經營者對社會具有一定影響力，承租人恐因媒體之廣告而為承租，故媒體經營者受託刊登租賃住宅廣告時，對於廣告之租賃住宅面積、屋齡、

¹¹⁶ 曾明遜、陳明燦，預售屋不實廣告責任之法律經濟分析，公平交易季刊，第 14 卷第 3 期，頁 8、21，2006 年 7 月。楊宏暉，前揭註 115，頁 38-39。

¹¹⁷ 王澤鑑，前揭註 36，頁 268-278。

¹¹⁸ 謝宗憲，不實廣告法律責任之研究－以預售屋廣告為中心，公平交易季刊，第 23 卷第 1 期，頁 69-71，2015 年 1 月。

樓層別及法定用途等重要資訊，應負查證責任¹¹⁹。倘承租人因信賴該廣告而受有損害，並與出租人負連帶賠償責任(租賃住宅管理條例第 13 條第 2 項參照)。

第二項、立法政策-以填補損害為主

一般而言，因信賴該廣告致受損害，如何獲得填補救濟是承租人最為關切的問題，故對於出租人違反廣告真實義務之責任，立法裁量上與其課予高度公益色彩之行政責任，更著力於民事責任的部分¹²⁰。因此，除了租賃住宅服務業涉及影響交易市場秩序較大，課予行政責任維持一定程度嚇阻作用，以維護不特定承租人之利益外，其餘個別出租人僅負民事責任(租賃住宅管理條例第 37 條第 1 款參照)。

另外，針對媒體經營者責任，參考行政院草擬版本第 34 條之規定：「受託刊登住宅租賃廣告之媒體經營者違反第七條第二項規定，刊登與事實不符之住宅租賃廣告者，由直轄市、縣（市）主管機關處新臺幣三千元以上一萬五千元以下罰鍰，並限期改正；屆期未審酌受託刊登住宅租賃廣告之媒體經營者違反本條例規定應受非難程度，及對當事人所生影響，爰明定受託刊登住宅租賃廣告之媒體經營者違反本條例相關規定應處三千改正者，按次處罰。」原本課予行政責任現實版本則改為使其與出租人負連帶民事責任，原因為何，立法院之院會記錄並無記載。試以探究，可能考量為了增加承租人損害獲得彌補的機會，要求媒體經營者與出租人負連帶民事責任。在觀察過去立法趨勢，如：消保法第 23 條第 1 項及公平交易法第 21 條第 5 項之規定，此乃立法者一貫的立法政策。

第三項、立法分析

所稱廣告，一般指利用電視、廣播、影片、幻燈片、報紙、雜誌、傳單、海報、招牌、牌坊、電腦、電話傳真、電子視訊、電子語音或其他方法，可使多數人知悉其宣傳內容之傳播(消保法施行細則第 23 條參照)。出租人透過廣告傳達之

¹¹⁹ 朱柏松，論廣告媒體業者之損害賠償責任兼評最高法院九十年度台上字第二二七號判決，月旦法學雜誌，第 91 期，頁 15-17，2002 年 12 月。

¹²⁰ 謝宗憲，前揭註 118，頁 82。

內容應與事實相符，然而出租人違反真實義務時，是否當然負民事契約責任，並非無疑。查立法理由，租賃住宅管理條例第 13 條之規定乃參照消保法第 22 條之規定增訂，似可援引過去學說與實務針對消保法第 22 條之論述參考¹²¹。

一、廣告為要約之引誘

要約之引誘，在於引誘他人向其要約並未發生法律效果，與要約以訂立契約之目的有別¹²²。有時兩者概念於現實生活難以分辨，大致以相對人涉及範圍與內容之具體程度等交易習慣為判斷因素¹²³。因此，要約對象越是特定，內容越是具體，似應認為要約，反之則為要約之引誘。廣告是出租人吸引承租人之工具，接受廣告資訊之相對人不為特定，且契約內容，如：租金、租期，尚待當事人具體約定，故應為要約之引誘。再者，將廣告逕自認定為要約，無意使出租人承擔因履約能力不足而負債務不履行之風險，實非妥適¹²⁴。實務上，針對相似規定，消保法第 22 條企業經營者刊登廣告的解釋認定上，除早期曾有認定為要約之性質外，大多認為屬於要約引誘之性質^{125、126}。換言之，租賃住宅管理條例第 13 條第 1 項之規定刊登租賃廣告屬相同之行為，性質認定應無不同。

二、廣告成為契約內容之條件

既然廣告之性質為要約之引誘，究竟出租人違反廣告內容真實義務時，如何構成民事契約責任，有必要進一步探討。一般而言，民事契約責任應回歸當事人

¹²¹ 立法院公報處(2017)，前揭註 113，頁 299-300。

¹²² 王澤鑑，前揭註 36，頁 174-175。

¹²³ 王澤鑑，前揭註 36，頁 175。黃立，民法債編總論，元照，頁 59，2006 年 11 月 3 版。

¹²⁴ 陳忠五，不誠實廣告與夾層屋買賣契約－實務上相關判決之綜合評釋(下)，台灣本土法學雜誌，第 3 期，頁 73，1999 年 8 月。

¹²⁵ 最高法院 89 年度台上字第 746 號判決認為：「預售屋既無何成品可供實際之檢視，建商以廣告內容誘發客戶預購房屋之動機，且以廣告內容與購屋人洽談該屋之性質，該廣告之說明及樣品屋示範應成為契約內容之一部。準此，企業經營者刊登廣告為『要約』之性質，並非『要約引誘』。」最高法院 90 年度台上字第 1404 號判決相同意旨。

¹²⁶ 最高法院 92 年度台上字第 906 號「……惟查出賣人將廣告平面圖放置於售屋現場供人取閱，固屬契約之引誘，然買受人受此要約之引誘後，進而與出賣人之使用人洽談買賣；出賣人之使用人並依據該平面圖向買受人解說，表示買賣房屋之空間、隔局按該平面圖所示，買受人因該平面圖所示之空間、隔局而決定簽約訂購，即足認定該平面圖所示房屋之空間、隔局等項，確已成為買賣雙方合致之意思表示，該平面圖自屬契約之一部分。」最高法院 92 年度台上字第 2694 號及 95 年度台上字第 2192 號判決同旨。

意思表示合致之內容，待廣告內容成為契約內容之一部，方可追究。換言之，契約以廣告為契約內容約定，若廣告與事實不符，出租人自應負責，反之，若契約未提及廣告為契約內容之一部，縱使與事實不符，出租人似毋庸負責。但如此解釋，將架空本條立法目的，故如何緩和此部分使廣告在一定條件下，自然構成契約之一部，以填補對於承租人保障之不足，為實務重要問題。

參考消保法第 22 條之適用，多數學者與實務見解，皆提出構成契約內容之廣告須客觀上作為雙方洽談締約的基礎，並且具體明確說明給付內容，排除單純市場的宣傳手法，主觀上相對人合理信賴該廣告內容將會實現^{127、128}。同理，適用於出租人違反廣告內容真實義務時，亦應視承租人主觀上是否有合理信賴，客觀上廣告內容是否具體明確，雙方當事人是否持廣告內容進行磋商，始能透過契約請求履行賠償責任。質言之，若雙方當事人針對廣告內容並無說明、洽談使之成為具體之「要約」或無合理信賴廣告內容時，則非契約內容之一部，自不得請求賠償。

三、廣告不得約定僅供參考

誠如前述，發生廣告與事實不符時，倘若當事人在締約初期以廣告內容作為洽談基礎，並將出租人提供之廣告內容明確具體化，承租人亦具有主觀合理信賴時，出租人則須承擔民事契約責任。但是否可藉由契約明確約定，「廣告僅供參考」以排除法律責任，似有疑問。在租賃住宅管理條例第 13 條第 1 項之規定所授權公布之《住宅租賃契約應約定及不得約定事項》明文，「不得約定廣告僅供參考」為應不得約定事項。違反者，該條款無效。由此觀之，立法者防堵出租人躲避廣告真實義務不遺餘力。但如前文所述(第三章第三節第一項、三、(二)嚴密管制契

¹²⁷ 陳忠五，前揭註 124，頁 74。曾品傑，論不動產不誠實廣告之契約效力(上)－最高法院相關判決評釋，台灣本土法學雜誌，第 81 期，頁 71-88，2006 年 4 月。謝宗憲，前揭註 118，頁 76-78，2015 年 1 月。

¹²⁸ 最高法院 91 年度台上字第 1387 號判決：「按八十三年一月十一日公布施行之消費者保護法第二十二條明定企業經營者應確保廣告內容之真實，其對於消費者所負之義務不得低於廣告內容。是企業經營者與消費者間所訂定之契約，雖未就廣告內容而為約定，惟消費者如信賴該廣告內容，並依企業經營者提供之訊息進而與之簽訂契約時，企業經營者所負之契約責任自應及於該廣告內容。」

約的質疑)，逕自認定無效，無異剝奪了當事人談判磋商的機會，手段是否妥適有待思量。

第三節 資訊主動揭露

第一項、法理基礎

在資訊地位不對等情形下，當事人為締約契約而接觸、準備或磋商時，因兩造進入特殊信賴關係，對於重要資訊義務存有說明、告知及保護義務，是誠信原則的具體實踐，此又稱之為「先契約義務」¹²⁹。實際上，有關住宅租賃的交易資訊除了坪數、格局、樓層及區域環境機能外，尚有其他租賃物資訊，諸如：凶宅、輻射、海砂屋及漏(淹)水等，並無法期待出租人於締約階段或廣告中主動揭露所有內容。為了確保雙方資訊在對等狀態，並防止出租人濫用交易資訊的優勢地位，以降低承租人錯誤的交易風險，除了消極禁止出租人提供不實資訊或廣告外，對於交易上重要事項在符合一定條件下，應有積極主動揭露義務，以貫徹資訊平等的理念。因此，承租人與出租人接觸、準備或磋商時，本於出租人角色的合理信賴，若有重要交易資訊是締約決定的基礎時，為保護相對人之權益，應為適當的揭露。

第二項、揭露範圍

在一般交易的狀態中，原則上一方並無主動提供資訊的義務，亦即當事人應本於追求最大利益的驅使下，自行承擔資訊收集不利的後果，此乃當事人自主原則的表現，更是私法自治的前提¹³⁰。在肯定出租人負有資訊揭露義務之前提，更重要的是如何決定出租人應揭露資訊的範圍，以避免出租人承擔義務過重，失去談判的空間。

¹²⁹ 王澤鑑，前揭註 36，頁 48-50。

¹³⁰ 楊宏暉，契約準備階段的資訊揭露與廣告規制—以我國法及德國法為中心，公平交易季刊，第 18 卷第 3 期，頁 61，2010 年 7 月。

學者提出以「資訊需求」與「資訊期待可能性」作為判斷標準¹³¹。所謂資訊需求是指當事人盡資訊蒐集勤勉義務後，對於締約決定有重大影響的交易資訊因取得難度過高，即有告知的義務¹³²。至於資訊期待可能性則指資訊的取得與揭露，基於揭露資訊義務人的專業與優勢得合理期待為之¹³³。透過此標準可以提供在個案適用之妥當性，同時提前揭示出租人應揭露的範圍，不致無法預見其何種作為或不作為構成義務之違反，實為住宅租賃契約關係可能存在的重要交易資訊提供標準方向¹³⁴。

第三項、請求權依據

在住宅租賃契約關係中，出租人對於租賃住宅的重要交易資訊相對於承租人享有優勢地位。對於承租人而言，若須自行蒐集全部的租賃住宅的資訊，將使整體交易成本大幅提升，實不利提振租賃住宅市場。但由於現行民法尚無針對住宅租賃關係資訊主動揭露的明文，對於其他影響締約決定的重要交易資訊，在《租賃住宅管理條例》亦未列入規定須主動揭露，學者認為對於資訊揭露的保障稍嫌不足¹³⁵。因此違反義務者，應視個案情況回歸民法適用。

一、故意違反揭露義務

資訊優勢之出租人若明知或可得而知具有交易重要事項告知之義務而未告知，致影響當事人的決定自由。依最高法院 33 年上字第 884 號判例：「民法第九十二條第一項所謂詐欺，雖不以積極之欺罔行為為限，然單純之緘默，除在法律上、契紙上或交易之習慣上就某事項負有告知之義務者外，其緘默並無違法性，即與本條項之所謂詐欺不合。」換言之，負有告知之義務而緘默仍屬詐欺，得主張撤銷以排除契約效力。又一般意思表示自由受詐欺，相當於故意以背於善良風俗之

¹³¹ 楊宏暉，加盟業主先契約資訊揭露義務之建構，政大法學評論，第 144 期，頁 252，2016 年 3 月。

¹³² 楊宏暉，前揭註 131，頁 252-253。

¹³³ 楊宏暉，前揭註 131，頁 254-257。

¹³⁴ 大法官釋字第 432 號、第 521 號、第 617 號、第 623 號、第 633 號、第 697 號、第 702 號解釋。

¹³⁵ 陳冠甫，前揭註 97，頁 53。

方法加損害於他人之侵權行為，得依回復原狀原則，請求廢止契約¹³⁶。

二、過失違反揭露義務

出租人非故意而未告知，致間接影響當事人的決定自由時，則成立締約上過失。但如前文所述，由於民法第 245 條之 1 規定適用狹隘，對於承租人的保障實在有限。現行方法，透過《住宅租賃契約應約定及不得約定事項》將住宅租賃的重要交易資訊作為租賃標的現況確認內容，鼓勵當事人簽訂契約時揭露租賃物資訊及住宅租賃的相關事務，避免過失未告知的情形，以補足保障的缺漏。然而，此仍無法避免當事人無瑕疵擔保或不完全給付適用的可能，參照《住宅租賃契約應約定及不得約定事項》有關租賃物揭露資訊，如果當事人依照清單詳實填寫，透過瑕疵擔保責任與債務不履行，得以保護承租人利益。然而，目前採取開放式問答並非完全強制，倘雙方當事人對於租賃物揭露資訊皆未確認、檢查，當事人對其陳述亦未加以擔保，更未作為契約成立後應該履行之債務內容，這時可能產生保障漏洞。因此，若能夠修訂民法第 245 條之 1 使得貼合締約上過失理論，將「契約成立後」之情形納入，並放寬主觀歸責要件，則將使得當事人因資訊落差可能導致損害獲得更全面的法律保護，不致產生保障缺漏。

第四節 小結

在正常的住宅租賃契約關係中，出租人相較於承租人在交易地位有資訊優勢。鑑於過去民法上以出租人主觀故意歸責為基礎的救濟方法，尚難充分保障承租人權益。再者，民法第 245 條之 1 規定偏離「先契約義務」理論的架構，更使資訊充分的締約環境難以建立。故租賃住宅管理條例第 13 條第 1 項之規定要求出租人所提供之廣告應與事實相符，否則出租人違反廣告事實義務時，則須承擔民事契約責任。並且透過《住宅租賃契約應約定及不得約定事項》將住宅租賃的重要交易資訊作為租賃標的現況確認內容，鼓勵當事人簽訂契約時揭露租賃物資訊

¹³⁶ 王澤鑑，意思表示詐欺與侵權行為，法學叢刊，第 23 卷第 4 期，頁 2-5，1978 年 12 月。王澤鑑，民法學說與判例研究第二冊，自版，頁 215-220，2009 年 12 月。

及住宅租賃的相關事務，藉瑕疵擔保責任與債務不履行責任，以承擔「彌平資訊地位平等」的任務。惟若能夠修訂民法第 245 條之 1 使得貼合締約上過失理論，將「契約成立後」之情形納入，並放寬主觀歸責要件，則在雙方當事人對於租賃物揭露資訊皆未確認、檢查，當事人對其陳述亦未加以擔保，更未作為契約成立後應該履行之債務內容之情形發生時，當事人仍然獲得保護，不致產生保障缺漏。另外，建立資訊充分的締約環境，雖然造成出租人之權利限制，但此項要求卻是為了符合私法自治得以持續運作，並且透過承租人之主觀信賴作為出租人資訊義務提供的範圍界限，不致不符合比例原則。



第五章 經濟地位平等

第一節 收入水準與居住對價相稱

第一項、管制的必要原因

依照居住權益的保障內涵包含「支付的對價與收入水準相稱」，故國家除了著手建構資訊充分的締約環境以保障承租人之居住權益，有必要使承租人「住得起」，否則縱使擁有良好的締約環境，支付能力不足亦是枉然。但租金的管制是否必要及能否達到政策目的，一直是爭論不休的問題。

租金的管制影響層面甚廣，對於出租人、投資人等利害關係人而言，租金利潤減少，可能間接造成整體經濟市場負面影響，包含：租賃住宅品質低落、投資客退出租賃住宅市場及地下交易盛行等¹³⁷。單就金錢、物質利益之經濟分析，對於社會的效益而言，租金的管制看似未能經得住考驗，甚至對契約自由干涉程度過重，不符合憲法保障私法自治之意旨。但整體而言加入非金錢之利益以外之重要決定影響因素，包含使承租人享有穩定的居住環境、減少貧窮及無家可歸的社會成本等其他道德、政治及社會因素，與管制成本等負面影響相比，則有不同結果¹³⁸。由此觀之，此乃租金管制為何不符合自由經濟卻仍需要存在的關鍵原因。又，現實交易常以押租金作為履行租賃債務之擔保，為避免押租金成為規避租金管制的出口，故有一同受限制的必要。

第二項、管制的手段選擇

租金的管制雖然不符合經濟學理念，但從整體社會觀察可能帶來更多其他金錢物質無法衡量的效益，故對於出租人之收益權限產生限制，但只要出租人可以獲得合理的利潤，仍然在容許的範圍。再者，我國依照土地使用種類與使用性質進行管制屬於合憲，依舉重明輕的法理，租金的管制應為憲法所許¹³⁹。不過，此

¹³⁷ 王鴻源、林鼎鈞，我國租金管制問題之研究，土地問題研究季刊，第4卷3期，頁130-131，2005年9月。

¹³⁸ 謝哲勝，房租管制法律與政策，五南，頁148-151，1996年9月。

¹³⁹ 大法官釋字第444號解釋。

項涉及對契約內容的事前管制，屬於高度干涉私法自治的手段，故在適用的範圍必須節制。此外，租金管制實為「居住權保障」與「財產權保障」利益衡量下之結果，並依憲法第 23 條法律保留原則與比例原則應有所限制，避免「禁止保護不足」與「禁止過度侵害」，如前文所述(第二章第三節二、合適的手段標準)。

租金管制的手段，可以是總額的管制，亦可是每年調漲租金的幅度¹⁴⁰。並且，應根據租賃住宅市場的情形，衡量承租人須加以保護的程度，決定是否採行房租管制。但須注意的是，若租金管制剝奪出租人合理收益之範圍造成財產權之侵害時，則應適時給予補償，方符合憲法保障人民權利之意旨。而在押租金之部分，則應避免額度的限制損及擔保之目的。

第三項、租金

一、租金管制規定

(一) 適用客體

在民法除了規範租金的支付，不以金錢為限外(民法第 421 條第 2 項參照)，並無租金管制規定。僅於土地法第 97 條有租金管制之規定，依土地法第 97 條第 1 項之規定：「城市地方房屋之租金，以不超過土地及其建築物申報總價年息百分之十為限。」是保護經濟上弱勢的承租人，確保能取得居住空間及避免居住問題。

1. 房屋

所稱之房屋，依內政部函釋指供「住宅使用」的建築物¹⁴¹。另，依最高法院 54 年台上字第 1528 號判例：「市場攤位之承租人，不僅在其承租之攤位得以營商，並得享受整個市場之特殊利益，其應付租金不僅為使用攤位之對價，且包括此項特殊利益之對價在內，自非普通之房屋兼土地之承租可比，固不受土地法第九十七條及實施都市平均地權條例第四十八條(舊)所定，房租及地租最高限制之拘束。

¹⁴⁰ 鄭惠佳，對我國不動產租金管制法律規定之建議，真理財經法學，第 2 期，頁 223，2009 年 3 月。

¹⁴¹ 內政部 71 年 5 月 22 日台內字第 87103 號函：「土地法第 97 條所稱「房屋」，係指供住宅用之房屋而言。」。

¹⁴²」換言之，本條之房屋租賃是以住宅使用為目的之建築物，與《租賃住宅管理條例》所稱之租賃住宅，並無不同。

然而過去實務在適用本條持有不同見解，若出租人單純將房屋之店面租與營商，不負責市場之經營管理及場內秩序與衛生之維持時，仍有土地法第 97 條之規定適用¹⁴³。換言之，本條所言之「房屋」意義較「租賃住宅」範圍廣。但從土地法第三章乃至於本條之規範目的，在於保護經濟弱勢之承租人，避免無所可居，營業用房屋，承租人用以營業獲取利潤並非供居住，其應付租金不僅為使用房屋之對價，且包括享受商業利益之對價在內，當非一般住宅用房屋之承租可比，無立法限制租金額度之必要，此是目前實務及學界通說^{144、145}。另外，從土地法第 94 條及第 96 條之體系觀察皆以「自住之房屋」為規範客體，亦可得到相同結論。相對而言，若肯定凡以房屋作為租賃物即有適用，則將過分侵蝕私法自治，非但不利整體市場經濟，對出租人之財產權及契約自由亦有過度侵害之疑慮，故本條解釋方法上不論是採目的性限縮或是限縮解釋，結論皆以居住使用的建築物為限，並無不同¹⁴⁶。

¹⁴² (73)廳民一字第 0672 號復台高院函：「土地法第九十七條之立法用意在保護經濟上弱者，即無房屋居住之小市民。某財團將其興建之大樓共有權持分出售保持共有不得分割，得款後，又向買受人承租，然後分層、分間或分攤位轉租他人經營各種生意，收取高額之租金。該大樓本為經營各種商場之用，與一般市場攤位無異。而市場攤位之承租人，不僅在其承租之攤位得以營商，且得享受整個市場之特殊利益。其應付之租金，包括使用攤位之對價及此項特殊利益之對價在內，非普通房屋兼土地之承租可比，自不受土地法之限制(五十四年台上字第一五二八號判例參照)。若該財團得享受土地法限制租金之利益，不但助長不勞而獲，且將迫使房地共有人廉價出售房地共有權與該財團，形成經濟以大吃小之怪現象。」採同見解。

¹⁴³ 最高法院 72 年度台上字第 4278 號判決：「本院五十四年台上字第一五二八號判例，係就市場經營者將市場攤位租予承租人之情形而為釋示，意謂市場經營者不惟提供攤位於承租人營商，並負責該市場之經營管理及場內秩序與衛生之維持，此與本件上訴人單純將房屋之店面租與被上訴人營商之情形，尚屬有間，即不得援例主張。」最高法院 76 年度台上字第 712 號、84 年年度台上字第 2069 號判決同旨。

¹⁴⁴ 最高法院 94 年度第 2 次民事庭會議決議：「城市地方供營業用之房屋，承租人得以營商而享受商業上之特殊利益，非一般供住宅用之房屋可比，所約定之租金，自不受土地法第九十七條規定之限制。」最高法院 107 年度台上字第 1940 號、107 年度台上字第 988 號、105 年度台上字第 727 號、104 年度台上字第 152 號、102 年度台再字第 33 號、102 年度台上字第 912 號、102 年度台上字第 755 號判決同旨。

¹⁴⁵ 王錦村，土地法實用，自版，頁 416，1984 年 6 月。李鴻毅，土地法論，自版，頁 463，1984 年 5 月增訂 8 版。溫豐文，土地法，自版，頁 308，2013 年 3 月修訂版。

¹⁴⁶ 吳從周，民法上之法律漏洞、類推適用與目的性的性限縮，東吳法律學報，第 18 卷第 2 期，頁 130-135，2006 年 12 月。

2.城市地方

(1)定義

租金管制既然限於「城市地方之房屋」，但是針對「城市」定義為何，《土地法》並無定義。由於「城市」規模、標準不一，判斷上過於空泛，容易造成適用上之疑義。依司法院院字第 2462 號解釋，指：「土地法第三編第二章所謂市地，為市行政區域內之土地，同法第一百四十八條第一項規定甚明，故通俗所謂市鎮，不在市行政區域內者，不包括在內。」似僅指「市行政區域內」之土地。然而，依法務部函釋認為從土地法第 96 條及第 97 條之規定觀察，是以直轄市或縣（市）政府並稱之，故不以市行政區域為限，尚包含「縣行政區域」內之土地，最高法院決議從之^{147、148}。亦有行政機關及學者認為是指依法實施都市計畫的地方，對此項見解區分標準較為客觀，宜採之^{149、150}。

(2)非城市地方應無類推適用的空間

《土地法》所施行的租金管制是以城市地方的租賃住宅為限，並非整體租賃住宅市場適用。但有學者認為在非城市地方，應有類推適用的必要，理由在於立法者制定租金管制主要處理城市的居住問題，對於非城市地方並未意識亦有租金過高的問題而造成漏洞，故基於保護承租人之必要，實應類推適用彌補漏洞¹⁵¹。惟所謂類推適用，為法律漏洞的填補手段，係指在存有法律漏洞的前提下，本於

¹⁴⁷ 前司法行政部(今法務部)44 年 5 月 26 日台(44)台令公參字第 2875 號令：「土地法所稱之『城市地方』，在有關法令及解釋中均無確定之意義可尋，自係依通常觀念指與村地方相對之稱謂而言。且城市地方，亦非必限於指行政區域之市區，此觀乎該法第 96 條，第 97 條均以『市縣政府』併稱即可推之(現今改稱直轄市或縣（市）政府)，因之鄉與鎮自可認為鄉村地方與城市地方之對比，原呈所舉之鎮，似應認為該法所指之城市地方。土地法第 97 條第 1 項即以是否超過土地及其建築物申報總價額若干為其限制標準，依理論解釋，自當以曾辦土地及其建築物總價額之申報為先決要件，凡合於此要件之區域，即有其適用，似不限於有無都市計劃之存在。又非城市地方即不合於法定條件，似難援照該條辦理。」

¹⁴⁸ 最高法院 54 年度第 1 次民、刑庭總會會議：「土地法第九十七條所稱之城市地方係指市縣行政區域而言，凡在市縣行政區域內者，即有其適用，其未辦理申報地價者，依立法旨趣，法院自得依當地政府評定地價為計算標準。」

¹⁴⁹ 行政院 44 年 7 月 14 日台(44)內字第 4380 號函：「該省為實施都市平均地權條例區域，所謂城市地方之範圍，應依該條例第三條之規定，原呈所稱之頭城鎮無都市計畫不得視為城市地方。」

¹⁵⁰ 吳啟賓，前揭註 34，頁 96-98。謝哲勝，前揭註 138，頁 10。

¹⁵¹ 吳從周，前揭註 146，頁 135。

相類似事務為相同處理的法則，給予事務相似的法律評價¹⁵²。而法律漏洞，是指法律問題本身依法律規範，應規範而疏未規範而言，倘若基於立法政策有意不為規範，則非屬漏洞¹⁵³。立法者之所以將租金管制規範對象以城市地方的租賃住宅為限，是為了避免影響整體租賃住宅市場過劇，並根據租賃住宅市場的情形，調整承租人保護程度，屬有意不為規範，非屬法律漏洞。退步言之，縱使認為存有法律漏洞。城市地方與非城市地方兩者市場條件有異，是否比附援引適用同樣額度的租金管制，實有疑問。因此，對於非城市地方應無類推適用的空間。

(二) 租金最高額度

依土地法第97條之規定所謂土地及建築物之總價額，「土地價額」依法定地價，「建築物價額」依該管直轄市或縣（市）地政機關估定之價額(土地法施行法第25條參照)。

1. 土地價額

有關土地價額是依法定地價而定。所謂法定地價，指土地所有權人依土地法所申報之地價(土地法第148條參照)。土地所有權人聲請登記而不同時申報地價者，以標準地價為法定地價(土地法第158條參照)。所稱標準地價，指直轄市或縣（市）主管機關依最近一年之土地買賣價格或收益價格調查結果，劃分地價區段並估計區段地價後，提交地價評議委員會評議，所計算宗地單位地價之結果。(平均地權條例第15條參照)。

須注意的是，土地所有權人未於公告期間申報地價者，或申報之地價未滿公告地價百分之八十時，得以公告地價百分之八十為其申報地價；反之，倘土地所有權人於公告期間申報地價，其申報之地價超過公告地價百分之一百二十時，以公告地價百分之一百二十為其申報地價(平均地權條例第16條參照)。

2. 建築物價額

對於建築物價額之計算，因《土地法》並無明文規定申報地價時一同估定建

¹⁵² 王澤鑑，法律思維與民法實例－請求權基礎理論體系，自版，頁 320-321，2011 年 8 月。

¹⁵³ 王澤鑑，前揭註 152，頁 302-304。

築物價額，造成適用上之疑義。內政部曾函釋，各級法院如基於城市地方房屋租金訴訟之需要，函請直轄市或縣（市）政府辦理建築物價額之估定案件，係依地價調查估計規則及依該規則第24條訂定之相關標準估計之¹⁵⁴。依此，近期實務則依循內政部函釋辦理，不再根據執行法院拍賣標購之價額或房屋現值作為計算基礎^{155、156}。

不過，實務仍有認為房屋稅稽徵機關依房屋稅條例規定評定之房屋現值與直轄市或縣（市）政府辦理建築物估定之價額相差無幾，而以房屋現值為準之見解¹⁵⁷。房屋現值與建築物之估定價額，前者為房屋稅的課稅基準，後者為房屋租金的計算基礎，不論是調查機關、評價委員會之組成抑或評定標準存有落差，以房屋現值逕自作為建築物價額之計算見解，不無可議（房屋稅條例及地價調查估計規則參照）。

（三）法律效果

雙方合意租金總額超過管制規定，依目前實務見解認定土地法第97條為強制

¹⁵⁴ 內政部 86 年 10 月 1 日台內地字第 8688351 號函：「各級法院如基於城市地方房屋租金訴訟之需要，函請直轄市或縣（市）政府辦理建築物價額之估定案件，直轄市或縣（市）政府應予受理。」

¹⁵⁵ 最高法院 86 年度台上字第 3382 號判決：「查原審既係依據土地法第九十七條第一項及土地法施行法第二十五條，城市地方房屋之租金以不超過土地及建築物申報總價額年息百分之十為限。所謂土地及建築物之總價額，土地價額依法定地價，建築物價額依該管市縣地政機關估定之價額等規定，作為計算不當得利之標準。乃原審就建築物價額部分，竟依被上訴人向執行法院拍賣標購之系爭房屋價額，作為計算上訴人所受相當於租金之利益之基礎，自有未合。上訴論旨，執以指摘原判決此敗訴部分不當，求予廢棄，非無理由。」

¹⁵⁶ 最高法院 95 年度台上字第 2857 號判決：「按土地法第九十七條第一項所謂土地及其建築物總價額，關於建築物價額，同法施行細則第二十五條規定，係依該管市縣地政機關估定之價額，而非申報課稅價額。原審逕以高雄市稅捐稽徵處新興分處所訂系爭房屋之課稅現值，作為被上訴人所受相當於租金損害之標準，亦不無可議。」

¹⁵⁷ 最高法院 87 年度台上字第 849 號裁定：「號末查土地法施行法第二十五條雖規定土地法第九十七條第一項所謂之建築物價額，係指該管市縣地政機關估定之價額。但法院斟酌實情，認課稅價額與地政機關估定之價額無異，爰在土地法第九十七條第一項所定年息百分之十限度內，命為給付損害金之判決，非當事人所得任意爭論多寡。原審斟酌系爭房屋坐落位置，利用價值及原約定租金等情形，認應按房屋課稅價額年息百分之十計算損害金，核無違背法令情事，附此敘明。」

規定，如當事人間約定之租金超過此限制，即對其超過部分無請求權¹⁵⁸。換言之，在直轄市或縣（市）政府得依標準減定之行政處分(土地法第 97 條第 2 項參照)，即得拒絕給付。另外，司法機關毋庸等待行政機關之處分確定亦得審酌，兩者並行不悖¹⁵⁹。

二、租金去管制化

(一) 土地法第 97 條之規定適用問題

1.租金管制計算基準失真

(1) 房地評定價值與市場價值存有落差

現今土地法第 97 條之規定制定迄今有七十餘年未修，逐漸延伸其他適用問題¹⁶⁰。其中租金的計算基準問題尤為重要。在實務上公告地價及房屋評定現值通常與市場價值存有差距，尤其是公告地價實在無法完全反映房屋收益價值。理由在於公告地價計算時間為每三年一次，無法反映市場價格的漲跌所致(平均地權條例第 14 條參照)。如此，將導致出租人的預期受益，二度受到侵害，恐怕不符合憲法保障財產權之意旨。

(2) 解決辦法

有論者建議可由公正之不動產估價單位或行政機關加以估定，以避免土地公告地價和房屋估定價值與市場價值差距太遠，發生難以計算合理報酬的缺失¹⁶¹。或者可以按土地之區位、地力等性質，依可供「使用」之種類決定「收益能力」，

¹⁵⁸ 最高法院 43 年台上字第 392 號判例：「土地法第九十七條第一項所定，『城市地方房屋之租金，以不超過土地及其建物申報總價額年息百分之十為限』，係屬強制規定，如當事人間約定之租金超過此限制，其超過部分無請求權。」最高法院 43 年度民、刑庭總會會議決議及 46 年度第 4 次民、刑庭總會會議決議同旨。

159 最高法院 59 年台上字第 793 號判例：「查房屋及基地之租金數額，按其地區於土地法第九十七條及修正實施都市平均地權條例第五十八條分別定有限制，當事人間約定之租金超過此限制者，其超過部分並無請求權，此與民法第四百四十二條規定因租賃不動產價值昇降關係聲請法院增減租額以不定期租賃為限之情形不同，且與行政機關強制減定前開超限租額，併行不悖，毋待於行政處分確定，即得審酌。」最高法院 70 年度台上字第 4336 號判決同旨。

160 立法院法律系統，土地法法條沿革，
<https://lis.ly.gov.tw/lglawc/lawsingle?00274763C61000000000000000003200000007000000^01150100052700^00114001001> (最後瀏覽日：12/23/2018)

¹⁶¹ 鄭惠佳，前揭註 140，頁 229。

故主管機關應先規定其「使用」種類，以決定其「收益能力」，俾利其「租金」之算定¹⁶²。不過，前者與現行評議委員會性質差異不大(地價及標準地價評議委員會組織規程參照)，後者則仍無正面回應如何避免計算基準與市場價值差距的問題。故學者建議可以採「土地公告現值」為計算基準，其計算方式與公告地價相似，但計算期間每年一次，相較於「公告地價」確實能夠與市場價值相近(平均地權條例第 46 條參照)¹⁶³。此種方式同樣可以考慮適用在房屋評定。但不論是採取何種方式，公告地價及房屋評定現值應以接近市場價格為宜。

2. 租金總額管制設定過高

目前租金管制為土地及建築物之申報總價額年息之百分之十，市場租金遠低於此上限，故對於承租人而言幫助實益不大¹⁶⁴。換言之，應重新檢視一般租賃住宅市場之投資人所應享有的合理利潤。另外，學者建議除了管制租金總額外，應增訂租金的漲幅限制，才能真正落實保障承租人之目的，避免透過租金調幅，迫使承租人搬離，喪失穩定居所的機會¹⁶⁵。此部分似可參考國外規定，定期市場檢討，規定以固定比例或配合消費者物價指數調整租金，此見解值得參考¹⁶⁶。

在《租賃住宅管理條例》擬訂前，立法委員曾提出《自用房屋租賃法草案》¹⁶⁷。該草案第 12 條之規定：「租金之調漲，限於主計處公布之物價指數距上次漲幅逾百分之四時，出租人始得調漲對應比例之金額。物價指數調降時，承租人亦得請求比例調降之。前項承租人之租金減免請求權，不得預先拋棄。」即以租金調幅的管制取代租金總額的管制，透過避免出租人惡意漲租，以保障人民居住之權益。

(二) 租賃住宅管理條例第 6 條

¹⁶² 陳明燦，城市房屋租金管制之簡析—兼評最高法院九五年臺上字第一九〇七號民事判決，台灣本土法學雜誌，第 92 期，頁 248，2007 年 3 月。

¹⁶³ 謝哲勝，前揭註 92，頁 281。

¹⁶⁴ 謝哲勝，前揭註 92，頁 271-272。

¹⁶⁵ 謝哲勝，前揭註 92，頁 272。

¹⁶⁶ 鄭惠佳，前揭註 140，頁 229。

¹⁶⁷ 立法院公報處(2015)，〈立法院第 8 屆第 7 會期第 11 次會議紀錄〉，《立法院公報》，第 104 卷 第 39 期，頁 268。
<https://lis.ly.gov.tw/lcggi/lypdf.txt?xddlcecacbc8c9cec9c7cecf81cecfcbcfccc6cfcec4cfcfcecfcc4cfcdc7cf> (最後瀏覽日：01/16/2019)

然而，依租賃住宅管理條例第 6 條之規定並無改善土地法第 97 條之規定適用問題，反而逕自排除適用，放棄了對租金的干預措施。查立法理由：「考量公告地價及房屋評定現值與市場價值仍有差距，無法完全反映房屋收益價值，且上開土地法規定僅規範城市地區之住宅，造成同樣為租賃行為，租金卻因地區不同而有差異。為避免影響出租人提供租賃住宅之意願，並尊重市場機制，爰定明予以排除適用。¹⁶⁸」本次修法使交易重新回歸自由經濟市場，得降低租賃住宅黑市存在，以及避免行政過度管制破壞市場秩序¹⁶⁹。然而，立法理由說明，仍有二點值得檢視：

(1)原則上，居住權益涉及人民基本的生活需求，是維持自身生命的最基本權利，若與生存權息息相關之居住權益皆無法享有，又如何享受財產權之保護，故居住權益享有優先的保護。但對於出租人財產之限制，亦須合比例原則。職此，針對城市與鄉村相比，屬於住宅供需容易失衡地方，自有實施管制必要，以落實保障承租人居住權益。因此租金因地區不同而有差異，則是必然結果，故立法理由謂：「土地法規定僅規範城市地區之住宅，造成同樣為租賃行為，租金卻因地區不同而有差異。」而排除，此理由不知所云。

(2)另外，針對公告地價及房屋評定現值與市場價值差距問題，如前文所述，學者提出許多解決辦法，以此為由而逕自排除適用，易造成承租人收入水準無法與市場租金相稱，而無處所可居。

綜上，有關租賃住宅管理條例第 6 條之規定非但未能解決土地法第 97 條之規定適用問題，甚至排除適用之理由過分牽強。試以探究，目前住宅租賃政策似乎急欲傾向優惠出租人以換取閒置住宅加入租賃住宅市場，希冀透過租賃住宅的大量供給，以量制價，降低租金額度，間接保障承租人的居住權益。不過，如此方式是否能夠有效吸引閒置住宅加入租賃住宅市場，會否目的不達反而造成現有租賃住宅市場哄抬價格，損及承租人有限之資源，不無疑問。整體而言，對於承租

¹⁶⁸ 立法院公報處(2017)，前揭註 28，頁 296。

¹⁶⁹ 陳冠甫，前揭註 97，頁 54。

人之居住權益保障稍嫌不周，並且完全與「收入水準與居住對價相稱」之內涵背道而馳。

三、租金調整

最後，由於住宅租賃契約屬於繼續性契約，法律關係存續期間偶有發生情事變更，對人民依契約所建立之生活秩序，難免發生影響。若嚴守原初約定之契約內容，尤其是租金給付的部分，恐怕導致一造當事人不利，故特別明文當事人得在一定法律要件下請求調整租金，是情勢變更原則的態樣之一，如前文所述(第二章第一節第三項、二、(四)情事變更原則)。其與租金管制的減定是源自居住政策管制手段概念不同¹⁷⁰。由於《土地法》及《租賃住宅管理條例》皆無租金調整的相關規定，則回歸民法第 442 條之規定適用。

(一) 要件

依民法第 442 條之規定：「租賃物為不動產者，因其價值之昇降，當事人得聲請法院增減其租金。但其租賃定有期限者，不在此限」所謂不動產價值之昇降，係指租賃物本身之價值，於租賃契約成立後有昇降者而言¹⁷¹。至於不動產價值昇降的原因為何，並非所問。另外，本條之規定限於不動產租賃且為不定期租賃型態，方有適用¹⁷²。應注意的是雖然不動產定期租賃無民法第 442 條之規定適用，但不得據此認定亦無民法第 227 條之 2 情事變更原則的適用¹⁷³。

(二) 方式

¹⁷⁰ 最高法院 48 年台上字第 1536 號判例：「當事人就不動產所訂之租金，於租賃關係存續中，因租賃物價值之昇降，固得聲請法院增減其數額，惟此項聲請，以租約未定期限者為限，倘定有期限，則不在准許之列，此觀民法第四百四十二條之規定自明。至約定之租金額數，因法律變更致超過法定限度以外者(例如房屋租金超過土地法第九十七條之規定，土地租金超過實施都市平均地權條例第四十二條規定)，關於超過部分，亦僅生請求權是否存在之問題，其與租賃物價值發生昇降之情形既非相同，自亦不得援用該條規定而為增減之聲請。」

¹⁷¹ 最高法院 26 年滬上字第 4 號判例：「民法第四百四十二條所謂價值之昇降，係指租賃物本身之價值，於租賃契約成立後有昇降者而言。」

¹⁷² 最高法院 47 年台上字第 1635 號判例：「租約既載明出租之房屋至反攻大陸時為止，雖係以不確定之期間為終止契約之時期，亦不失為定有期限之租賃關係，自不在適用民法第四百四十二條之規定聲請增減其租金之列。」高法院 48 年台上字第 1536 號判例同旨。

¹⁷³ 林誠二，前揭註 37，頁 416。邱聰智，前揭註 31，頁 351-353。

租金調整之性質屬於形成權，但非經一方意思表示即生調整效力，仍須透過聲請請求法院增減其租金，待判決確定方生效力¹⁷⁴。換言之，法院決定增減其租金以前，原約定之租金額，並不因租賃不動產價值之昇降，而失其拘束雙方當事人之效力¹⁷⁵。另外，契約當事人得就增減租金有特別約定，不因民法第 442 條之規定已有得聲請法院增減租金之規定而失其效力，或認於定期租賃不能有此約定¹⁷⁶。須注意的是既使當事人就增減租金有特別約定，但並不代表完全排除民法第 422 條之規定適用¹⁷⁷。而就當事人增減租金之約定，如果有符合約定的情事發生時，當事人即得直接依該約定增減租金，無待雙方另行協議或依民法第 422 條之規定訴請法院調整¹⁷⁸。

(三) 效果

1. 調整依據

一般而言，透過法院判決所決定之租金，依土地法第 97 條之規定可達土地及建築物之申報總價額年息之百分之十，但卻非謂必然達到最高額。法院除以基地申報地價為基礎外，尚須斟酌座落位置，工商業繁榮之程度，承租人利用之經濟

¹⁷⁴ 最高法院 98 年度台抗字第 384 號裁定：「依民法第四百四十二條規定請求調整租金，屬形成之訴，固應於法院為形成判決，以確定其增減之租金額後，當事人始得請求所增加租金之給付。惟基於訴訟經濟起見，倘當事人於該形成之訴合併提起給付租金之訴，即非法所不許。」

¹⁷⁵ 最高法院 47 年台上字第 1152 號判例：「租賃物為不動產者，因其價值之昇降，當事人固得依民法第四百四十二條聲請法院增減其租金，但在未聲請法院增減其租金以前，原約定之租金額，並不因租賃不動產價值之昇降，而失其拘束雙方當事人之效力。」最高法院 85 年度台上字第 2118 號、101 年度台上字第 809 號判決同旨。

¹⁷⁶ 最高法院 89 年度台上字第 1112 號判決：「又不動產租賃契約就增減租金所為之約定，並不因民法第四百四十二條已有得聲請法院增減租金之規定而失其效力，或認於定期租賃不能有此約定，果有合於增減租金約定之情事發生時，當事人即得直接依該約定方法增減租金，殊無待雙方之另行協議。」

¹⁷⁷ 最高法院 90 年度台上字第 269 號判決：「未定租賃期限之不動產，如契約當事人所約定之租金係隨不動產價值之昇降而機動調整者，原則上固無再請求法院准予調整租金之必要，惟倘遇稅額增加致所收租金不敷納稅，而稅額之增加又與不動產價值之騰漲有關係時，若仍不許增加租金，則出租人之出租該不動產，不但毫無收益，反將成為一種負累，自屬顯失公平，且與雙方約定「機動調整」之本意有違。」

¹⁷⁸ 最高法院 106 年度台上字第 730 號裁定：「未查未定期限之不動產租賃，如契約當事人已約定租金係按不動產價值之固定比率計算，則該不動產之價值倘有昇降之情事發生，當事人即得直接依是項約定增減租金，無待依民法第四百四十二條規定訴請法院調整。」

價值及所受利益，並與鄰地租金相等項比較，以為決定¹⁷⁹。換言之，租金調整並非謂租金必隨申報地價之變動而當然調整¹⁸⁰。另外，租金調整是處理租金額度的問題，並不因此改變給付種類¹⁸¹。

2.調整生效日

租金調整生效日為何，應視個案情形而定。通常生效日以判決確定日為基準，但不以此為限。若當事人與起訴前表明租金調整的意思表示並且未給付，判決效力可能溯及於判決確定前之期日¹⁸²。質言之，法院為准許調整之判決，當事人於起訴前，尚未按原約定租金額給付或受領給付者，得自調整租金之意思表示時起算；倘起訴前已按原約定租金額給付或受領給付而發生清償之效力者，僅得就尚未給付或尚未發生之租金為調整。

第四項、押租金

一、概說

(一) 意義

押租金是出租人為擔保租金之給付與租賃債務履行之目的，請求承租人移轉一定之金錢或替代物，又稱「擔保金」¹⁸³。實務及學說將此認定為一種「讓與擔

¹⁷⁹ 最高法院 68 年台上字第 3071 號判例：「基地租金之數額，除以基地申報地價為基礎外，尚須斟酌基地之位置，工商業繁榮之程度，承租人利用基地之經濟價值及所受利益等項，並與鄰地租金相比較，以為決定，並非必達申報總地價年息百分之十最高額。」最高法院 81 年度台上字第 3062 號、87 年度台上字第 1133 號、89 年度台上字第 388 號判決同旨。

¹⁸⁰ 最高法院 79 年度台上字第 2737 號判決：「土地法第九十七條規定最高租金額之限制，係指租金不得超過土地及其建築物申報總價額年息百分之十而言，並非謂租金必隨申報地價之變動而當然調整。」

¹⁸¹ 最高法院 75 年台上字第 2126 號判例：「租賃物為不動產者，因其價值之昇降，當事人固得依民法第四百四十二條規定，聲請法院增減其租金。惟調整租金之訴，祇能增減租金之數額，不得將原約定之租金種類變更。」最高法院 88 年度台上字第 3083 號判決同旨。

¹⁸² 最高法院 48 年台上字第 521 號判例：「房屋或土地出租人，依民法第四百四十二條提起請求增加租金之訴，如起訴前之租金並未按原約定租額付清，則法院准許增加之判決，得自出租人調整租金之意思表示時起算。故起訴前未為此項意思表示者，即不得溯及請求調整。」最高法院 48 年度台上字第 317 號、82 年度台上字第 1877 號、86 年度台上字第 1364 號判決同旨。

¹⁸³ 邱聰智，前揭註 31，頁 372。

保」，亦即「附有停止條件返還債務的所有權讓與」^{184、185}。在租賃關係消滅前，出租人不負返還之義務¹⁸⁶。並且，以租賃關係消滅時，無欠租與其他債務不履行之情事，或發生抵償效力仍有餘額作為停止條件，待條件成就時，發生返還義務¹⁸⁷。又，對於押租金出租人在租賃債務範圍內享有優先權，承租人之其他債權人不得就尚未發生返還請求權之押租金，實施強制執行¹⁸⁸。

(二) 類型

1. 區分依據

押租金根據使用交易目的可區分為「押金」及「押租」，前者純以擔保租賃債務為目的者；後者兼具租金支付功能者¹⁸⁹。押金型態是目前當事人常見的交易模式，由出租人取得使用收益權限，毋庸支付利息與承租人。「押租」契約又可分為「押金計息，息抵租金」之類型，與「押金抵付租金」（租金預付）之類型¹⁹⁰。應注意的是，後者「租金預付」之型態，於租賃消滅時，押金雖已不存在，但倘於租期屆滿前，若租賃物因可歸責於承租人之事由而毀損滅失，此時預付租金仍

¹⁸⁴ 臺灣高等法院 84 年度重上字第 292 號判決：「按押租金契約，係信託的所有權讓與行為，乃承租人以擔保租賃契約所生債務之履行為目的，移轉押租金之所有權與出租人，如承租人履行租賃債務完畢，出租人即應全數返還，倘承租人有欠租或其他債務不履行情事，出租人當然就押租金扣押受償，苟有餘額再返還之。準此，出租人就押租金，負有附停止條件之返還義務，在出租人自己之債權受清償前，不負返還之義務；租賃關係終了，承租人若有欠租時，其所交付之押租金，無須當事人之意思表示，亦不問當事人之意思如何，發生『當然抵充』（法定抵充）之效力；出租人就押租金所為之抵充，有優先權，承租人之其他債權人不得就尚未發生返還請求權之押租金，實施強制執行。此為我國及日本學者之通說（吳啟賓氏所撰「論不動產租賃之押租金」乙文，刊載於吳啟賓氏著「土地法規與民事審判實務」第二五一頁正反面、第二五七頁；謝在全氏著「民法物權論」下冊第二八三頁參看；史尚寬氏、鄭玉波氏、楊與齡氏、姚瑞光氏有關民法物權著作，均採此一見解），實務上亦持相同之看法（本院五十五年法律座談會研討意見參看）。」

¹⁸⁵ 林誠二，前揭註 37，頁 374-375。吳秀明，前揭註 29，頁 400。邱聰智，前揭註 31，頁 379-381。另外，尚有其他學說意見：債權質說、附解除條件之消費寄託、附停止條件之債權說及抵銷預約說，不過皆與押租金之目的未合，少有採納。

¹⁸⁶ 最高法院 83 年台上字第 2108 號判例：「押租金在擔保承租人租金之給付及租賃債務之履行，在租賃關係消滅前，出租人不負返還之責。本件租賃關係既已消滅，承租人且無租賃債務不履行情事，從而其請求出租人返還押租金，自為法之所許。」

¹⁸⁷ 邱聰智，前揭註 31，頁 383-384。

¹⁸⁸ 同前揭註 184。

¹⁸⁹ 邱聰智，前揭註 31，頁 375-376。

¹⁹⁰ 邱聰智，前揭註 31，頁 376。

生擔保作用，即非單純租金之預付¹⁹¹。

2. 區分實益

上述類型皆以擔保為目的，此區分並無太大實益，但實務上卻持有不同看法。在「押金計息，息抵租金」之類型，實務認為其為租賃契約與借貸契約，但此已經嚴重偏離當事人約定押租金之真意，實有不妥¹⁹²。另外，區分「押金抵付租金」之類型，主要實益在租賃物轉讓第三人時，實務見解認為不論出租人是否將押租金移轉第三人，承租人皆享有得對抗受讓人之權利，毋庸再履行給付之義務¹⁹³。實務對於此類型，特別考量承租人已給付租金之義務，將租金給付之風險轉移受讓人承擔之見解可資贊同，但若仔細分析實然是實務對於押租金性質認定之謬誤，使其不得不區分加以緩和，但是否只有「押金抵付租金」之類型須特別保護，不無疑問。對此，於下文詳述(本項二、性質)，即可揭曉。

3. 立法者預設類型

押租金的類型原則上由當事人自行約定，但土地法第 98 條第 1 項之規定：「以現金為租賃之擔保者，其現金利息視為租金之一部。」因此在無特別約定情況下

¹⁹¹ 邱聰智，前揭註 31，頁 376。

¹⁹² 最高法院 64 年台上字第 2400 號判例：「所謂土地押租契約，一般指出租人將土地出租與承租人，承租人另借款與出租人，雙方約定以借款利息抵付土地租金，俟租賃關係終了時互相返還土地借款之聯立契約，其有關法律關係應分別適用民法租賃、借貸之規定。」另有實務曾認「押金計息，息抵租金」是租賃契約與典權契約之聯立，司法院院字第 2132 號解釋：「大佃契約當事人之一方，因支付鉅額押金祇須支付小額租金即得佔有他方之不動產，而為使用及收益者，應認為租賃契約與典權設定契約之聯立，一方所支付之押金，即為民法第九百十一條所稱之典價，對於該不動產相當於押金數額部分之使用收益權，即為同條所稱之典權，該不動產之其他部分，因支付租金所得行使之使用收益權，仍為租賃權，但當事人明定一方所支付之金錢為借款，他方就該不動產全部設定抵押權，並將該不動產全部出租於抵押權人，約明以其應付之租金，扣作借款之利息，僅須支付其餘額者，仍應從其所定，所有以前解釋及判例與此見解有異者，應予變更。」參照。

¹⁹³ 司法院院字第 1909 號解釋：「民法第四百二十五條所謂對於受讓人繼續存在之租賃契約，係指民法第四百二十一條第一項所定意義之契約而言，若因擔保承租人之債務而授受押金，則為別一契約，並不包含在內，此項押金，雖因其所擔保之債權，業已移轉，應隨同移轉於受讓人，但押金契約，為要物契約，以金錢之交付，為其成立要件，押金權之移轉，自亦須交付金錢，始生效力，此與債權移轉時，為其擔保之動產質權，非移轉物之占有，不生移轉效力者無異，出租人未將押金交付受讓人時，受讓人既未受押金權之移轉，對於承租人自不負返還押金之義務。惟承租人依租賃契約所為租金之預付，得以之對抗受讓人，故租賃契約，如訂明承租人得於押金已敷抵充租金之時期內，不再支付租金，而將押金視為預付之租金者，雖受讓人未受押金之交付，亦得以之對抗受讓人，此為本會議最近之見解，所有以前關於此問題之解釋，應予變更。……」最高法院 51 年台上字第 2858 號判例同旨。

則採「押金計息，息抵租金」之模式，然而此項規定與現實交易脫節，雖然保障了承租人的期限利益，卻可能延伸其他爭議。因此，在租賃住宅管理條例第 3 條第 3 款之規定將押租金的預設模式改為「押金」以切合現實交易運作。

(三) 擔保範圍

押租金所擔保範圍，以租賃關係效滅前及效滅時所生之債務為主要。不過，租賃關係效消滅後所生之債務，如：逾期返還租賃物繼續占有，請求不當得利或損害賠償，是否即無適用空間，並非無疑。採肯定學者認為押租金所擔保是指租賃關係存續中所生之債務，至於租賃關係效滅後所生之債務仍應回歸到民法抵銷之適用¹⁹⁴。然而，出租人要求押租金主要是要降低承租人不具備履行給付義務之責任所生之損害，「租賃物之返還」既為承租人之給付義務，其延伸之損害應無排除適用之理，實務採否定見解¹⁹⁵。在租賃住宅管理條例第 3 條第 3 款之規定明文化押金所擔保之範圍，其規定：「押金指承租人為擔保租賃住宅之損害賠償行為及處理遺留物責任，預為支付之金錢。」並無以「租賃關係存續中」所生之債務為要件。換言之，新條例之規定亦採後說。

二、性質

押租金存在目的既是擔保租賃債務，須以租賃契約存在為前提。換言之，租賃契約存在並不當然代表存有押租金之約定，性質上屬於物保及從契約，甚為明顯。但押租金契約是否得進一步認為是「別一契約」及「要物契約」則有待釐清，其重大實益在於租賃物轉讓第三人時，何人承擔向出租人請求押租金之風險。

(一) 實務見解

早期實務見解押租金為租賃契約內容之一部，故出租人轉讓租賃物於受讓人，則受讓人承擔原租賃之法律關係，包含租賃關係消滅時押租金之返還之義務，

¹⁹⁴ 邱聰智，前揭註 31，頁 374。

¹⁹⁵ 最高法院 69 年度台上字第 3985 號判決：「查承租人交付押租金與出租人，在於擔保其租賃債務之履行，諸如租金之給付，租賃關係終了後，租賃物之返還以及遲延返還租賃物所生之損害賠償債務均是。故在租賃關係終了後，承租人於租賃物返還前，尚不得請求出租人返還押租金，自亦無從主張其租賃物之返還應與出租人押租金之返還同時履行。」

自承擔向出租人請求押租金之風險¹⁹⁶。惟嗣後實務改變見解認定押租金有別於租賃契約為獨立契約並且為要物契約，遂成實務通說¹⁹⁷。依此見解，出租人將租賃物之所有權讓與時，押租金契約不當然隨同租賃契約而移轉於受讓人。換言之，押租金契約在押租金轉交於受讓人前，存在於出租人與承租人之間，故由承租人承擔向出租人請求押租金之風險。

(二) 學說見解

學者對於實務所改變之見解，多抱持肯定的立場¹⁹⁸。然而，部分學者認為實務將押租金契約認定為「別一契約」，而否定押租金契約為租賃契約內容之一部，稍嫌速斷¹⁹⁹。固然約定租賃契約不當然同時成立押租金契約，但現實交易上通常多在住宅租賃契約裡同時明文押租金之內容，從內政部公布之住宅租賃契約應約定及不得約定事項第 4 點及房屋租賃定型化契約應記載及不得記載事項第 5 點之內容亦能得知，實難謂押租金非租賃契約內容之一部。另外，要物契約是以交付為契約生效要件，目的是給予債務人悔約之機會，因此倘押租金尚未給付，承租人是否即無給付之義務，此應非出租人所能接受，故押租金契約實非要物契約²⁰⁰。

對於此問題，學者從風險分配的角度認為出租人移轉租賃物所有權，受讓人一般若知有租賃契約可以透過詢問、查看合約等間接推知押租金契約之存立與否，相比承租人可能就出租人移轉租賃物所有權之事未必能夠得知，故受讓人較能提早預防押租金無法順利請求之風險，尤其當原出租人陷於無資力之狀態，由

¹⁹⁶ 司法院院字第 1266 號解釋：「依民法第四百二十五條規定，應繼續存在之租賃契約，其讓與人對於承租人契約上之權利義務，即皆移轉於受讓人，承租人當日所交之押租金，係原約內容之一部，自得向受讓人請求返還。」院字第 1807 號及第 1843 號解釋同旨。

¹⁹⁷ 最高法院 65 年台上字第 156 號判例：「民法第四百二十五條所謂對於受讓人繼續存在之租賃契約，係指民法第四百二十一條第一項所定意義之契約而言，若因擔保承租人之債務而接受押租金，則為別一契約，並不包括在內，此項押租金契約為要物契約，以金錢之交付為其成立要件，押租金債權之移轉，自亦須交付金錢，始生效力，出租人未將押租金交付受讓人時，受讓人既未受押租金債權之移轉，對於承租人自不負返還押租金之義務。」

¹⁹⁸ 吳啟賓，租賃物所有權移轉與押租金之關係，法令月刊，第 37 卷 5 期，頁 13-14、24，1986 年 5 月。邱聰智，前揭註 31，頁 378。劉春堂，民法債編各論(上)，自版，頁 295-296，2003 年 9 月。

¹⁹⁹ 謝哲勝，請求返還押租金，月旦法學教室，第 22 期，頁 14，2004 年 8 月。

²⁰⁰ 謝哲勝，前揭註 199，頁 14-15。

受讓人承擔實為合理²⁰¹。因此，從風險分配的角度檢視實務所採之性質認定，確實有礙承租人之權益，有必要重新斟酌。

三、效力

當事人雙方存有押租金契約，在租賃關係消滅後，債務不履行之情事仍存在，不待當事人表示即發生押租金抵償之效力，不同於抵銷應向他方為意思表示(民法第 334 條及 335 條參照)，此乃押租金契約擔保功能的便捷之處。不過，當押租金之金額若小於租賃債務而不足清償時，依法則會發生抵充之效果，此情似可類推適用民法第 321 及第 322 條之規定²⁰²。反之，租賃關係消滅後，無欠租與債務不履行之情事，出租人發生返還義務，並與承租人之租賃物返還間具有同時履行抗辯之關係(租賃住宅管理條例第 7 條第 2 項參照)²⁰³。

四、押租金的限制

為避免出租人透過收取押租金躲避租金總額的限制，或預先收取高額的押租金並嗣後任意苛扣損及承租人之權益，土地法第 99 條及租賃住宅管理條例第 7 條 1 項之規定押租金額度不得超過二個月房屋租金之總額，超過限度者，承租人得以超過之部分抵付房租²⁰⁴。該條所稱之房屋解釋上與租賃住宅相同，理由與詮釋土地法第 97 條之房屋並無不同。又，所謂承租人得以超過之部分抵付房租，實為「抵銷」之意思。質言之，須待承租人以意思表示為之後，其相互間債之關係，溯及最初得為抵銷時，按照抵銷數額而消滅（民法第 335 條參照）。

第五項、小結

一、檢討租金管制取代去管制化

租金的管制雖然不符合經濟學理念，但從整體社會觀察可能帶來更多其他金

²⁰¹ 吳從周，租賃關係存續中押租金之返還與租金之預付－簡評最高法院 99 年度台上字第 633 號判決，台灣法學雜誌，第 195 期，頁 22，2012 年 3 月。

²⁰² 邱聰智，前揭註 31，頁 383。

²⁰³ 謝哲勝，前揭註 199，頁 15。

²⁰⁴ 楊松齡，實用土地法精義，五南，頁 363，2017 年 9 月 17 版。

錢物質無法衡量的效益，故對於出租人之收益權限產生限制，但只要出租人可以獲得合理的利潤，仍然在憲法保障所容許的範圍，但此項涉及對契約內容的事前管制，屬於高度干涉私法自治的手段，故在適用的範圍必須節制。在土地法第 97 條之規定適用上應以住宅租賃為主，因此曾經擴及適用於營業用租賃，導致承租人有受過度保護之疑慮實屬不當。在租金管制的計算基礎應重新檢討，避免出租人之財產權二次受到損害。

然而，目前新條例放棄租金管制，希冀透過租賃住宅的大量供給，以量制價，降低租金額度，間接保障承租人的居住權益。不過，會不會適得其反造成現有租賃住宅市場哄抬價格，損及承租人有限之資源，不無疑問。應適時考慮租金總額管制或者改為租金調漲管制為宜。另外，是否實施租金的管制，學者建議可以授權地方立法機關決議，以避免影響整體租賃住宅市場並且符合因地制宜原則²⁰⁵。

二、押租金契約性質重新認定

最後，押租金之部分管制原則以兩個月之租金額度為限，但不反對當事人得約定更高的額度，僅不過對於超收部分賦予承租人主張抵銷以保護自身權益，使雙方在租賃擔保及任意苛扣風險得以平衡(土地法第 99 條第 2 項參照)。不過，押租金最大的問題在於實務性質認定不當，導致在於租賃物轉讓第三人時，延伸承租人究竟向誰請求押租金之問題，更有「新受讓人說」及「押租金實際占有人說」之爭論²⁰⁶。

在新條例授權公布住宅租賃契約應約定及不得約定事項第 15 點之內容雖然明文出租人應於租賃住宅所有權轉讓受讓人時，應移交押金與受讓人並以書面通知承租人，有意使受讓人承擔向出租人請求押金的風險，固然保護了承租人之權益。但在出租人未移交時，承租人是否仍然可以逕向受讓人請求，尤其實務將押租金契約認定為別一契約及要物契約性質之見解，使得問題仍然未解。為避免問題持

²⁰⁵ 謝哲勝，前揭註 138，頁 96。

²⁰⁶ 實務採押租金實際占有人說，詳見：姚志明，租賃物移轉後，租金請求與押租金返還之問題，月旦法學教室，第 163 期，頁 15-17，2016 年 5 月。

續復雜難以解決，其釜底抽薪之計在於押租金契約之性質應重新認定。

第二節 穩定持續的契約關係

第一項、重要意義

承租人選擇居住地點往往與學校、工作地點等具有密切關聯。若每次租期屆滿皆須另尋房屋或受出租人任意終止租約，對承租人追求安穩及安全的居住空間將難以實現。讓承租人擁有穩定持續的住宅租賃契約關係是保障其居住權益的重要手段，並且與租金管制相輔相成。質言之，若僅盡力維持穩定持續的住宅租賃契約關係，放任出租人調高租金，將使承租人無法負擔，迫使承租人主動放棄締結契約機會或提早終止契約關係；反之，若僅有租金管制，沒有注意維持穩定持續的住宅租賃契約關係，將使承租人容易喪失居住的正當權源而流離失所。故穩定持續的住宅租賃關係，在維護居住權益當中屬於重要課題。

第二項、可能方法

穩定持續住宅租賃關係之手段可能包含：所有權讓與不破租賃(民法第 425 條參照)、出租人終止權之限制(土地法第 100 條參照)以及租期屆滿後續約問題。前者主要處理承租人與租賃住宅受讓人間法律關係之問題，後面兩者則處理承租人与出租人間法律關係之問題。

此外，依據實務學說見解似主張法定更新亦是保護承租人穩定持續住宅租賃關係之手段之一，但法定更新實則為明確雙方法律關係，並無意偏袒一方(民法第 451 條參照)²⁰⁷·²⁰⁸。質言之，法定更新是為避免雙方因對造「出爾反爾」致受損害，故立法者透過擬制性手段使雙方權利關係單純化以符合法律經濟原則，而非維持

²⁰⁷ 最高法院 55 年台上字第 276 號判例：「民法第四百五十一條所定出租人於租期屆滿後須即表示反對之意思，始生阻止續租之效力。意在防止出租人於租期屆滿後，明知承租人就租賃物繼續使用收益而無反對之表示，過後忽又主張租賃關係消滅，使承租人陷於窘境而設，並非含有必須於租期屆滿時，始得表示反對之意義存在。故於訂約之際，訂明期滿後絕不續租，或續租應另訂契約者，仍難謂不發生阻止續約之效力。」

²⁰⁸ 陳自強，契約之內容與消滅，元照，頁 179，2016 年 3 月。

穩定持續住宅租賃契約關係的手段²⁰⁹。因此，維持穩定持續住宅租賃關係之手段，主要為所有權讓與不破租賃、出租人終止權行使限制以及租期屆滿後續約問題。

第三項、合憲問題

一、所有權讓與不破租賃

考量租賃制度存在目的在於承租人取得使用收益之代價相較於買賣制度直接獲得所有權成本低即可發揮相同之經濟效益，以及租賃住宅使用之性質牽涉居住權益，為了避免降低當事人使用租賃制度的意願，因此國家選擇須介入調和當事人權益關係。所有權讓與不破租賃制度，乃鑑於住宅租賃契約具有占有公示方法，能夠維護動態的交易安全，並不影響未來出租賃住宅之受讓人原本即須負擔的資訊成本，故為了不額外增加承租人監督出租人忠實履行契約之交易成本，國家選擇保護承租人優先於租賃住宅之受讓人以符合法律經濟原則，為憲法第 23 條容許範圍²¹⁰。此項說法也充分補足昔日以保護經濟弱勢之承租人之理由²¹¹。

二、出租人終止權行使限制

另外，限制出租人終止權之行使雖然影響當事人財產之使用權及契約自由之憲法保障，但在住宅租賃契約關係當中出租人依舊存在實質終止契約之機會並且受有承租人支付的對價，仍然符合均衡正義，無違憲法第 15 條保障人民財產權及第 22 條契約自由之保障意旨。

三、租期屆滿後續約問題

然而，租期屆滿後續約問題對於出租人權利限制更高，倘若法律賦予拒絕續約的難度過高，嚴重影響當事人財產權，國家則應給予徵收或補償，方謂適法。目前我國尚未存有相關規範，過去《自用房屋租賃法草案》雖然提及租期屆滿後

²⁰⁹ 鄧文明，不動產租賃之默示更新，頁 35-36，國立臺北大學不動產與城鄉環境學系碩士論文，2018 年 2 月。

²¹⁰ 胡天賜，前揭註 61，頁 176-178。簡資修，前揭註 61，頁 141-142。

²¹¹ 林誠二，買賣不破租賃規定之目的性限縮與類推適用，台灣本土法學雜誌，第 97 期，頁 144-145，2007 年 8 月。黃立，買賣不破租賃的鐵則不再，月旦法學教室，第 1 期，頁 14-15，2002 年 11 月。。

續約問題，但卻無給予出租人任何租稅優惠等其他補償措施。因此，可以推測大概是現行《租賃住宅管理條例》所不採納之原因，但租期屆滿後續約問題是居住權益保障的重要內容，否有妥適，詳待後述(本章第六項、租期屆滿後續租問題)。

第四項、所有權讓與不破租賃

所有權讓與不破租賃乃指出租人交付租賃物所有權時，使受讓人法定繼受原先之權利義務關係，承租人與受讓人間無須另立租賃契約²¹²。因此，原出租人脫離租賃契約之地位由受讓人繼受，承租人並保持使用收益的正當權原。依民法第425條之規定：「出租人於租賃物交付後，承租人占有中，縱將其所有權讓與第三人，其租賃契約，對於受讓人仍繼續存在(第1項)。前項規定，於未經公證之不動產租賃契約，其期限逾五年或未定期限者，不適用之(第2項)。」由於所有權讓與不破租賃並不分客體一律適用，自包含住宅租賃契約。其適用的前提要件主要有四，包含：(1)須存在有效租賃契約、(2)有法定公示狀態、(3)出租人將所有權轉讓與第三人以及(4)不動產租期逾五年或未定期限者須經公證。然而，後面兩者從承租人居住權益保障的觀點，在住宅租賃契約存有適用問題。

一、須出租人將所有權移轉讓與第三人

依民法第425條之規定推導出所有權讓與不破租賃原則既以所有權移轉，同時以出租人具備所有權人為前提始發生效力。惟若堅守此項要件，可能阻礙了正在發展的租賃住宅服務業。

(一) 承租人締約對象為受所有權人委任或得其同意出租之人

當承租人締約對象為受所有權人委任或得其同意出租之人，若遇所有權人轉讓所有權時，由於所有權人非出租人，則無所有權讓與不破租賃原則適用的空間。鑑此，所有人可能利用第三人為出租人，以規避所有權讓與不破租賃原則的束縛。為避免規避情事發生，現行實務見解認為：「第三人如受所有人之委任或得其同意

²¹² 最高法院23年上字第3092號判例：「出租人於租賃物交付後，將其所有權讓與第三人時，其租賃契約既對於受讓人繼續存在，則在承租人與受讓人間，自無須另立租賃契約，於受讓之時當然發生租賃關係。」

而為出租時，得類推適用民法第 425 條之規定。²¹³」同受所有權讓與不破租賃原則拘束。雖然此項結論可資贊同，但此處之同意是否混淆負擔行為與處分行為不免受到質疑，蓋租賃契約之成立不以具備所有權為限，實有必要說明²¹⁴。學者認為從民法第 118 條處分行為效力所蘊涵的精神，民法第 425 條之規定所有權讓與不破租賃具有對抗效力猶如法定物權，應以同樣方式處理，故實務所稱同意是指所有權人同意賦與出租人與承租人間之租賃契約得發生所有權讓與不破租賃之對抗效力，此項說法補充了實務見解不夠圓滿之處²¹⁵。

(二) 次承租人締約對象為所有權人同意轉租之第一承租人

另一情形，次承租人締約對象為所有權人同意轉租之第一承租人，當第一承租人轉讓租賃權時，由於非所有權轉讓，似亦不得對租賃權之受讓人主張所有權讓與不破租賃。倘若如此，對於次承租人之保護有所不周。實務見解認為此項情形與出租人移轉所有權人相似，應允類推適用以保障次承租人之權益²¹⁶。不過，有學者則認為租賃權之受讓人既取得第一承租人之地位，繼承內容包括延伸之轉租關係，次承租人當然得以與第一承租人之租賃契約對抗租賃權之受讓人，實無民法第 425 條之規定適用與否的問題²¹⁷。但此說忽略了租賃權受讓人所取得之租賃契約與轉租契約，為兩個獨立契約，如欲繼承轉租契約則因涉及契約主體的變更，應有次承租人之同意問題。雖然兩者結果相同，但實務見解相對可採。

二、租期逾五年或未定期限者須經公證

²¹³ 最高法院 84 年台上字第 163 號判例：「民法第四百二十五條規定之適用，固以讓與租賃物之所有人為出租人為其要件，然第三人如得所有人同意而為出租時，仍得類推適用該條之規定。」

²¹⁴ 蘇永欽，關於租賃權物權效力的幾個問題—從民法第四二五條的修正談起，律師雜誌，第 241 期，頁 22-23，1999 年 10 月。

²¹⁵ 蘇永欽，前揭註 214，頁 23-25。

²¹⁶ 最高法院 36 年度民、刑庭會議決議：「房屋承租人經出租人之承諾，將租賃權讓與他人時，依民法第四百二十五條之類推適用，合法之次承租人得主張與承租人所訂租賃契約對於受讓租賃權之他人，仍繼續存在。」

²¹⁷ 王澤鑑，買賣不破租賃：民法第四二五條規定之適用、準用及類推適用，軍法專刊，第 35 卷 8 期，頁 10，1989 年 8 月。王澤鑑，民法學說與判例研究第六冊，自版，頁 223-224，2009 年 12 月。

(一) 立法理由

所有權讓與不破租賃適用前提原則上無須公證，但租期逾五年或未定期限者不在此限²¹⁸。查其立法理由主要有二：考量長期或不定期之租賃契約對於當事人權利義務影響甚鉅，為明確雙方權利義務關係，以杜爭議及減少訟源，此其一²¹⁹。防免債務人於受強制執行之際，與第三人虛偽訂立長期或不定期之租賃契約妨害債權之強制執行，此其二²²⁰。不過，對於租期逾五年或未定期限者要求公證方有所有權讓與不破租賃適用之限制卻可能損及承租人之居住權益。

(二) 立法評析

1. 增加交易成本不利追求穩定的住宅租賃契約關係

住宅租賃契約之公證請求須由承租人與出租人雙方協同辦理，並繳交一定的公證費用(公證法第 108 條以下參照)，將增加當事人之交易成本，除了雙方願意彼此配合外，可能選擇不循公證制度²²¹。此外，承租人為了避免無所有權讓與不破租賃之適用將可能委曲轉而訂立小於五年之租期，則對於追求穩定的住宅租賃契約關係之承租人，可謂不利。

2. 公證制度無法補充占有作為公示方法之缺點

引進公證制度是否可以補充占有作為公示方法之缺點，即有意之受讓人得透過請求閱覽公證書之方式，了解住宅租賃關係之有無，不無疑問。蓋依公證法第 89 條之規定：「請求權人或繼受人或就公證書有利害關係之人，得請求閱覽公證卷內文書。」換言之，請求閱覽公證卷內文書須與公證書具有利害關係，租賃物讓與契約未成立前，受讓人僅是與出租人洽商之相對人，難謂具有利害關係。

退步言之，有論者基於民法第 245 條之 1 誠實磋商原則，肯認其與公證書具

²¹⁸ 林誠二，買賣不破租賃原則限制規定之溯及力問題，台灣本土法學雜誌，第 84 期，頁 130，2006 年 7 月。

²¹⁹ 立法院公報處(1999)，前揭註 55，頁 329-331。

²²⁰ 立法院公報處(1999)，前揭註 55，頁 329-331。

²²¹ 溫豐文，民法第四二五條修正條文評析--論租賃權物權化之範圍，東海大學法學研究，第 19 期，頁 205-207，2003 年 12 月。

有法律上利害關係之人，固非無見²²²。不過，在實務操作上除出租人願意出具同意書供受讓人查證外，洽商之相對人面對出租人拒絕協助提供同意書後，如何證明與出租人間的磋商關係，實非容易，故透過公證制度補充占有作為公示方法之缺點恐怕稍有困難。

3.防堵逃避債務及減少訟源成效有限

另外，觀察立法者制定所有權讓與不破租賃限制條件之立法理由有待商榷。長期或不定期之租賃契約對於當事人權利義務影響甚鉅，透過公證固然能夠明確雙方權利義務關係，預防爭議。但公證制度之踐行是否能夠有效防堵逃避債務的問題，尤其僅要求租期逾五年或不定期之租賃契約之前提下，不免遭受質疑。再者，縱使依法請求公證後，承租人仍須具備法定的公示狀態，在逃避債務案件是否僅是從原本爭執虛偽訂立租約之戰場，轉移於「承租人占有中」要件之認定，則對減少訟源的成效為何，實有疑問²²³。綜上所言，民法第 425 條第 2 項之限制規定，雖然立意良善，惟整體而言成效有限並且間接損及了承租人之居住權益，是有顧此失彼，思慮不夠周全之處。對於上述問題，或許可以參考學者曾經之建議將民法第 425 條第 2 項刪除，在同條第 1 項增訂但書「租賃物因法院拍賣或出租人破產、公司重整而變賣時，不在此限。」一方面在逃避債務事件中保護第三人之債權利益，另一方面避免打擊過廣以降低損及其他承租人居住權益之程度²²⁴。

三、小結

所有權讓與不破租賃原則，對於保護承租人穩定的使用租賃住宅之利益，具有重大意義。實務秉持相同意旨的精神，在處理承租人締約對象非所有權人時，透過類推適用的法學方法，補足權益保護的漏洞，足資贊同。在《租賃住宅管理條例》除了包租業外，對於代管業市場交易模式的設計，限於委任處理租賃住宅管理業務，不包含委任出租的部分，亦確實能夠減少此類問題在法律適用的疑慮。

²²² 陳玫君，前揭註 60，頁 175。

²²³ 陳玫君，前揭註 60，頁 177-178。

²²⁴ 李忠雄，論買賣不破租賃與逃避債務，法令月刊，第 44 卷第 5 期，頁 12，1993 年 5 月。

然而，在於租期逾五年或未定期限者有關所有權讓與不破租賃之適用須踐行公證的要求，無意之中間接損及承租人的居住權益，乃唯一美中不足之處。公證制度的限制乃出自補充占有作為公示方法之缺點、防堵逃避債務及減少訟源成效之考量，然而前者忽略公證制度本質不具有公示性，難作為公示手段，對於後面兩者僅要求租期逾五年或不定期之租賃契約之前提下，能夠達到的目的成效為何，實有疑問。雖然上述考量立意良善，卻間接損及了承租人之居住權益，實非妥適，建議刪除。

第五項、出租人終止權之限制

一、民法規定

除了防止出租人利用轉讓租賃住宅所有權規避住宅租賃契約的履行義務外，更應注意避免出租人任意終止契約直接影響住宅租賃契約關係，才能完整保障承租人之居住權益。在《民法》不定期租賃契約，各當事人得隨時終止契約。定期租賃契約則考量雙方對於契約履行期待較高，故於期限屆滿時消滅，但有民法第 438 條第 2 項之規定承租人違反約定使用或收益方法、第 440 條第 2 項之規定遲延租金總額達二個月以上或第 443 條第 2 項之規定違反轉租時，出租人得提前終止契約²²⁵。

然而，租賃住宅是生活必需品牽涉承租人之居住權益，民法之規定實在不足保障承租人享有穩定的住宅租賃契約關係，尤其是不定期住宅租賃契約之承租人。因此，為解決住宅租賃契約不論是定期租賃或不定期租賃在出租人終止權行使的限制問題，增訂土地法第 100 條之規定。

二、土地法第 100 條之規定

土地法第 100 條之規定：「出租人非因左列情形之一，不得收回房屋。一、出租人收回自住或重新建築時。二、承租人違反民法第四百四十三條第一項之規定轉租於他人時。三、承租人積欠租金額，除擔保金抵償外，達二個月以上時。

²²⁵ 謝哲勝，前揭註 92，頁 266。

四、承租人以房屋供違反法令之使用時。五、承租人違反租賃契約時。六、承租人損壞出租人之房屋或附著財物，而不為相當之賠償時。」列舉出租人得收回房屋之情事。由於出租人負有交付租賃物使用之義務，其收回房屋勢必須以終止租賃契約關係為前提，故相當限制出租人終止權行使之情形。

（一）適用範圍

1. 僅適用於住宅租賃契約

土地法第 100 條和同法第 97 條之規定，其目的皆強調彌平承租人的經濟地位以保障其居住權益，故兩者所稱之「房屋」應無不同，適用租賃契約範圍相同。因此，與《租賃住宅管理條例》之租賃住宅意義亦相同，自僅適用於住宅租賃契約。

然實務持有不同見解，其認為本條所言之「房屋」意義兼指居住使用與營業用之房屋，不但較「租賃住宅」範圍廣且與土地法第 97 條之規定不同²²⁶。此說不分使用目的同受土地法第 100 規定之保護，在非居住使用之房屋租賃契約關係中，承租人將享有過度保護的問題。因承租人依民法第 450 條第 2 項之規定得隨時終止契約，出租人卻受土地法第 100 條之規定限制，不但與土地法第 100 條之立法旨趣格格不入並且有失衡平，實務見解有待商榷。

2. 不限於不定期租賃契約類型

土地法第 100 條之增訂雖然補足民法對於住宅租賃契約保障之缺漏，但學說及實務見解認為土地法第 100 條之規定僅適用不定期之住宅租賃契約，卻延伸其他問題^{227、228}。

²²⁶ 最高法院 51 年台上字第 370 號判例：「土地法第一百條所謂之房屋兼指住屋與供營業用之房屋而言，系爭廠房租賃固無排除該條規定之適用，惟上訴人在原審既始終主收回系爭廠房及機械設備自行經營，自與該條第一款之規定相當。」最高法院 94 年度第 3 次民事庭會議決議仍予維持該判例。

²²⁷ 吳啟賓，前揭註 34，頁 107-108。

觀察土地法第 100 條之規定，沒有明文限定不定期住宅租賃契約方有適用之要件，實務解釋已超出文義解釋範圍。再者，現實交易以定期住宅租賃為主，故如此解釋將使其存在意義不但不大，反而使租期相對穩定之定期住宅租賃比起不定期住宅租賃之保障更為周全，輕重失衡²²⁹。因此，土地法第 100 條之規定不論是定期住宅租賃或不定期住宅租賃皆有適用空間。綜上，實務見解對於土地法第 100 條之適用不論是定義或範圍似乎未能正確掌握，以致間接損及出租人及承租人之權益，有必要重新檢討。

（二）收回條件

1. 可歸責於承租人之事由

觀察土地法第 100 條之收回要件，以可歸責於承租人之事由為主，包含：違法轉租、積欠租金、違反法令之使用、損壞出租人之房屋或附著財物而不為相當之賠償等其他違反住宅租賃契約之情事。特別須注意的是，在民法對於積欠租金額設有不同之要件規定，土地法第 100 條第 3 款之規定須積欠租金額度抵償擔保金二個月後始可收回房屋，民法第 440 條第 2 項之規定則僅須遲付租金總額達二個月以上即可終止契約。

2. 出租人收回自住或重新建築

本款限於契約當事人方有適用，並具備收回自住或重新建築兩者之一，訴訟上又以重新建築作為收回之理由為大宗。

（1）收回自住

所謂收回自住，係指出租人對於出租之住宅有收回供自己或共同生活之家屬

²²⁸ 最高法院 37 年上字第 7729 號判例：「租賃契約屆滿後，如非有民法第四百五十一條所定，視為以不定期限繼續契約之情形，則其租賃關係應依同法第四百五十條第一項規定，於租期屆滿時消滅，不受土地法第一百條所定各款之限制，業經司法院院解字第三四八九號解釋有案。雖原判決成立於該號解釋發表以前，而係以司法院院解字第三二三八號解釋為依據，但第三四八九號解釋已將第三二三八號解釋所持之見解變更，則土地法第一百條規定，實應解為不包含定有期限之租賃契約在內。原審乃以兩造所訂有期限之租賃契約，應與未定期限之租賃契約，同受土地法第一百條規定之限制，不問其有無民法第四百五十一條規定之情形，不容以期限屆滿而主張租賃關係消滅收回房屋，自嫌未合。」

²²⁹ 謝哲勝，出租人收回房屋之限制，月旦法學雜誌，第 6 期，頁 44-45，1995 年 10 月。

居住²³⁰。實務上並擴張解釋包括收回供自己營業之用，但若出租人與他人共同經營事業之使用則不包括之²³¹。不過，先不論實務見解將自住擴張為自用是否違背法律解釋方法，對於自己營業與他人共同經營事業卻有不同判斷標準，是否妥適不無疑問²³²。為了符合立法目的保護承租人之意旨，解釋上應從嚴。

此外，出租人必須舉證收回自住具備正當理由及必要情形，方為適法^{233、234}。但是否符合正當理由及必要之情形為事實認定的問題，最高法院大多尊重下級審之裁量，少有置喙。然而，仍有兩則判決難得對此表明見解，其認為出租人年邁為了方便就近受子女照顧或者出租人僅有出租房屋一棟為成家立業，皆得作為正當理由，值得參考^{235、236}。

²³⁰ 最高法院 72 年度台上字第 1057 號判決：「房屋租賃，出租人有收回自住之正當理由及必要情形時，得終止之。而所謂收回自住，並不限於收回以供出租人本人自住，兼包括收回供共同生活之家屬自住者在內。且所謂共同生活之家屬，亦不限於其為未成年人者。」最高法院 83 年度台上字第 1942 號、86 年度台上字第 3311 號判決同旨。

²³¹ 最高法院 42 年台上字第 981 號判例：「土地法第一百條第一款所謂收回自住，依司法院院解字第三四八九號解釋，固屬包含收回出租之房屋，以供自己營業之使用者在內，惟此種收回自住，既僅以供出租人自己營業之使用為限，則收回以供出租人與他人共同經營事業之使用，即與僅供出租人自己營業之使用者有間，自難調為亦在得收回自住之列。」最高法院 51 年台上字第 370 號判例及最高法院 88 年度台上字第 430 號、88 年度台上字第 2291 號、101 年度台上字第 1152 號判決同旨。

²³² 吳從周、鄭聆苓，不定期租賃出租人收回房屋之限制－土地法第 100 條第 1 款「收回自住」之實務案例類型化，台灣法學雜誌，第 174 期，頁 94，2011 年 4 月。

²³³ 最高法院 41 年台上字第 138 號判例：「土地法第一百條第一款所謂收回自住，係指出租人對於其出租未定期限之房屋，有收回自住之正當理由及必要情形而言（參照司法院院解字第三四九一號解釋）。故出租人以收回自住為原因請求返還房屋，須具備上述要件並能為相當之證明始得為之。」最高法院 80 年度台上字第 212 號判決同旨。

²³⁴ 最高法院 43 年台上字第 1199 號判例：「土地法第一百條第一款前段所謂收回自住，係指因正當事由有收回自住之必要者而言，出租人基於該條款前段所列之情形收回房屋，應就此負舉證責任。」最高法院 48 年台上字第 228 號及 50 年台上字第 1761 號兩則判例重申其旨。

²³⁵ 最高法院 86 年度台上字第 819 號裁定：「末按原審依調查證據為辯論之結果，以：被上訴人年已逾七十三歲，系爭坐落台北市○○路一二三號一樓房屋係國防部分配予被上訴人居住者，且地點亦方便其子女就近照顧，確有收回自住之正當理由及必要情形，被上訴人依土地法第一百條第一款規定請求收回自住，依法核屬有據，且該房屋自民國八十四年一月至五月份租金每月新台幣七萬元，上訴人復未能證明已支付之事實；因而併為上訴人敗訴判決並不違背法令。」

²³⁶ 最高法院 86 年度台上字第 343 號判決：「……其次，被上訴人與鄭美貞固於所稱擬成婚時間過後仍未結婚，然被上訴人陳明：係因女方想自組小家庭，系爭房屋未能收回，致延宕結婚計劃等語，尚與情理無違。上訴人以被上訴人陳報之結婚日期一再延展，而否認被上訴人有成婚計劃，亦無可取。何況就令被上訴人近日確無成婚計劃，其已成年，擬與父母別居，獨立生活，亦屬情理之常。土地法第一百條第一款前段所指「收回自住」，應就出租人之情況為考量，不能因出租人之父母或子女名下有房屋，即置出租人是否具備收回自住之條件於不顧。被上訴人名下僅有系爭房屋，為供自住而終止租賃契約，收回系爭房屋，尚非無正當理由。」

(2)重新建築

重新建築，指原房屋拆除重新另為建築之謂，至於重新建築之人為誰並非所問²³⁷。而重建標準不以瀕於倒坍為必要，只要客觀上有重建必要即為已足²³⁸。所謂「客觀上有重建必要」應斟酌都市之繁榮發展，指原有建物既與土地利用價值顯不相當，有礙都市發展之程度，新建物與原有建物對於都市市容之改善及土地利用貢獻程度相較大者而言²³⁹。實務上為證明原有建物與土地利用價值顯不相當，常以房屋現值與公告地價作為佐證依據²⁴⁰。另外，是否須於訴訟中提出具體重建計畫，實務認為具體重建計畫非本款要件，故無必要²⁴¹。不過，學說認為雖然不以提出建築執照等具體重建內容為必要，但仍須有相關具體的事實足信已著手重建，方謂適法²⁴²。

(三) 程序要件

由於土地法第 100 條之規定僅係限制出租人終止權行使之原因，如出租人請

²³⁷ 最高法院 70 年台上字第 1401 號判例：「土地法第一百條第一款所謂出租人收回重新建築，係以充分利用土地為目的，故祇須租賃物在客觀上有重建之必要者，出租人即得依該款規定終止租約。至出租人收回房屋係由自己重新建築，抑或與他人合建，甚至供由他人重建，均非所問。」

²³⁸ 最高法院 45 年台上字第 536 號判例：「出租人就所出租之房屋主張收回重新建築，應以客觀的標準認為有必要之正當理由者為限，始得為之。」最高法院 49 年台上字第 1767 號判例：「出租人以重建房屋為收回租賃物之理由者，祇須租賃物在客觀標準上認有重建必要即為已足，非謂必俟租賃物瀕於倒坍始合收回要件。」

²³⁹ 最高法院 60 年台上字第 3027 號判例：「土地法第一百條第一款所謂收回重建之必要，不得僅以物理上堅固與否為準，如建物之價值與土地之利用價值顯不相當，為配合都市之繁榮發展，亦應在斟酌之列。」、最高法院 64 年台上字第 1387 號判例：「土地法第一百條第一款之收回重新建築，不以房屋瀕於倒塌為限，其因建造年久，使用逾齡，有礙都市發展，或與土地利用價值顯不相當者，亦屬之。」最高法院 69 年度台上字第 3299 號、最高法院 70 年度台上字第 3173 號、最高法院 78 年度台上字第 2172 號、最高法院 79 年度台上字第 1599 號、最高法院 79 年度台上字第 2725 號、最高法院 83 年度台上字第 16 號、最高法院 90 年度台上字第 567 號判決、最高法院 92 年度台上字第 789 號裁定同旨。

²⁴⁰ 最高法院 79 年度台上字第 2725 號判決：「被上訴人主張系爭房屋建造迄今已達三十年，非常老舊，須重新建築，已領得建築執照。又該房屋係位於台北市南京東路一段路旁之四樓建物，左鄰為十一樓之國王飯店，且該屋坐落○○○市○○區○○段○○段○○○○○地號土地，其七十八年之公告土地現值為二十一萬三千二百元，五七、五八地號土地為二十一萬四千二百五十元，以該屋所占土地面積共一千一百三十五點七平方公尺計算土地總價，高達二億四千餘萬元，而該屋全棟四樓現值僅五百零四萬七千五百元，具見系爭房屋與基地之利用價值顯不相當，為配合都市發展，被上訴人主張收回重建，自屬必要。」

²⁴¹ 最高法院 83 年度台上字第 1259 號判決：「土地法第一百條第款之收回重新建築，不以房屋瀕於倒塌為限，只須租賃物在客觀標準上認有重建必要為已足，並不以提出具體之重建計劃始合收回要件。」

²⁴² 吳從周，不定期租賃出租人收回房屋重新建築土地法第一百條第一款「收回重新建築」之意涵，月旦法學教室，第 112 期，頁 19，2012 年 2 月。

求返還房屋所依之條款，於民法設有一定程序要件，自仍應依各該民法之規定踐行，包含：遲延租金之催告(民法第 440 條第 1 項參照)或終止租約之先期通知(民法第 450 條第 3 項參照)並經合法終止後，始有收回該房屋請求權存在²⁴³。

三、租賃住宅管理條例第 10 條

在租賃住宅管理條例第 10 條之規定，同樣規定出租人終止權行使之限制條件：「租賃期間發生下列情形之一者，出租人得提前終止租賃契約，且承租人不得要求任何賠償：一、承租人毀損租賃住宅或附屬設備，不為修繕或相當之賠償。二、承租人遲付租金或費用，達二個月之租額，經催告仍拒繳。三、承租人未經出租人書面同意，將租賃住宅轉租於他人。四、出租人為重新建築而必要收回。五、其他依法律規定得提前終止租賃契約。」相較與土地法第 100 條之規定，有幾點說明：

(一) 承襲一貫終止事由

新法所設定的限制條件初看似較狹隘，土地法第 100 之規定出租人得收回房屋的情形，包含：「收回自住」及「承租人違反租賃契約」。但仔細比較新法尚有第 10 條第 5 款之規定「其他依法律規定得提前終止租賃契約」，所謂其他依法律規定自含土地法第 100 條之規定。因此，兩者大同小異，並無不同。須注意的是，為了強化房客有按時繳交租金與費用的義務，租賃住宅管理條例第 10 條第 2 款之遲延租金的部分，不須抵償擔保金僅須總額達 2 個月，即可終止住宅租賃契約關係²⁴⁴。此外，租賃住宅管理條例第 10 條第 3 款之轉租問題，則不論是房屋一部或全部轉租皆須事前取得同意並以書面為之方謂適法，如前文所述(第三章第三節二、租賃住宅轉租制度)。

²⁴³ 最高法院 87 年度台上字第 1922 號判決：「按不定期房屋租賃，出租人有收回自住之必要時，固得依土地法第一百條第一款之規定隨時收回該房屋。惟該條款之規定僅係限制出租人收回房屋之特別原因而已。如出租人依該條款以收回自住為由請求返還房屋者，自仍應依民法第四百五十條第三項但書之規定向承租人先期通知並經合法終止後，始有收回該房屋請求權存在。」

²⁴⁴ 陳冠甫，新租賃法－關於房屋押租金問題之初探，土地問題研究季刊，第 17 卷第 4 期，頁 77，2018 年 12 月。

(二) 踐行終止程序要件

不同於土地法對於終止程序要件回歸民法規定，租賃住宅管理條例第 10 條第 2 項之特別規定通知程序要件：「出租人依前項規定提前終止租賃契約者，應依下列規定期限，檢附相關事證，以書面通知承租人：一、依前項第一款至第三款及第五款規定終止者，於終止前三十日。二、依前項第四款規定終止者，於終止前三個月。」又，相較民法規定，不定期不動產租賃終止通知期限是依租金給付的定期型態而定(民法第 450 條第 3 項但書參照)，租賃住宅管理條例第 10 條第 2 項不論住宅租賃之期限與租金給付的定期型態皆要求書面及檢附相關事證並統一規定終止通知期限，應於終止前一個月通知為原則。另外，對於同條第 1 項第 4 款「重新建築」之終止理由，由於非承租人之不合宜行為所致，故為了給予承租人較長之寬限期限尋覓居處，要求出租人應於終止前三個月通知。不過，土地法第 100 條第 1 款前段「收回自住」同樣非承租人之不合宜行為之所致，則由於屬同條第 1 項第 5 款之規定，而適用同條第 2 項第 1 款之規定應於終止前一個月通知，如此形成差別待遇之理由為何，不無疑問，實應改進。

(三) 延伸法律適用疑義

對於過去土地法第 100 條之規定適用定期租賃契約與否之爭議，租賃住宅管理條例第 10 條之規定似無特別明文解決之。但從其所稱「租賃期間」，應指「租賃關係存續中」之意，則不論是定期租賃契約或是不定期租賃契約應皆有適用²⁴⁵。另外，針對適用客體的範圍限於租賃住宅，確實能夠避免實務見解不當解釋，可資贊同。

不過，新法不同於土地法第 100 條以「租賃物」收回與否之立法體例，改以「契約關係」作為法定終止事由的規範標的，將延伸法律適用問題，尤其是租賃住宅管理條例第 10 條第 2 款規定。依該規定，承租人遲付租金達兩個月，出租人縱然可以終止契約關係，但出租人卻可能未必能夠收回房屋，蓋從土地法第 100

²⁴⁵ 陳立夫，租賃住宅市場發展及管理條例解說，月旦法學雜誌，第 277 期，頁 36，2018 年 6 月。

條第 3 款之規定，須抵償擔保金後，遲付租金總額達 2 個月方可收回房屋，不免產生適用疑義。從法律適用邏輯出租人必將等待總計 4 個月方可收回房屋，但從新法「強化房客有按時繳交租金與費用的義務」立法目的，則應屬有意擴張出租人之終止權，如此出租人則僅須等待總計 2 個月即可收回房屋。一般而言，遲付租金之承租人大多陷於財務困難，另覓經濟得以承擔之處所須花費較長時間，從保護居住權益而言，應採前說使承租人得有較長寬限期間尋覓處所。綜上所言，整體新法之規定了無新意，並且擴張出租人之終止權，對於承租人之保護實在有限。

四、小結

針對出租人終止權行使的限制，《土地法》補足《民法》對於住宅租賃契約保護的缺漏，卻延伸出是否適用定期租賃之爭議。《租賃住宅管理條例》不但未盡其力明文立法解決爭議，卻擴張出租人之終止權，損及承租人之居住權益的保護機會。不過，隨著主管機關公布住宅租賃契約應約定及不得約定事項第 16 點及房屋租賃定型化契約應記載及不得記載事項第 15 點之內容，直接把出租人終止權之限制條件列為契約內容，則不論是定期租賃契約或不定期租賃契約應當皆有適用空間。為德不卒的是公告版本分別闕漏了「出租人收回自住」及「重新建築」兩款終止事由，導致是否適用定期租賃契約之爭議仍舊存在。

另外，有關針對雙方是否可以提前終止租約的約定，在住宅租賃契約應約定及不得約定事項第 13 點及房屋租賃定型化契約應記載及不得記載事項第 12 點之內容載為「本契約於期限屆滿前，出租人☐得☐不得；承租人☐得☐不得終止租約。」觀其文義，解釋上易生誤會，如：在約定期限屆滿前得終止租約，是否排除適用法定終止事由；反之，當事人約定於期限屆滿前，租賃雙方不得終止租約，是否有終止法定事由仍不可終止，如此解釋將顯不合理。再者，出租人終止權之限制規定性質屬於強制規定，當事人不得有相反之約定，否則依民法第 71 條之規定應

屬無效²⁴⁶。故就合約解釋從契約目的及經濟價值等作全般之觀察，應是指「雙方當事人在本契約於期限屆滿前，除有法定終止事由外，基於雙方合意，得否提前終止。」此部分應修訂明確，較為妥適。

第六項、租期屆滿後續租問題

一、土地法未竟之志

最後，應注意的是承租人在租期屆滿後續租的問題。對此，立法者似注意到承租人租賃屆滿消滅後續租的問題，反面觀察土地法第 100 條之立法體例可以發現巧思，縱然限制收回房屋之情形，相當達到限制出租人終止權行使之情形，但不直接以終止權行使作為規範標的，卻有更深一層涵義，即：使房屋租賃契約關係屆期，出租人未必能夠直接收回房屋。對於此項從土地法第 103 條第 1 款之規定，契約年限屆滿時，出租人得作為收回租用建築房屋之基地之要件，在房屋租賃關係並無相同之條件既可得知²⁴⁷。如此，給予承租人之居住權益的保護有重大意義。

不過，對照耕地三七五減租條例第 19 條之規定：「耕地租約期滿後，有左列情形之一者，出租人不得收回自耕：……」及同條例第 20 條之規定：「耕地租約於租期屆滿時，除出租人依本法條例收回自耕外，如承租人願繼續承租者，應續訂租約。」同樣以租賃物收回與否作為規範標的，擁有續訂租約之明文規定，《土地法》卻付之闕如，實斷送承租人之尋求續定租約之機會。

二、租賃住宅管理條例捨進而退

過去《自用房屋租賃法草案》第 18 條及第 19 條之規定存有解決續租的相關規定。該草案第 18 條之規定：「租賃期限期滿後，承租人得請求出租人為契約期限之更新。前項更新期限為二年。租賃期限期滿前，出租人得催告請求承

²⁴⁶ 最高法院 72 年台上字第 283 號判例：「市場攤位租賃為房屋租賃之一種，而房屋租賃如約定承租人欠租時，出租人得逕行終止租約，與土地法第一百條第三款之強制規定有違，依民法第七十一條規定，此項約定應屬無效。」最高法院 88 年台上字第 3306 號、89 年台上字 238 號判決同旨。

²⁴⁷ 謝哲勝，前揭註 92，頁 264-265。

租人確答是否為契約期限之更新。」及第 19 條之規定：「前條情形，出租人除有自己使用之必要情形，或具有其他正當事由者為限，方得拒絕租賃契約期限之更新。」草案第 18 條之租約更新依立法理由係指契約期限之更新，亦即僅發生期限變更之效果，其餘如租金及其他條件並未隨同變更，與民法第 449 條之規定有間²⁴⁸。並且自租賃期滿後，承租人得向出租人主張契約期限之更新，出租人非有必要理由，不能拒絕承租人所提延長租約之提議。

先不論該草案第 18 條及第 19 條之規定可能存在的問題，此項立法確實滿足承租人之尋求續定租約之機會²⁴⁹。然而，在《租賃住宅管理條例》不但未納入參考，並且整體捨棄土地法第 100 條之立法例，改以住宅租賃契約關係作為終止行使的規範標的，徹底拒絕承租人追求穩定持續住宅租賃關係。

三、住宅租賃政策未來方向

目前，從住宅法第 15 條、第 23 條到租賃住宅管理條例第 17 條觀察現行住宅租賃政策，主要致力於透過租稅優惠鼓勵住宅所有權人將空屋提供予租賃住宅市場。換言之，我國住宅租賃政策僅停留在租賃住宅市場的建制，尚未對於有關人民居住權益作出更周詳的細部規劃，稍嫌可惜。租期屆滿後有關續約之問題，實然是保障居住權益的重要一環，雖然涉及出租人財產權之高度限制，但仍然可以透過給予出租人補償措施，如：租稅優惠、折舊津貼，以換取承租人追求穩定持續住宅租賃關係。

第七項、小結

目前國家賦予住宅租賃契約具有對抗之效力及限制出租人終止權之行使以保護承租人，此項立法政策符合憲法第 23 條比例原則之規定，雖然各存有法律適用上的疑慮，包含：在於租期逾五年或未定期限者須踐行公證的要求、土地法第 100

²⁴⁸ 立法院第 8 屆第 7 會期第 11 次會議議案關係文書院總第 447 號委員提案第 17687 號，取自 <https://lis.ly.gov.tw/lgcgi/lgmeetimage?cfc7cfc8cecec8cdc5cec8d2cdcb>。(最後瀏覽日：01/16/2019)

²⁴⁹ 該草案之立法評析，詳見：林柏安，台日自用房屋租賃法規比較研究—以傳統借家制度為中心，德明學報，第 41 卷第 1 期，頁 87-105，2017 年 6 月。

條之規定是否適用所有房屋租賃與定期租賃契約及同條第 1 款「收回自住」解釋過寬等，但在保護承租人追求穩定的住宅租賃關係具有重大意義。

然而，租期屆滿後續約問題，實然是保障居住權益的重要一環，雖然涉及人民財產權之高度限制，但仍然可以透過給予出租人補償措施，以換取承租人追求穩定持續住宅租賃關係。不過，《租賃住宅管理條例》選擇以保守的方式，僅停留在租賃住宅市場建制初期，未能貫徹國家對於履行人民居住權益的決心，稍嫌可惜。



\

第六章 德國住宅租賃法制探討

第一節 住宅租賃政策的發展

第一項、政策起源

住宅租賃政策在德國一直位居國家發展的重要位置，回顧德國住宅租賃政策主要受到政治事件及住宅市場的影響，而實施不同程度的管制。二十世紀初期，在德國雖然存有住宅租賃的相關法律，但受自由主義的風潮，多以崇尚雙方的自由意志為主²⁵⁰。然而隨著兩次世界大戰結束，由於全國住宅嚴重受損，住宅市場產生嚴重的供需失衡，是德國政府戰後首要面對的社會問題²⁵¹。因此，德國政府開始著手制定一系列居住政策以解決問題，其主要政策的內涵有三：全面管控住宅市場、限制租金收入及租賃契約終止權²⁵²⁻²⁵³。其中，德國政府介入當事人租賃住宅關係是作為管控住宅市場的主要手段，亦是德國介入住宅租賃關係的濫觴。

第二項、規制基礎

在過去德國政府一直透過修訂特別法作為管制住宅租賃之依據，而隨著法律規範逐漸複雜，為了簡化和重整租賃規範，於 2001 年 6 月 19 日通過「租賃法制革新法」(Mietrechtsreformgesetz，全名為：Gesetz zur Neugliederung, Vereinfachung und Reform des Mietrechts)，以包裹立法之方式大幅度修訂《德國民法》(BGB，全名為：Bürgerliches Gesetzbuch)租賃一節之規定，包含：全面改編條號、重新調整規範架構等，並於同年 9 月 1 日生效施行，成為住宅租賃契約主要規範依據²⁵⁴。又，2015 年再次通過「租賃法修正案」(Mietrechtsnovellierungsgesetz，原名為：Gesetz zur Dämpfung des Mietanstiegs auf angespannten Wohnungsmärkten und zur

²⁵⁰ Schmidt-Futterer/Blank, BGB, 13. Aufl., 2017, §573 Rn. 1-2a

²⁵¹ Schmidt-Futterer/Blank, BGB, 13. Aufl., 2017, §573 Rn. 1-2a

²⁵² 所謂全面管控住宅市場乃指戰後全國住宅歸公、興建社會住宅，實施住宅配給制度，遲至 1950 年代末逐步市場化。

²⁵³ Schmidt-Futterer/Blank, BGB, 13. Aufl., 2017, §573 Rn. 1-2a

²⁵⁴ BGBl I 2001 Nr. 28 vom 25.06.2001 S. 1149

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?start=%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl115s0610.pdf%27%5D#_bgbl_%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl101s1149.pdf%27%5D_1548413458241 (最後瀏覽日期：01/25/2019)

Stärkung des Bestellerprinzips bei der Wohnungsvermittlung, vgl, BGBL I S. 1149)加入「租金價格上限機制」(Mietpreisbremse)並授權地方政府得指定緊張住房市場區域，以便適用租金上限機制之規定²⁵⁵。

第二節 住宅租賃契約的規範制度

《德國民法》租賃一節依據用益型態區分為使用租賃(Mietvertrag)及收益租賃(Pachtvertrag)，並且分設使用租賃總則(Allgemeine Vorschriften für Mietverhältnisse)、關於住宅之使用租賃關係(Mietverhältnisse über Wohnraum)及其他物之使用租賃關係(mietverhältnisses über andere Sachen)(德國民法第 535 條以下參照)²⁵⁶。住宅租賃契約為居住使用為目的並非收益使用，故分類型態屬於使用租賃契約，適用德國民法第 549 條至第 577 條之 1 關於住宅之使用租賃關係章節之規定。

又，關於住宅之使用租賃關係章節(以下為行文方便將使用租賃皆稱為住宅租賃)主要考量住宅使用之性質多設有保護承租人規定，但非有保護之必要或有受有其他法律規範，如：租期短暫非供承租人長期使用，或承租對象為公法法人或福利組織締約前向承租人提示住宅之特殊使用目的及其他學生宿舍或青年旅館之住宅，則排除適用保護承租人之相關規定²⁵⁷。

²⁵⁵ BGBL I 2015 Nr. 16 vom 27.04.2001 S. 610
https://www.bgb1.de/xaver/bgb1/start.xav?start=%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgb1115s0610.pdf%27%5D#_bgb1_%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgb1115s0610.pdf%27%5D_1548415201271 (最後瀏覽日期：01/25/2019)

²⁵⁶ 有關本文之德國民法譯文，取自：國立臺灣大學法律學院·財團法人台大法學基金會，德國民法(上)—總則編、債編、物權編，元照，2016 年 10 月 2 版。

²⁵⁷ 德國民法第 549 條：「住屋使用租賃關係，如第五百四十九條至第五百七十七條之一無不同之規定者，適用第五百三十五條至第五百四十八條規定(第一項)。關於提高租金之規定(第五百五十七條至第五百六十一條)與對於使用租賃關係終止及住宅所有權創設之保護承租人規定(第五百六十八第二項、五百七十三條、第五百七十三條之一、第五百七十三條之四第一項、第五百七十四條至第五百七十五條，第五百七十五條之一第一項、第五百七十七條及第五百七十七條之一)不適用於下列使用租賃關係：1.僅為短暫使用而出租之住屋。2.住屋為出租人自行居住之住宅部分，且主要由出租人裝潢設施及物品者；但以其住屋非供承租人長期與其家庭或與其有持續共同家計關係之人使用者為限。3.公法法人或經承認為福利事業之私法組織，為交付與有迫切住宅需求者所出租之住屋，但以於締約時已向承租人提示住屋之特殊使用目的及前開規定之例外情形為限(第二項)。第五百五十七條至第五百六十一條、第五百七十三條、第五百七十三條之一、第五百七十三條之四第一項、第五百七十五條、第五百七十五條之一第一項、第五百七十七條、第五百七十七條之一規定，於學生宿舍或青年旅館之住屋不適用之(第三項)。」

第一項、租金管制規範

一、德國法之租金概念

(一) 意義

德國住宅租賃契約的租金在概念上得區分為基本租金(Grundmiete)及作業費用(Betriebskosten)，從德國民法第 551 條擔保金(Begrenzung und Anlage von Mietsicherheiten)之規定及第 556 條以下有關租金(Miete)之規定既可得知²⁵⁸。基本租金指租賃住宅使用的對價，而作業費用則是出租人提供租賃等其他輔助服務的成本²⁵⁹。依德國民法第 556 條第 2 段之規定，作業費用指所有人或地上權人因其所有權或不動產之地上權，或就建築物、附屬建築物、設施、設備及土地為符合其特定性之使用，而持續發生之費用²⁶⁰。

(二) 區分實益

原則上，承租人支付的租金應當包含與該房屋有關的任何作業費用，出租人僅在相關的住宅租賃契約中有明確規定的情況下，方可要求承租人支付作業費用²⁶¹。因此，德國民法在租金管制上並不區分基本租金及作業費用。不過，鑑於作業費用之約定仍然屢見不鮮，德國民法在第 556 條、第 556 條之 1 有作業費用之

²⁵⁸ 德國民法第 551 條第 1 項：「使用承租人為履行其義務，而應對使用出租人提供擔保者於不違第三項第四段規定時，該擔保最高得為扣除以總額或預付之經核實作業費用後之每月租金之三倍」及第 556 條第 1 項第 1 段：「契約當事人得約定，由使用承租人負擔作業費用。」

²⁵⁹ Schulze/Dörner/Ebert/Hoeren/Kemper/Saenger/Scheuch/Schreiber/Schulte-Nölke/Staudinger/Wiese, Handkommentar-BGB, 10. Aufl., 2019, BGB §556 Rn. 1-7.

²⁶⁰ 德國民法第 556 條第 1 項第 2 段：「作業費用指所有人或地上權人因其所有權或不動產之地上權，或就建築物、附屬建築物、設施、設備及土地為符合其特定性之使用，而持續發生之費用。」

²⁶¹ Lindner-Figura/Oprée/Stellmann, Geschäftsraummiete, 4. Aufl., 2017, Kapitel 10. Die Miete Rn. 2-3.

編列及結算費用之規定^{262、263}。此外，德國民法第 560 條則明文實施現代化措施 (Modernisierungsmaßnahmen) 後有關作業費用變更之要件規定^{264、265}。

二、租金價格上限機制

依德國民法第 556 條之 4 規定：「住宅租賃契約經訂立，且該住宅位於第二項法規命令所定激烈競爭之居住市場區域者，租賃關係開始時之租金，比照當地通常參考租金(第五百五十八條第二項)，至多不得逾百分之十。」為了防止出租人在住宅租賃契約締結時，向承租人要求約定過高租金，故對於租金容許的定價制

²⁶² 德國民法第 556 條第 2 項至第 4 項：「除另有規定外，契約當事人得以約定，為一次給付或預付該經核實之作業費用。作業費用之預付，僅得約定合理之數額(第 2 項)。作業費用之預付，應每年結算之；於此情形，應遵守經濟性原則。結算期間終了後，最遲應於十二個月期間屆滿前，對使用承租人為結算之通知。於該期間屆滿後，使用出租人不得行使額外請求。但遲延之行使不可歸責於使用出租人者，不在此限。使用出租人無部分結算之義務。使用承租人最遲應於結算到達後十二個月期間屆滿前，將該結算之抗辯告知使用出租人。於該期間屆滿後，使用承租人不得再為抗辯。但遲延之抗辯不可歸責於使用承租人者，不在此限(第 3 項)。使用承租人受有不同於第一項，第二項第二段或第三項規定之不利約定者，其約定無效(第 4 項)。」

²⁶³ 德國民法第 556 條之 1：「契約當事人未為約定者，除另有規定外，作業費用按居住面積之部分，而為分攤。作業費用取決於已計入之使用承租人消費，或已計入之使用承租人原因者，應考量不同消費或不同原因，而為分攤(第 1 項)。契約當事人另有約定者，使用出租人得以文字方式表示該作業費用未來得不同於該約定，全部或一部考量已計入之不同消費或不同原因，而為分攤。該意思表示，僅得於結算期間開始前為之。費用迄今已包含於租金之內者，應適當調降其租金(第 2 項)。使用承租人受有不同於第二項規定之不利約定者，其約定無效(第 3 項)。」

²⁶⁴ 現代化措施依德國民法第 555 條之 2 乃指對建築物為以下之變更：「1，可持續節約租賃物之末端能源（能源現代化）。2 不屬第一款規定之能源現代化，但可持續節約非再生之初級能源或可持續為氣候之保護者。3，可持續減少水之使用。4，可持續提高租賃物之使用價值。5，可長期改善通常居住狀況。6，因不可歸責於使用出租人之事由而實施，且不屬於第五百五十五條之一規定之保存措施，或 7，可增加新住屋。」

²⁶⁵ 德國民法第 560 條：「於作業費用總額之情形，使用出租人得將提高之作業費用，以文字方式表示按比例分攤於使用承租人，但以租賃契約有約定者為限。該表示僅以指明並解釋分攤之原因者為限，始生效力(第 1 項)。使用承租人就應由其分攤之部分，自前項表示下個月之次月開始日負其責任。該表示係依據已溯及提高作業費用者，該表示於作業費用提高時生效；至多溯及於該表示之前一年之始日，但以使用出租人自知該提高情事後三個月內為該表示者為限(第 2 項)。作業費用減少者，作業費用總額應自減少時起，相對降低之。作業費用之減少應即時通知使用承租人(第 3 項)。有預付作業費用之約定者，任一契約當事人得於結算後，以書面表示調整至適當數額作業費用之變更，應注意經濟性原則(第 4 項)。使用承租人受有不利益之約定者，其約定無效(第 5 項)。」

定上限。違反規定者，依同法第 556 條之 7 規定當租金超過容許上限時無效，並準用不當得利之效果將該支付超過之租金返還於承租人²⁶⁶。

所謂激烈競爭之居住市場區域係指邦政府經國會授權以法規命令訂定為期五年之激烈競爭居住市場區域²⁶⁷。構成激烈競爭之居住市場區域，指鄉鎮市或部分鄉鎮市以相當條件租屋予民眾之充分照顧而發生特別危險者²⁶⁸。所謂特別危險之情形(Besonders gefährdet)，指租金上升幅度明顯高於聯邦平均值、家計生活費用之平均租金負擔明顯高於聯邦平均值、居住人口成長但未因新建築活動而建造必要住屋，或因較大需求而少有空屋之情況²⁶⁹。

三、租金漲幅的控制

其次，德國民法除了防止出租人在締約之初強迫承租人接受高額租金外，對於租賃關係存續當中同時避免租金漲幅過高，導致承租人陷於困頓，制定相關規範。原則上對租金調整約定，除當事人有特約外，依法定情形為之²⁷⁰。

²⁶⁶ 德國民法第 556 條之 7 第 1 項：「約定違反本次目規定，不利於使用承租人者，無效。關於租賃開始時之租金上限，僅於租金超過該所容許之租金時，始適用前段規定。使用出租人應依不當得利返還之規定，將該支付超過之租金返還予使用承租人。第八百十四條及第八百十七條規定，不適用之。」、第 814 條：「以履行債務為目的而為之給付，如給付人明知其無給付之義務，或給付係基於履行道德上義務或合於禮儀上所為之考量者，不得請求返還。」及第 817 條：「給付目的之訂定，如使受領人因其受領而違反法律禁止規定或善良風俗者受領人負返還之義務。該違反亦應由給付人負責者，不得請求返還。但給付係以負擔債務為內容者，不在此限；為履行該債務所為之給付，不得請求返還。」

²⁶⁷ 德國民法第 556 條之 4 第 2 項第 1 段：「邦政府經授權以法規命令訂定為期五年激烈競爭之居住市場區域。」

²⁶⁸ 德國民法第 556 條之 4 第 2 項第 2 段：「鄉鎮市或部分鄉鎮市以相當條件租屋予民眾之充分照顧而發生特別危險者，構成激烈競爭之居住市場區域。」

²⁶⁹ 德國民法第 556 條之 4 第 2 項第 3 段：「即如下列之情形：1，租金上升幅度，明顯高於聯邦平均值 2，家計生活費用之平均租金負擔，明顯高於聯邦平均值 3，居住人口成長，但未因新建築活動而建造必要住屋或，因較大需求而少有空屋之情況。」

²⁷⁰ 德國民法第 557 條：「於使用租賃關係之期間內，當事人得約定提高租金(第 1 項)。對於租金數額之未來變更，契約當事人得依第五百五十七條之一規定，約定為分級租金，或依第五百五十七條之二規定，約定為指數租金(第 2 項)。於其他情形，使用出租人僅得依第五百五十八條至第五百六十條規定之標準請求提高租金。但租金之提高，依當事人約定所排除，或因情事所生之排除者，不在此限(第 3 項)。使用承租人受有不利益約定者，其約定無效(第 4 項)。」

(一) 意定情形

住宅租賃契約之當事人得約定租金調漲及其模式，依調漲模式分為「分級式租金」(Staffelmiete)或「指數式租金」(Indexmiete)，由當事人擇其一而定(德國民法第 557 條第 1 項及第 2 項參照)。

1. 分級式租金(德國民法第 557 條之 1 參照)

分級式租金係指當事人以書面就租金或租金調整額度在不同特定之時間為不同數額之約定。每次租金調整後至少須維持一年以上時間不變，又當事人約定採分級式租金模式，即排除德國民法第 558 條至 559 條之 2 法定情形調整租金之適用²⁷¹。

2. 指數式租金(德國民法第 557 條之 2 第 1 項參照)

指數式租金則係指當事人以書面約定，租金依據聯邦統計局(Das Statistische Bundesamt)所公布之德國全國私人生活家計生活支出所確認之物價指數(Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte in Deutschland)而定²⁷²。故當物價指數變更時，出租人須以書面表示租金或租金調整之額度，並自通知到達後下個月之次月開始²⁷³。每次租金調整後至少須維持一年以上時間不變，但不可歸責出租人實行現代化措施而調漲租金或實行現代化措施變更作業費用，不在此限²⁷⁴。又當事人約定採指數式租金模式，同樣排除德國民法第 558 條法定情形調整租金之適用²⁷⁵。

²⁷¹ 德國民法第 557 條之 1 第 1 項及第 2 項：「租金得就特定期間，以書面為不同數額之約定；於其約定中，應就各該租金或各該租金之提高，以金額表示之（分級租金）(第 1 項)。租金每次至少應維持一年不變。於分級租金期間，不得依第五百五十八條至第五百五十九條之二規定提高租金(第 2 項)。」

²⁷² 德國民法第 557 條之 2 第 1 項：「契約當事人得以書面約定，依聯邦統計局為計算所有德國私人生活支出所確認之物價指數，而定其租金（指數租金）。」

²⁷³ 德國民法第 557 條之 2 第 3 項：「依第一項規定為租金之變更，應以文字方式表示。於此情形，其已發生之物價指數變更，及各該租金或租金之提高，應載明金額。變更之租金，應自該表示到達後下個月之次月開始時，支付之。」

²⁷⁴ 德國民法第 557 條之 2 第 2 項：「指數租金有效期間內，除第五百五十九條至第五百六十條所定之租金提高者外，租金每次至少應維持一年不變。第五百五十九條規定提高租金，以出租人因不可歸責於自己之事由，而實施建築措施者為限。依第五百五十八條規定提高租金，排除之。」

²⁷⁵ 同前揭註 274。

(二) 法定情形

當事人未約定租金調整條款的情形，出租人若須調整租金僅得依德國民法第 558 條或第 559 條以下之規定，在特定情況下方能調整。同時，承租人在調整租金意思表示到達後再二個月之末日屆滿前，以再二個月之末日為終止期間，享有特別終止租賃關係之權利²⁷⁶。

1. 租金提高至當地通常之參考租金

(1) 實體要件

依德國民法第 558 條之規定，出租人在租金維持 15 個月不變後，得依據「當地通常之參考租金」（ortsübliche Vergleichsmiete）請求承租人同意租金之提高，調整之幅度上限於三年內不得超過百分之二十²⁷⁷。所謂「當地通常之參考租金」係指在同一或類似之鄉鎮市內，就種類、大小、設備、品質及地點相當之住宅，於過去四年間所約定或改變之通常報酬²⁷⁸。

(2) 程序要件

出租人請求調整租金須以書面（Textform）為之並應說明理由²⁷⁹。依德國民法第 558 條之 2 規定承租人同意說明內容，自請求到達後第三之日曆月開始承擔新租金之給付義務²⁸⁰。反之，承租人未於第二之日曆月屆滿前同意，出租人得於第

²⁷⁶ 德國民法第 561 條：「使用出租人依第五百五十八條或第五百五十九條規定主張提高租金者，使用承租人得於使用出租人之表示到達後再二個月之末日屆滿前，以再二個月之末日為終止期間，特別終止租賃關係。使用承租人終止契約者，不生租金提高之效力(第 1 項)。使用承租人受有不利益之約定者，其約定無效(第 2 項)。」

²⁷⁷ 德國民法第 558 條第 1 項：「租金於應提高之時，已維持十五個月不變者，使用出租人得請求將租金提高至當地通常之參考租金。該提高租金之請求，最先得於前次租金提高一年後為之。第五百五十九條至第五百六十條規定之提高租金，不予斟酌。」第 3 項前段：「依第一項規定為租金之提高，於三年內不得超過百分之二十（提高上限）。但依第五百五十九條至第五百六十條提高租金者，不在此限。」

²⁷⁸ 德國民法第 558 條第 2 項：「稱當地通常之參考租金，指於鄉鎮市或與鄉鎮市相當之地區，就種類，大小，設備，品質及地點相當之住屋，於過去四年間所約定或變更之通常報酬，但不含第五百六十條規定之提高租金。2 租金額係以法律規定或與社會住屋補助同意有關而確定之住屋者，不在此限。」

²⁷⁹ 德國民法第 558 條之 1 第 1 項：「依第五百五十八條規定請求提高租金，應以文字方式向使用承租人表示，並說明理由。」

²⁸⁰ 德國民法第 558 條之 2 第 1 項：「使用承租人同意提高租金者，自提高租金之請求到達後第三之日曆月，就提高之租金負其義務。」

二之日曆月屆滿日三個月內訴請同意²⁸¹。又出租人未依法踐行通知，出租人得於訴訟中補正，承租人享有二個日曆月之同意期間²⁸²。

(3)說明理由內涵

其中，所謂說明之理由出租人得以「租金一覽表」（Mietspiegel）、「租賃資料庫」（Mietdatenbank）、官方選任之專家並經其宣誓之意見或舉出三幢類似住宅之相當對價作為其他能說明當地一般租金情形之佐證資料²⁸³。一般而言，租金一覽表依製作情形不同又分為兩種：「租金一覽表」及「經認可之租金一覽表」。「租金一覽表」指由鄉鎮市或出租人與承租人之利益代表人共同製作或承認所公告之當地通常參考租金一覽表²⁸⁴。其當地的範圍得就一個或數個鄉鎮市區域，或就數個鄉鎮市之部分而製作²⁸⁵。

相對於「經認可之租金一覽表」是指鄉鎮市或出租人與承租人之利益代表人確認依科學原則製作之租金一覽表，有效期限為四年²⁸⁶。但兩種租金一覽表者兩年應隨市場發展更新一次，又按經認可之租金一覽表之性質，並非確認者所制作，故得以抽樣調查或經聯邦統計局所公布之德國全國私人生活支出所之物價指數發展為參考基礎²⁸⁷。另外，租金資料庫指為確定當地通常之參考租金，而持續

²⁸¹ 德國民法第 558 條之 2 第 2 項：「使用承租人自請求到達後，未於第二之日曆月屆滿前同意提高租金者，使用出租人得訴請同意。該訴訟應於接續三個月內提起之。」

²⁸² 德國民法第 558 條之 2 第 3 項：「於訴訟前所為提高租金之請求，不符合第五百五十八條之一規定者，使用出租人得於訴訟中補正，或排除該提高租金請求之瑕疵。於此情形，使用承租人亦享有第二項第一段規定之同意期間。」

²⁸³ 德國民法第 558 條之 1 第 2 項：「該理由得特別以下列相關之情事說明：1，租金一覽表（第五百五十八條之三，第五百五十八條之四）。2，租金資料庫之資訊（第五百五十八條之五）。3，官方選任並經宣誓之專家所提供附理由之專家意見。4，就個別類似住宅之相當對價；於此僅須舉出三幢住宅。」

²⁸⁴ 德國民法第 558 條之 3 第 1 項：「租金一覽表，指當地通常參考租金之一覽表，但以該一覽表由鄉鎮市或由使用出租人與使用承租人之利益代表人所共同製作或承認者為限。」

²⁸⁵ 德國民法第 558 條之 3 第 2 項：「租金一覽表，得就一個或數個鄉鎮市區域或就數個鄉鎮市之部分而製作」

²⁸⁶ 德國民法第 558 條之 4 第 1 項：「經認可之租金一覽表，指依公認科學原則製作，且經鄉鎮市或使用出租人與承租人之利益代表人確認之租金一覽表。」及同條第 2 項後段：「經認可之租金一覽表應於四年後重新製作。」

²⁸⁷ 德國民法第 558 條之 3 第 3 項：「租金一覽表應以二年為間隔，因應市場之發展而調整。」及第 558 條之 4 第 2 項前段：「經認可之租金一覽表應以二年為間隔，因應市場之發展而調整。於此情形，得以抽樣調查或經聯邦統計局就德國所有私人生活水準計算之物價指數發展為基礎。」

管理之租金彙編，該彙編並經鄉鎮市或出租人與承租人之利益代表人共同管理或承認，且就個別住宅可得而知當地通常參考租金之資訊²⁸⁸。

2.現代化措施調漲租金

(1)實體要件

又租賃住宅實施現代化措施，出租人得因增加租賃住宅之價值而為租金之提高，並且租賃住宅年租金調高之幅度，不得高於出租人為實施現代化措施所支出費用之百分之十一²⁸⁹。然而依據德國民法第 559 條第 4 項之規定，租賃住宅因實施現代化措施所增加之作業費用對於承租人係屬嚴苛，且衡量出租人之利益非謂正當，則不得提高租金，但租賃住宅僅改變為一般通常之情況，或現代化措施之實施，係因不可歸責於出租人之事由，不在此限²⁹⁰。

(2)程序要件

現代化措施調漲租金仍須以書面通知，自表示到達後第三個月開始承擔新租金之給付義務²⁹¹。所謂表示到達須以書面就發生之現代化措施費用作為計算基礎並為說明，始發生效力²⁹²。又，出租人未依法踐行現代化措施之通知，或實際提高租金較前述通知說明高過百分之十，則新租金之給付義務延長六個月開始²⁹³。

²⁸⁸ 德國民法第 558 條之 5：「租金資料庫，指為確定當地通常之參考租金，而持續管理之租金彙編；該彙編係經鄉鎮市或使用出租人與使用承租人之利益代表人共同管理或承認，且就個別住宅可得而知當地通常參考租金之資訊。」

²⁸⁹ 德國民法第 559 條第 1 項：「使用出租人依第五百五十五條之二第一款，第三款，第四款，第五款或第六款規定實施現代化措施者，該年租金得提高至住宅所支出費用之百分之十一。」

²⁹⁰ 德國民法第 559 條第 4 項：「非於斟酌該預計之未來作業費用可能對使用承租人係屬嚴苛，且其嚴苛於衡量使用出租人正當利益後，仍不能認為正當者，租金不得提高：依第一段規定所為之衡量，於下列情形排除之：1，租賃物僅改變為一般通常之情況，或 2，現代化措施之實施，係因不可歸責於使用出租人之事由者。」

²⁹¹ 德國民法第 559 條之 2 第 2 項前段：「使用承租人就提高之租金，自表示到達後第三個月開始時，負其責任。」

²⁹² 德國民法第 559 條之 2 第 1 項：「第五百五十九條規定之租金提高，應以文字方式向使用承租人表示。該表示僅以已發生之費用為基礎而計算提高之租金，且符合第五百五十九條及第五百五十九條之一規定要件而說明者，始生效力。3 第五百五十五條之三第三項規定，準用之。」

²⁹³ 德國民法第 559 條之 2 第 2 項後段：「於下列情形，其期限延長六個月：1，使用出租人未依第五百五十五條之三第一項，第三項至第五項規定通知使用承租人現代化措施，或 2，事實上提高之租金較其通知者超過百分之十時。」

第二項、租賃擔保規範

一、「租賃擔保」額度管制

(一) 管制目的

在過去實務運作出租人之留置權受限於執法困難以及留置物品無抵償價值造成出租人之損害難以順利獲償，租賃擔保逐漸成為現實交易常見的手段，依德國民法第 551 條第 1 項之規定：「承租人為履行其義務，而應對出租人提供擔保者，於不違反第三項第四段規定時，該擔保最高得為扣除以總額或預付之經核實之作業費用後之每月租金之三倍」以基本租金為計算基礎之三倍，主要考量承租人須保留一定資金準備住宅事務，包含：搬家費、裝修費、房仲介紹費等，故不宜任由出租人無限制索取擔保²⁹⁴。另外，為避免租金與租賃擔保同時給付造成一次須負擔將近四個月的租金額度，為減輕承租人負擔，故租賃擔保支付的方式得分期之²⁹⁵。

(二) 違反效果

又，當出租人超收允許的最大額度時，按德國實務一貫見解為無效，承租人可以要求返還超額的部分，然而部分學者認為出租人超收允許的最大額度是否即為無效，並非無疑，其從保護承租人締約前階段準備住宅事務資金之目的解釋及德國民法第 554 條之 1 承租人要求出租人實行無障礙空間時，出租人得請求附加擔保之體系解釋觀察，在契約存續期間隨著出租人損益風險之增加，在特定情況下，如承租人之要求超出契約義務範圍並將為出租人帶來額外風險，應容出租人

²⁹⁴ Börstinghaus, Zusätzliche Mietsicherheit infolge Änderung des Mietvertrags im Mieterwunsch?, NZM. 2008, S. 558.

²⁹⁵ 德國民法第 551 條第 2 項：「以支付金錢作為擔保者，使用承租人得將之分為每月三等分而分期支付之。第一期於使用租賃關係開始時到期。其他期於其後各期支付租金時到期。」

有收取額外擔保金之權利^{296、297}。

二、現金擔保

觀察德國民法第 551 條第 3 項之規定，德國民法原則上要求出租人以現金作為擔保而交付與自己之金額，除當事人另有約定，以三個月為終止期限之通常利率存於銀行。但不論存放的方式為何，出租人應將其財產與該存放款分離，且收益應歸屬於承租人，並作為擔保之一部分。同條第 4 項之規定，承租人受有不利利益約定者，其約定無效。由此觀之，德國民法以現金作為擔保時，採取以擔保為目的之「押金模式」，但有別於我國現實交易出租人並無取得自由使用之權限，並且德國出租人原則上負有承擔支付利息之義務²⁹⁸。

三、「租賃擔保」性質

(一) 舊法時期

在德國租賃擔保性質的認定，同樣影響是否有所有權讓與不破租賃適用的爭議。在過去租賃擔保性質認定為擔保條件，與租賃契約獨立分開²⁹⁹。因此，立法者為避免法律關係複雜化，賦予租賃住宅受讓人請求權基礎，使其得對於原出租人請求承租人已提供之擔保，觀德國舊民法第 580 條適用第 572 條之規定：「讓與土地之承租人為其義務之履行已提供擔保者，受讓人加入因此而生之權利關係。受讓人僅在其已受擔保之交付，或者對出租人承擔返還之義務者，始負返還擔保之義務。」即可推知³⁰⁰。因此，租賃住宅受讓人對於租賃擔保是否負返還責任，視受讓人取得租賃擔保與否而定，承租人原則上只能對於已經取得租賃擔保之原

²⁹⁶ 德國民法第 554 條之 1：「承租人有正當利益者，得請求出租人同意為身障者得利用或接近租賃物所必要之建築變更或其他設施。出租人保持租賃物或建築物不變之利益，大於承租人使租賃物為身障者利用之利益時，出租人得拒絕同意之。於此情形，亦應斟酌同一建築物中其他承租人之正當利益(第一項)。出租人之同意，得以恢復原狀所提供相當之附加擔保為條件。第五百五十一條第三項及第四項規定，準用之(第二項)。承租人受有不同於第一項規定之不利益約定者，其約定無效。」

²⁹⁷ Börstinghaus, Zusätzliche Mietsicherheit infolge Änderung des Mietvertrags im Mieterwunsch?, NZM. 2008, S. 562-563.

²⁹⁸ Schmidt-Futterer/Blank, BGB, 13. Aufl., 2017, §551 Rn. 1-5.

²⁹⁹ 吳從周，前揭註 201，頁 21。

³⁰⁰ 吳從周，前揭註 201，頁 19-20。

出租人請求返還，而不得對受讓人主張之。

(二) 新法時期

這樣的見解同樣受到德國學界的反撲，其認為租賃擔保絕對是租賃契約之部分，並且有德國民法第 566 條(相當於我國民法 425 條)所有權讓與不破租賃之適用³⁰¹。因此，德國民法在 2001 年 9 月 1 日修正租賃法時，將相關條文移列並修改為現行法第 566 條之 1：「已讓與住宅之承租人就其義務之履行，為出租人提供擔保時，受讓人加入因此而生之權利及義務關係(第 1 項)。租賃關係終了時，如承租人不能自受讓人處取得擔保時，出租人仍繼續負返還之義務(第 2 項)。」之規定³⁰²。

本條規定與上開舊法最大之區別，將受讓人加入之關係，除「權利」外包括「義務」，其目的在於貫徹所有權讓與不破租賃之法律效果以保護承租人，及將第 2 項新增訂為「租賃關係終了時，如承租人無法自受讓人處取回擔保時，出租人仍繼續負返還之義務。」換言之，受讓人原則上負有返還租賃擔保之義務，並且縱使原出租人已經將租賃擔保交付予受讓人，但只要承租人尚未自受讓人處取得租賃擔保，原出租人的返還責任即未因此而消滅，藉以轉由原出租人承擔嗣後受讓人給付不能的風險³⁰³。因此，整體規定的保護重點已從受讓人轉移為承租人³⁰⁴。

第三項、穩定持續契約關係的手段

一、出租人終止權之限制

在德國民法租賃一節針對終止權依據終止原因是否牽涉重大事由區分為一般終止(ordentliche Kündigung)與特別終止(außerordentliche Kündigung)，兩者最大區別實益在於一般終止權之行使有一定期限限制，特別終止權之行使則無限制，從德國民法第 573 條之 3 第 1 項一般終止權之規定：「終止最遲應於日曆月之第三工作日至該日曆月之下個月次月屆滿止為之。住屋交付後經過五年及八年，使用出

³⁰¹ 吳從周，前揭註 201，頁 21。

³⁰² 吳秀明，前揭註 29，頁 417。

³⁰³ Wetekamp, Mietsachen, 4. Aufl., 2007, Kapitel 3. Die Mietkaution Rn. 64-70.

³⁰⁴ 吳秀明，前揭註 29，頁 417。

租人終止契約之期限，各延長三個月。」既可得知。

(一) 特別終止權

1. 重大事由

特別終止權主要考量契約當事人在繼續契約關係中，有時須具備一定程度之基礎、能力與相互的信賴作為前提始有可能，一旦不具備前提要件，則當事人間根本不可能成立契約關係，故不限制當事人權利行使期間。依德國民法第 543 條第 1 項存有原則性之規定，即各當事人得基於重大事由，特別不定期終止住宅租賃關係³⁰⁵。所謂重大事由指衡量當事人之可歸責事由及衡量雙方之利益後，不能期待為終止之人繼續住宅租賃關係至使用租賃期限屆滿，或以其他方式致住宅租賃關係消滅者，即為有重大事由³⁰⁶。

2. 列舉事由

為避免重要事由之舉證困難，德國民法第 543 條第 2 項列舉相關重要事由，包含：出租人未按時提供或剝奪租賃物、承租人未盡其應盡之注意而顯著危害租賃物或未經授權將之交付與第三人致顯著損害出租人之權利者，以及連續二期遲延給付租金或長於二期之期間內遲延給付租金，其遲付之租金數額達二個月之租額³⁰⁷。

又，基於住宅租賃契約之法律關係德國民法第 569 條第 1 項至第 2 項之 1 增訂重大事由之規定，包含：承租住屋之使用將嚴重危害健康、契約當事人之一方持續侵擾住宅安寧，承租人依第五百五十一條規定提供擔保之遲延，其數額達一

³⁰⁵ 德國民法第 543 條第 1 項前段：「各當事人得基於重大事由，特別不定期終止使用租賃關係。」

³⁰⁶ 德國民法第 543 條第 1 項後段：「當衡量個別情形下之所有情事，即如契約當事人之可歸責事由，及衡量雙方之利益後，不能期待為終止之人繼續使用租賃關係至使用租賃期限屆滿，或以其他方式致使用租賃關係消滅者，即為有重大事由。」

³⁰⁷ 德國民法第 543 條第 2 項前段：「有下列情事之一者，重大事由即存在：1，未按時提供使用承租人就租賃物為全部或一部之約定使用，或再度剝奪之者。2，使用承租人未盡其應盡之注意而顯著危害租賃物，或未經授權將之交付與第三人，致顯著損害使用出租人之權利者；或 3，使用承租人 a) 連續二期遲延給付租金或租金非屬不重要部分；或 b) 在長於二期之期間內遲延給付租金，其遲付之租金數額達二個月之租額。」

個月之二倍租金者，皆為重大事由，當事人得行使特別終止權³⁰⁸。此外，對於德國民法第 543 條第 2 項第 1 段第 3 款第 1 目之情形，補充規定承租人未支付之租金僅於超過一個月之租金時，始得視為非屬不重要，但住屋僅就短暫之使用而出租者，不在此限³⁰⁹。

3. 遲延給付租金之特殊要件

另外，出租人依據遲延給付租金為由而終止，若出租人事先已獲清償者，不得終止；又承租人得因抵銷而免除其債務，且於終止後即時為抵銷之表示者，則使終止無效³¹⁰。出租人於遷讓請求權訴訟繫屬後，最遲於二個月屆滿前，就到期之租金已受清償，或公共機構就該清償負擔義務者，該終止亦無效，但於該終止前二年以內，已先有發生同樣情事者，不在此限³¹¹。此外，承租人經確定判決應循法定調漲租金支付提高之租金者，出租人不得於判決確定後二個月未屆滿前以承租人支付租金遲延為由而終止租賃關係，但已具備因原積欠租金而無期限之特別終止要件者，不在此限。³¹²

³⁰⁸ 德國民法第 569 條第 1 項至第 2 項之 1：「承租住屋之使用將嚴重危害健康者，對使用承租人亦屬有第五百四十三條第一項所稱之重大事由。使用承租人雖於訂約時已知具有危險之性質，或已拋棄因該性質而得行使之權利者，亦同(第 1 項)。契約當事人之一方持續侵擾住宅安寧，致斟酌個案所有情事，即如契約當事人之過失，並衡量雙方之利益，對終止之人不能期待租賃關係繼續至終止期限屆滿，或繼續至租賃關係之其他終了時，亦為具有第五百四十三條第一項所稱之重大事由(第 2 項)。使用承租人依第五百五十一條規定提供擔保之遲延，其數額達一個月之二倍租金者，亦屬第五百四十三條第一項所定之重大事由。計算第一段之月租金時，就作為總額給付或作為預付所確認之作業費用，不予斟酌。第五百四十三條第三項第一段規定之補正期間或催告，不適用之。本條第三項第二款第一段及第五百四十三條第二項第二段規定，準用之(第 2 項之 1)。」

³⁰⁹ 德國民法第 569 條第 3 項第 1 款：「對第五百四十三條第二項第一段第三款，適用下列補充規定：1，於第五百四十三條第二項第一段第三款第一目之情形，其未支付之租金僅於超過一個月之租金時，始得視為非屬不重要。但住屋僅就短暫之使用而出租者，不在此限。」

³¹⁰ 德國民法第 543 條第 2 項後段：「第一段第三款之情形，使用出租人事先已獲清償者，不得終止。使用承租人得因抵銷而免除其債務，且於終止後即時為抵銷之表示者使終止無效。」

³¹¹ 德國民法第 569 條第 3 項第 2 款：「對第五百四十三條第二項第一段第三款，適用下列補充規定：2，使用出租人於遷讓請求權訴訟繫屬後，最遲於二個月屆滿前，就到期之租金及到期之第五百四十六條之一第一項所定補償已受清償，或公共機構就該清償負擔義務者，該終止亦無效。但於該終止前二年以內，已先有依前段規定無效之終止者，不在此限。」

³¹² 德國民法第 569 條第 3 項第 3 款：「對第五百四十三條第二項第一段第三款，適用下列補充規定：3，使用承租人經確定判決應依第五百五十八條至第五百六十條規定支付提高之租金者，使用出租人不得於判決確定後二個月未屆滿前以使用承租人支付租金遲延為由而終止租賃關係，但已具備因原積欠租金而無期限之特別終止要件者，不在此限。」

4.程序要件

應注意的是，終止前當事人須指定補正期間，當期限屆滿而無效果後，或經催告而無效果後方的終止，但該期限或催告明顯無法達成效果者、或立即終止係屬正當者以及承租人遲延給付第二項第三款之租金者，不在此限³¹³。

(二) 一般終止權

1.正當利益

除了特別終止之重大事由外，依德國民法第 573 條之規定，出租人行使終止權額外受到許多條款的限制，不但不得以提高租金為目的終止契約，並且出租人對住宅租賃關係具備「正當利益」(berechtigtes Interesse)時，方可提出終止契約的要求³¹⁴。換言之，出租人並無隨時提出終止租賃關係的要求。所謂正當利益，同條第 2 項之規定列舉了三種情況，減輕出租人對自己利益舉證的難度，保證出租人得合理收回住宅的權利，包含：承租人違反重要契約義務，主觀上受有可歸責事由、或出租人將該住宅作為自己、親屬或其他家屬成員之住處者以及因繼續租賃關係將妨害不動產為適當之經濟利用受有嚴重損害，但以另為住宅出租可以獲取更高的租金機會為由不在此限³¹⁵。

2.承租人之異議

(1)實體要件

依德國民法第 574 條第 1 項前段之規定，住宅租賃契約之終止對於承租人本人、親屬或其他家屬成員係屬嚴苛，並與出租人終止契約之利益衡量難謂正當，

³¹³ 德國民法第 543 條第 3 項：「重大事由為違反因使用租賃契約而生之義務者，僅得於指定補正，相當期限屆滿而無效果後，或經催告而無效果後終止。下列情事之一者，不適用前段規定：1，該期限或催告明顯無法達成效果者。2，權衡雙方之利益後，基於特別理由，立即終止係屬正當者；或 3，使用承租人遲延給付第二項第三款之租金者。」

³¹⁴ 德國民法第 573 條第 1 項之規定：「使用出租人僅於有終止使用租賃關係之正當利益者，使得終止之。為提高租金之目的，不得終止。」

³¹⁵ 德國民法第 573 條第 2 項：「使用出租人終止使用租賃關係之正當利益者，即如下列條件：1. 使用承租人因可歸責之事由，非屬不重要之違反其契約義務者。2. 使用出租人需以其住屋作為其本身、其親屬或家屬成員之住處者；或 3. 使用出租人因繼續租賃關係，將妨害其就不動產為適當之經濟利用，並因而可能遭受重大不利益；因另為住屋之出租以獲取較高租金之機會，不予斟酌。使用出租人亦不得主張基於意圖創設建物區分所有權，或基於交付使用承租人後發生之創設建物區分所有權，而欲讓與租賃之住屋者。」

承租人得對出租人提出異議並請求繼續租賃關係³¹⁶。所謂嚴苛指對承租人屬於不可預期且影響重大的狀況，同條第 2 項之規定預設「未能依合理條件取得適當之替代房屋」即屬於嚴苛，目前德國實務亦承認其他屬於嚴苛狀況，如：承租人年事已高、健康狀態不好、懷孕，或承租人正在準備考試、畢業論文寫作，或附近有殘障人士專門的學校和承租人的貧困等等³¹⁷。

(2)程序要件

依德國民法第 574 條之 2 第 1 項之規定，承租人對終止之異議應以書面為之，並因出租人之請求，承租人應即時告知異議之理由³¹⁸。同條第 2 項之規定，租賃關係消滅前二個月，承租人未對出租人表示異議者，出租人得拒絕繼續住宅租賃關係³¹⁹。惟出租人於異議期間屆滿前，未適時履行異議之教示義務，承租人仍得於遷讓訴訟之第一期日表示異議³²⁰。

(3)法律效果

承租人異議後，承租人得請求將住宅租賃關係繼續至斟酌所有情事後認為適當之期限，若不能期待出租人依現有之契約條件繼續租賃關係者，承租人僅得於適當變更條件而請求繼續³²¹。如當事人間不能協議者，則以判決定之³²²。應注意得是，該住宅租賃關係終了係屬嚴苛之情事並且其何時除去不確定者，得將住宅

³¹⁶ 德國民法第 574 條第 1 項及第 2 項：「使用租賃關係之終止對使用承租人，其親屬或其他家屬成員係屬嚴苛，且其嚴苛於衡量使用出租人之合法利益後，仍不能認為正當者，使用承租人得對使用出租人之終止表示異議，並請求使用出租人繼續使用租賃關係。但使用出租人無期限特別終止之事由存在者，不適用之(第 1 項)。適當之替代住屋不能依合理條件取得者，亦屬嚴苛(第 2 項)。」

³¹⁷ Blank/Börstinghaus, Miete, 5. Aufl., 2017, BGB §574.

³¹⁸ 德國民法第 574 條之 2 第 1 項：「使用承租人對終止之異議，應以書面表示之。因使用出租人之請求使用承租人應即時告知異議之理由。」

³¹⁹ 德國民法第 574 條之 2 第 2 項前段：「使用承租人最遲未於使用租賃關係消滅前二個月對使用出租人表示異議者，使用出租人得拒絕繼續使用租賃關係。」

³²⁰ 德國民法第 574 條之 2 第 2 項後段：「使用出租人於異議期間屆滿前，未適時提示異議之可能性，其方式及期間者，使用承租人仍得於遷讓訴訟之第一期日表示異議。」

³²¹ 德國民法第 574 條之 1 第 1 項：「於第五百七十四條所定之情形，使用承租人得請求將使用租賃關係繼續至斟酌所有情事後認為適當之期限。不能期待使用出租人依現有之契約條件繼續使用租賃關係者，使用承租人僅得於適當變更條件而請求繼續。」

³²² 德國民法第 574 條之 1 第 2 項前段：「不能協議者，關於使用租賃關係之繼續，其繼續之期間及繼續之條件，以判決定之。」

租賃關係定為不定期而繼續之³²³。另外，若已因合意或判決決定為特定期間而繼續租賃關係者，承租人在特定情況下得請求住宅租賃關係再繼續，包含：重大且正當的情事變更，或該情事可預見其發生，對繼續之住宅租賃關係之期間得以特定，且該情事未發之生者為限³²⁴。

二、原則上住宅租賃為不定期租賃

在住宅租賃契約原則上為不定期租賃，亦即倘無終止事由發生，承租人即可無限租期租用該住宅³²⁵。只有在法律允許之特定情況，住宅租賃始可約定租賃期限，且出租人須於租賃關係成立時以書面告知承租人定租賃期限之理由，否則即會變為不定期租賃。依德國民法第 575 條之規定，列舉了三項可以締結定期契約的事由：(1) 租期屆滿後，將房屋自用、供親屬或同住者使用的；(2) 用合法的方式將房屋拆除、大修或置於某種不解除住宅租賃契約會嚴重影響其進展的狀態的；(3) 準備將房屋租給服務提供人居住的³²⁶。

在住宅租賃定期契約到期前，承租人可詢問是否仍存在相關理由，出租人必須以書面形式做出說明。該書面說明須充分、具體，以便承租人事後核實。原則上，不符合法律規定之定期租賃、或雖符合法律規定，但據以約定租賃期限之事由已不存在、或未履行上述告知或通知義務等其他原因經法院判決准許者，租賃期限

³²³ 德國民法第 574 條之 1 第 2 項後段：「該使用租賃關係終了係屬嚴苛之情事何時除去不確定者，得將使用租賃關係定為不定期而繼續之。」

³²⁴ 德國民法第 574 條之 3 第 1 項：「依第五百七十四條至第五百七十四條之二規定，使用租賃關係已因合意或判決，定為特定期間而繼續者，使用承租人得請求使用租賃關係之繼續，但以其繼續延長得以情事之重大變更而屬正當，或該情事可預見其發生，對繼續之使用租賃關係之期間得以特定，且該情事未發之生者為限。」

³²⁵ Schmidt-Futterer/Blank, BGB, 13. Aufl., 2017, §573 Rn. 2.

³²⁶ 德國民法第 575 條第 1 項：「使用租賃期間屆滿後，使用出租人於下列情事，得於特定期間成立使用租賃關係：1，欲將房屋作為住宅而為本人，其親屬或其家屬成員使用。2，欲以可容許之方式將房屋除去，重大變更或修繕，而該措施因租賃關係之繼續而有顯著困難者；或 3，欲將房屋租與負有勞務義務之人，且使用出租人於契約成立時以書面將定期之原因通知使用承租人者。其他情事，視為不特定期間之租賃關係。」

雖屆滿，承租人仍可繼續租用³²⁷。

第四項、小結

一、保護承租人利益並尊重市場規律的租金管制

目前而言，德國民法對房屋租金的除了針對激烈競爭之住宅市場區域內之住宅租賃關係規範租金價格上限機制外，對於整體住宅租賃市場設有租金漲幅的上限，透過採取此種嚴格的調控手段，保障承租人的利益。同時，考量整體住宅市場活絡，對於首次出租或實施現代化措施之住宅給予租金總額或漲幅上限不同程度之豁免，以尊重市場規律、防止市場失靈。

二、以保護承租人利益為中心的租賃擔保

此外，考量租賃擔保為住宅租賃常見的交易手段，為避免住宅租賃關係開始時租金與租賃擔保同時給付致增承租人負擔，以及解決出租人轉讓租賃住宅後由誰承擔返還租賃擔保之義務，德國民法設有租賃擔保上限規範並且增訂德國民法 566 條之 1 第 2 項由受讓人原則上負有返還租賃擔保之義務，並且原出租人承擔嗣後受讓人無資力的風險，使整體規定的保護重點在於承租人。

三、維持穩定持續契約關係的手段選擇

最後，德國民法為了維持承租人居住穩定，在住宅租賃契約時間設定上除了限制定期租賃外，不論是定期租賃或不定期租賃，出租人終止權行使同受限制，主要以承租人不合宜之行為及出租人具有正當理由為目的方得終止契約，並且須踐行預告程序，更要面對承租人異議的挑戰。換言之，德國民法透過不定期租賃以及限制出租人終止權之前提下，避免承租人頻繁更換居所。

³²⁷ 德國民法第 575 條第 2 項：「使用承租人最早得於所定期限屆滿前四個月向使用出租人為請求，於一個月內通知使用承租人定期之原因是否仍存在。遲延通知使用承租人得請求以遲延之期間延長使用租賃關係。」同條第 3 項：「定期之原因嗣後始發生者，使用承租人得請求於相當期間延長使用租賃關係。該原因消滅者，使用承租人得請求以不特定期間延長之。定期原因之發生及遲延之期間之舉證責任，由使用出租人負擔之。」

第七章 德國法制與我國法制之比較

第一節 資訊地位平等

第一項、德國民法締約上過失制度規範

一、締約上過失制度概括規範

德國法制並未如我國法針對住宅租賃資訊問題作出特別規定，其可能出自於德國法制對於資訊揭露義務具有完善的原則性規範。按德國民法第 311 條第 2 項之規定：「第二百四十一條第二項所定之義務之債之關係，亦發生於下列情形：1，契約磋商之開始。2，契約之準備，而當事人之一方有鑑於將發生之交易關係使他方得有影響其權利，法益或利益之機會，或將該權益託付於他方者或 3，類似之交易接觸。」及德國民法第 241 條第 2 項之規定：「債之關係按其內容，得使一方當事人對他方負有考量他方之權利、法益及利益之義務。」提供締約上過失制度的法律基礎，體現交易資訊揭露義務與補足過去故意歸責的缺陷。而違反此項義務效果，則規定於德國民法第 280 條第 1 項：「債務人違反債之關係所生之義務者，債權人得請求損害賠償」，故以本條作為締約上過失的請求權基礎所在。

二、德國民法締約上過失法律效果

一般締約上過失制度主要處理的類型有三，包含：損害與後締結契約無因果關係、損害與後締結之無效契約有因果關係及損害與後締結之有效契約有因果關係³²⁸。在住宅租賃關係當中，常見承租人因資訊地位落差，出租人又疏於告知重要的租賃住宅資訊，往往承租劣質的租賃住宅造成損害，此屬於損害與後締結之有效契約有因果關係的締約過失類型。對於此種類型契約，學理稱之「不受期待之契約」，即因相對人之過失行為而締結不利益契約之一方，也就是訂定不受期待之契約者，在德國主要依據德國民法第 241 條第 2 項及第 280 條第 1 項之規定，

³²⁸ 周伯峰，論對「不受期待之契約」的法律上處理——以締約上過失為中心，政大法學評論，第 155 期，頁 230-234，2018 年 12 月。

債權人可以請求處理方式主要賦予脫離契約關係或者對於契約內容進行改變的機會，此非但對當事人實質的締約自由提供更強的保障，並且創造更有效率的交換³²⁹。

第二項、重新修訂我國締約上過失

一、締約上過失存在的功能價值

對於「不受期待之契約」之情形，從德國締約上過失之處理效果與我國民法瑕疵擔保法律效果類似，似無額外再重新修訂締約上過失之必要。然而，在契約成立前當事人違反資訊提供及真實義務時，如果當事人對其陳述並未加以擔保，更未作為契約成立後應該履行之債務內容，這時可能無法適用「瑕疵擔保」甚至是「不完全給付」，此時即能體現「締約上過失」存在的功能價值³³⁰。

二、我國現行法制存在的缺陷

在住宅租賃關係當中，雖然對於當事人違反資訊提供及真實義務，分別仰賴《住宅租賃契約應約定及不得約定事項》提醒當事人揭露租賃物資訊，以及租賃住宅管理條例第 13 條規範廣告內容應與事實相符，透過瑕疵擔保責任與債務不履行承擔資訊平等的義務，整體上似能夠彌平承租人承租資訊的落差，但仍然無法避免當事人無瑕疵擔保或不完全給付適用的可能。參照《住宅租賃契約應約定及不得約定事項》有關租賃物揭露資訊，如果當事人依照清單詳實填寫，透過瑕疵擔保責任與債務不履行，得以保護承租人利益。然而，目前採取開放式問答並非完全強制，倘雙方當事人對於租賃物揭露資訊皆未確認、檢查，無以避免發生上述問題。因此，若能夠修訂民法第 245 條之 1 使得貼合締約上過失理論，將「契約成立後」之情形納入，並放寬主觀歸責要件，則將使得當事人因資訊落差可能導致損害獲得更全面的法律保護，不致產生保障缺漏。

³²⁹ 周伯峰，前揭註 328，頁 230-234。

³³⁰ 周伯峰，前揭註 328，頁 276-277。

第二節 經濟地位平等

第一項、收入水準與居住對價相稱

一、租金

先行跳脫我國法目前採行租金去管制化之趨勢，整體而言《德國民法》有關租金管制規定，不論是租金額度的上限或漲幅，或是實體或程序要件要求，相較於我國過去法制思慮周延。就德國民法中關於租金問題的規定而言，立法者一方面竭力避免出租人利用住宅租賃關係的優勢強迫承租人接受高額租金，另一方面力求避免過度干預租賃住宅市場的租金水平造成市場僵化，保有租賃住宅市場的靈活性，實具有一定的借鏡之意義。

(一) 作業費用管制成本手段不同

對於租賃住宅所延伸之費用，包含：管理費、水電費、瓦斯費及稅費負擔等，在德國民法一同受租金管制，並且針對上述費用尚有特別法規定編列內容與結算之方法，避免出租人浮報致增承租人負擔。在我國除了稅費負擔依民法第 427 條由出租人負擔外，其餘租賃住宅所延伸之費用由當事人自由約定並無限制。因此，在現實交易運作租賃住宅之費用多由承租人負擔，甚至有超收賺取差價情事發生，尤其是電費計算問題最為嚴重。對此，在住宅租賃契約應約定及不得約定事項第 5 點第 3 項對於額外收費之情形規定每度用電不得收取超過台灣電力公司所定夏季用電量最高級距之每度金額。

(二) 決定租金總額管制主體不同

對於租金總額管制，德國民法為避免干涉範圍過大導致市場僵化，對於是否為激烈競爭之居住市場區域而採取管制措施，其決定權限下放地方政府，與我國土地法第 97 條限於城市地方有異曲同工之妙，但不同的是決定租金總額管制的主體為中央政府。再者，相較於我國對於城市定義模糊容易有法律適用上的問題，德國民法第 556 條之 4 第 2 項不但明確提供適用地區的標準，並且透過踐行法定

程序，使適用地區範圍得以確定，此情確實不易產生法律適用問題，亦能限縮市場干預範圍。

(三) 租金漲幅管制與程序要求不同

在租金漲幅管制之部分德國民法提供分級租金及指數租金兩種方式，原則尊重當事人之約定。當事人既使未約定租金調整條款的情形，出租人若符合德國民法第 558 條或第 559 條以下之規定亦能調整租金，不致使當事人無法隨著物價水準或租賃住宅價值調整租金收益。相較於我國法除了民法第 442 條之規定外，在租金漲幅部分並無太多著墨，更何況漲幅限制之部分。

另外，除了分級式租金外，不論是指數租金或法定情形，皆須踐行一定書面預告程序，以明確調整發生時日。對於法定租金調整，除了當事人意思不合外，原則上自書面到達後第三個月發生調整效力，不同於我國須透過聲請請求法院增減其租金，待判決確定方生效力。

(四) 租金管制的計算基準不同

德國民法對於租金總額或漲幅管制計算，是以當地通常之參考租金水平為基礎，其是以當地參考租金、租金覽表或租金資料庫作為依據，由於該依據皆由出租人與承租人之利益代表人參與認同，不但能夠充分說明其正當性，亦得盡量尊重市場行情，接近出租人合理的收益利潤。不同於我國租金管制，在總額管制上以房地價值計算，在租金調幅部分主要仰賴法官自由心證，以基地申報地價為基礎，根據斟酌座落位置，工商業繁榮之程度，承租人利用之經濟價值及所受利益，並與鄰地租金相等項比較，在判斷上容易有模糊空間。

二、租賃擔保

(一) 租金擔保管制目的不同

再觀德國民法租賃擔保額度之管制，其目的與我國法稍有不同，前者主要考量承租人須保留一定財產作為準備住宅事務的資金，後者避免出租人透過收取押

租金躲避租金總額的限制，或預先收取高額的押租金並嗣後任意苛扣損及承租人之權益。其實租金擔保額度的管制，與上述目的皆有牽連，互不衝突，亦無孰優孰劣的問題。

(二) 違反租金擔保管制效果不同

我國法面對出租人超收租賃擔保部分時採取抵銷的方式，而非德國實務逕自認定為無效。縱然，德國學界有部分認為管制額度僅在締約之初發生拘束力，隨著契約存續期間出租人損益風險之增加，在特定情況下出租人有收取額外租賃擔保，仍舊非實務所採。相較之下，我國一方面使出租人得透過收取高額擔保以獲得債務清償之機會，另一方面賦予承租人「抵銷」之武器避免出租人恣意妄為，在權衡當事人之利益較具彈性。

(三) 租賃擔保持有方式不同

在德國法制之下對於租賃擔保採取的是以擔保為目的之「押金」模式，但承租人仍舊享有期限利益，只不過其對租賃擔保之利息處理是作為擔保之用，擴大出租人獲償之機會。此與我國土地法第 98 條之規定所預設「押租」類型不同，但保障承租人享有期限利益之精神相似。然而，現行租賃住宅管理條例第 3 條第 3 款將預設類型改為「押金」模式，但我國住宅租賃契約之承租人對於租賃擔保原則上不索取利息，整體而言租賃擔保持有方式仍舊不同。

(四) 租賃住宅轉讓後有關租賃擔保的解決不同

在出租人轉讓租賃住宅於第三人時，由誰負返還租賃擔保義務問題，處理上德國民法第 566 條之 1 規定，由受讓人負返還義務並且原出租人在承租人無法自受讓人取得租賃擔保時，仍繼續負返還義務。在我國因租賃擔保契約性質認定屬於要物契約，承租人究竟向誰請求押租金之問題，便有「新受讓人說」及「押租金實際占有人說」之爭論，以致承租人究竟向誰請求押租金須在個案中判斷。

三、檢討我國租金及押租金之法制

(一) 租金管制部分

1. 以法律限制作業費用收取

目前我國除了稅費負擔依民法第 427 條由出租人負擔以及出租人收取電費金額依住宅租賃契約應約定及不得約定事項第 5 點第 3 項有所限制外，其餘租賃住宅所延伸之費用原則上由當事人自由約定並無限制。考量電費收費之所以限制乃源自於過去出租人超收賺取差價之情形亂象叢生，現時僅限制電費項目的部分，難保不發生於其他費用之計算。另外，以住宅租賃契約應約定及不得約定事項作為限制當事人費用收取，是否已經逾越法律保留的界限，不無疑問。對此，應改由法律針對常見費用項目制訂收費標準，並且對於額外收取之費用應認定為租金之部分，以避免逃避租金所得稅之課徵及租金管制漏洞。

2. 採取因地制宜的租金總額管制

撤去租金總額管制區域由中央決定，將租金管制權限下放地方政府，除了呼應我國學者對於租金總額管制採取因地制宜的思想原則，更能減少干預市場的範圍³³¹。

3. 增設租金漲幅的管制規範

另外，建議我國增設租金漲幅管制，除了避免一次租金總額去管制化導致原本有限的居住資源縮水，惡化居住問題原本嚴重之地方，更能減少人民因調漲租金不堪負荷，而無所可居的情形，確實保障人民居住權益。

4. 管制計算基準契合市場行情

對於上述不論租金總額或是漲幅管制，其管制皆方式應貼近市場行情及出租人合理的收益利潤，避免過分侵蝕出租人之財產權。德國民法不論是租金總額或漲幅管制所依據的資料皆由出租人與承租人之利益代表人參與認同，能夠尊重市場行情及出租人合理的收益利潤，此作法值得我國參考。

³³¹ 謝哲勝，前揭註 92，頁 280。

(二) 租賃擔保管制部分

1. 繼續保留我國租賃擔保持有擔保的方式及違反的效果

針對租賃擔保部分，得繼續保留我國持有擔保的方式及違反的效果，除了切合我國住宅租賃運作實務，在權衡當事人之利益較具彈性，蓋與德國租賃擔保違反效果相較之下，賦予承租人「抵銷」之武器避免出租人恣意妄為，在權益救濟上與透過不當得利作為請求方式，我國方式較為便捷。

2. 重新認定押租金契約性質

然而，在出租人轉讓租賃住宅於第三人時，對於租賃擔保的處理上我國法制相較於德國法制仍有極大的進步空間，在德國民法的保護重點已從過去之受讓人轉移為承租人。在新條例授權公布住宅租賃契約應約定及不得約定事項第 15 點之內容雖然明文出租人應於租賃住宅所有權轉讓時，應移交押金與受讓人並以書面通知承租人，有意使受讓人負擔返還義務，但在出租人未移交時，承租人是否仍然可以逕向受讓人請求，尤其實務將押租金契約認定為別一契約及要物契約性質之見解，使得問題仍然未解。因此，為了根除法律適用上的疑慮，實應對於押租金契約性質重新認定。另外，可以參考德國法之規定，即承租人無法自受讓人取得押租金時，出租人仍繼續負返還義務，使承租人權益獲得更周全的保護。

第二項、穩定持續的契約關係

一、出租人終止權之限制

(一) 終止原因寬嚴不同

德國對於住宅租賃契約不論是定期租賃或不定期租賃，出租人終止權行使同受限制。其限制終止原因與我國相似，主要以承租人不合宜之行為及出租人具有正當理由為目的，方得終止契約。相較德國法所列举出租人之正當理由，與我國法制上相差不遠，但因德國實務上對於承租人異議內容認定較為寬闊，對於保護承租人德國法制之強度仍舊較強。

(二) 終止契約程序不同

另外，德國民法在終止住宅租賃契約具有相對嚴格的程序要求，更要面對承租人異議的挑戰，主觀上使出租人不得恣意妄為，提供承租人多一層保護，客觀上使當事人能夠自我協調紛爭，以疏解訟源，值得我國學習。

二、住宅租賃關係存續期間設定不同

由於德國法制只有特殊情況下始能簽訂定期租賃契約，故大部分的住宅租賃關係原則為不定期租賃，不同於我國由當事人自行約定。德國法制主要避免因定期租賃關係臨近終止的時機趁機提高續租租金，並且與限制出租人終止權相輔相成，使住宅租賃關係的穩定性得到充分的保障，承租人的利益也因而得到了更切實的保護。換言之，德國法制與其鼓勵出租人與承租人定期續約，不如直接使雙方在限制出租人終止權之前提下，透過不定期租賃讓住宅租賃關係得以穩定，避免承租人頻繁更換居所。

三、所有權讓與不破租賃

(一) 租期逾五年及不定期住宅租賃契約適用要件不同

又，依德國民法第 566 條第 1 項之規定：「出租之住屋交付使用承租人後，由使用出租人讓與第三人者，於其所有權存續中基於使用租賃關係所生之權利及義務，由受讓人取代使用出租人而加入之。」與我國相同皆存有所有權讓與不破租賃原則。不過，德國民法之所有權讓與不破租賃原則並不排除租期逾五年及不定期租賃契約之適用，其很大原因在於德國住宅租賃契約設定以不定期租賃契約為原則之前提下，不宜限縮適用，否則將架空本條適用空間。

(二) 法律效果不同

另外，其法律效果與我國相似，但不同的是受讓人若不履行義務者，出租人就應由受讓人賠償之損害，負與拋棄先訴抗辯權之保證人同一之責任，但承租人因出租人之通知而知有所有權之移轉時，如不以最初得終止住宅租賃關係之期日

而終止者，出租人免其責任³³²。

四、檢視我國穩定持續住宅租賃關係的手段

(一) 出租人終止權之限制

1. 調整終止正當理由認定

對於出租人終止權之正當理由的認定，實務上從寬的趨勢應重新檢討，尤其在具備「收回自住」之原因，避免產生承租人之保護的漏洞。實務上擴張解釋包括收回供自己營業之用，不但違背法律解釋方法，亦損及立法目的保護承租人之意旨。

2. 賦予承租人對於出租人終止權異議程序

由於土地法第 100 條僅係限制出租人終止權行使之原因，若出租人欲請求返還房屋，應回歸民法規定之程序要件，如：遲延租金之催告(民法第 440 條第 1 項參照)或終止租約之先期通知(民法第 450 條第 3 項參照)，經合法終止後，始有收回該房屋請求權存在。在租賃住宅管理條例第 10 條之規定，亦僅增加須書面踐行通知與檢附事證之要件。若此時能賦予承租人異議的權利，挑戰出租人催告或通知之正當理由，使當事人能夠自我協調，將能夠減少直接透過訴訟處理紛爭。

(二) 鼓勵出租人與承租人定期續約

保護承租人穩定的使用租賃物之利益，在於如何避免承租人頻繁更換居所，德國法制以限制當事人簽訂不定期租賃作為方法，實值參考。但考量我國實務運作多以定期租賃情形較多，且定期租賃確實較能夠提供當事人對於未來的可預期性，仍建議對於租賃存續期間仍交由當事人自主決定。然而，目前在《租賃住宅管理條例》對於租期屆滿後當事人續約之問題仍然持保守立場未以解決，稍嫌可惜，建議國家可以透過給予出租人租稅優惠等補償措施，以換取承租人追求穩定持續住宅租賃關係。

³³² 德國民法第 575 條第 2 項：「受讓人不履行義務者，使用出租人就應由受讓人賠償之損害，負與拋棄先訴抗辯之保證人同一之責任。使用承租人因使用出租人之通知而知有所有權之移轉時，如不以最初得終止使用租賃關係之期日而終止者，使用出租人免其責任。」

(三) 所有權讓與不破租賃

1.刪除公證要件

有關所有權讓與不破租賃適用前提原則上無須公證，但對於租期逾五年或未定期限者要求公證方有所有權讓與不破租賃適用。此限制之設定雖然立意良善，但對於原本立法預設的目的不只效果有限，同時間接損及了承租人之居住權益，實非妥適，建議刪除。

2.增設法律效果

最後，對於受讓人若不履行義務之責任，為避免不知租賃住宅所有權移轉情事之承租人權益受損無從取償，建議原本應由受讓人賠償之損害，負與出租人拋棄先訴抗辯權之保證人同一之責任，使承租人之權益獲得更周全的保障。



第八章 結論與建議

第一節 結論

「居住」是人們的基本需求，卻因為過高的房價、收入水準過低產生居住爭議，面對社會住宅提供的數量不足及不透明的租屋資訊等，更使居住權益雪上加霜，逼使政府積極面對。我國政府捨棄過去「住者有其屋」的政策理念，自 2011 年通過《住宅法》改以「住者適其屋」取代，其中包含透過建立公平的租賃住宅市場以保障國民居住品質及權益。因此，2017 年 12 月立法院通過《租賃住宅管理條例》，期以保障住宅租賃雙方權益及健全租賃住宅市場發展，以完善我國居住政策。

第一項、資訊地位平等

過去，對於住宅租賃契約多以《民法》、《土地法》作為依據。在《租賃住宅管理條例》中除了解決過去法律制度殘留的問題，亦提升權益保障的內容。概覽《租賃住宅管理條例》特別強調租賃住宅資訊的透明且真實，包含：修繕義務的說明、同意轉租的證明及租賃住宅廣告的真實，以彌平租賃住宅資訊不平等的現象。其中，考量過去民法上以出租人主觀故意歸責為基礎的救濟方法，尚難充分保障承租人權益，以及民法第 245 條之 1 規定適用狹隘，更使資訊充分的締約環境難以建立。新法新增租賃住宅廣告的真實義務以及《住宅租賃契約應約定及不得約定事項》將住宅租賃的重要交易資訊作為租賃標的現況確認內容，鼓勵當事人簽訂契約時揭露租賃物資訊及住宅租賃的相關事務，透過瑕疵擔保責任與債務不履行責任，以承擔「彌平資訊地位平等」的任務。

第二項、經濟地位平等

一、收入水準與居住對價相稱

(一) 租金管制問題

「支付的對價與收入水準相稱」是居住權益保障的重要內涵，而租金管制更

是不可或缺的手段。雖然其不符合經濟學理念，但從整體社會觀察可能帶來更多其他金錢物質無法衡量的效益，故對於出租人之收益權限產生限制，但只要出租人可以獲得合理的利潤，仍然在憲法容許的範圍。

翻開過去我國租金施行的租金總額管制，在法律適用存有疑慮，包含：城市要件認定模糊、管制計算基準失真以及總額設定太高等問題亟待解決。現行法選擇跳過此類問題，逕自採行「租金去管制化」之政策，考量其目的是希冀透過租賃住宅的大量供給，以量制價，降低租金額度，間接保障承租人的居住權益。不過，倘若房東投入市場成本過高以致沒有利潤等誘因，卻可能原先預設目的不達，甚至造成現有租賃住宅市場哄抬價格，損及承租人有限之資源，不無疑問。整體而言，不宜為了發展租賃住宅市場，而犧牲承租人之居住權益。

另外，對於租賃住宅所延伸之費用，在現實交易運作多由承租人負擔，甚至有超收賺取差價情事發生，尤其是電費計算問題最為嚴重。對此，在住宅租賃契約應約定及不得約定事項第 5 點第 3 項對於額外收費之情形規定，每度用電不得收取超過台灣電力公司所定夏季用電量最高級距之每度金額。不過，現時僅限制電費項目的部分，難保同樣問題不發生於其他費用之計算。同時應注意的是，以住宅租賃契約應約定及不得約定事項作為限制當事人費用收取，是否已經逾越法律保留的界限，不無疑問。

(二) 押租金性質認定問題

最後，押租金之部分最大的問題在於實務性質認定不當，導致在於租賃物轉讓第三人時，延伸承租人究竟向誰請求押租金之問題。在新條例授權公布住宅租賃契約應約定及不得約定事項第 15 點之內容雖然明文出租人應於租賃住宅所有權讓與受讓人時，應移交押金與受讓人並以書面通知承租人，有意使受讓人承擔向出租人請求押金的風險，固然保護了承租人之權益。但在出租人未移交時，承租人是否仍然可以逕向受讓人請求，尤其實務將押租金契約認定為別一契約及要物契約性質之見解，使得問題仍然未解。

二、穩定持續的契約關係

目前國家賦予住宅租賃契約具有對抗之效力及限制出租人終止權之行使以保護承租人穩定的使用租賃物之利益，對住宅租賃契約具有重大意義。不過，其存有法律適用上的疑慮，包含：在於租期逾五年或未定期者須踐行公證的要求方有所有權讓與不破租賃的適用、土地法第 100 條之規定是否適用定期租賃契約以及同條第 1 款「收回自住」認定過寬等。

雖然針對出租人終止權行使的限制，隨著主管機關依《租賃住宅管理條例》公布住宅租賃契約應約定及不得約定事項第 16 點及房屋租賃定型化契約應記載及不得記載事項第 15 點之內容，直接把出租人終止權之限制條件列為契約內容，則不論是定期租賃契約或不定期租賃契約應當皆有適用空間。為德不卒的是公告版本分別闕漏了「出租人收回自住」及「重新建築」兩款終止事由，導致土地法第 100 條是否適用定期租賃契約之爭議仍舊存在。

另外，對於租期屆滿後續約問題，雖然涉及人民財產權之高度限制，但國家仍然可以透過給予出租人租稅優惠等補償措施，以換取承租人追求穩定持續住宅租賃關係。不過，《租賃住宅管理條例》仍舊選擇以保守的方式，僅停留在維持當事人間權益間平衡，未能貫徹國家對於履行人民居住權益的決心，稍嫌可惜。

第二節 建議

第一項、重新修定締約上過失制度

面對前述問題，透過德國法有關住宅租賃政策比較我國法制之差異，我國住宅租賃法制上確實存有很大的進步空間。在住宅租賃關係當中，雖然對於當事人違反資訊提供及真實義務，分別仰賴《住宅租賃契約應約定及不得約定事項》提醒當事人揭露租賃物資訊，以及租賃住宅管理條例第 13 條規範廣告內容應與事實相符，透過瑕疵擔保責任與債務不履行承擔資訊平等的義務，但仍然無法避免當事人無瑕疵擔保或不完全給付適用的可能。

參照《住宅租賃契約應約定及不得約定事項》有關租賃物揭露資訊，如果當事人依照清單詳實填寫，透過瑕疵擔保責任與債務不履行，得以保護承租人利益。然而，目前採取開放式問答並非完全強制，倘雙方當事人對於租賃物揭露資訊皆未確認、檢查，當事人對其陳述亦並未加以擔保，更未作為契約成立後應該履行之債務內容，這時可能發生無法適用「瑕疵擔保」甚至是「不完全給付」問題。因此，若能夠修訂民法第 245 條之 1 使得貼合締約上過失理論，將「契約成立後」之情形納入，並放寬主觀歸責要件，則將使得當事人因資訊落差可能導致損害獲得更全面的法律保護，不致產生保障缺漏。

第二項、施行因地制宜的租金管制

在經濟地位保護上，不論是租金總額或漲幅的管制，將其決定權限下放地方政府，以落實因地制宜的思想原則，並且避免干預市場範圍過大。另外，應避免為發展租賃住宅市場而放棄租金管至犧牲承租人權益，重新考慮租金總額管制。退步言之，縱使不施行租金總額管制亦得加入租金漲幅管制以避免一次去管制化導致原本居住問題嚴重之地方更加惡化。另外，租賃住宅所延伸之費用除電費收取金額應限制外，為避免租金管制產生漏洞對於其他費用應制訂收費標準，並由法律層面規範。

第三項、檢討押租金契約性質認定

另外，針對租賃擔保應重新認定押租金契約性質，以根除法制運作不夠周全之處並將保護重點從受讓人轉移為承租人，否則既使新條例有意使受讓人承擔向出租人請求押金的風險，但在出租人未移交時，承租人是否仍然可以逕向受讓人請求，尤其實務將押租金契約認定為別一契約及要物契約性質之見解，使得問題仍然未解。另外，亦可參考德國法之規定，即承租人無法自受讓人取得押租金時，出租人仍繼續負返還義務，使承租人權益獲得更周全的保護。

第四項、加強穩定持續租約的手段

最後，為保護承租人穩定的使用租賃物之利益，應刪除租期逾五年或未定期

限者須踐行公證方有所有權讓與不破租賃適用之要求，並且於土地法第 100 條之規定明文肯定適用於定期租賃契約。此外，對於土地法第 100 條第 1 款出租人終止權之正當理由「收回自住」的認定，實務上從寬的趨勢應重新檢討，避免產生承租人之保護的漏洞。並且，有關出租人終止權應適時考慮對於出租人之正當理由加入一定的預告程序，並賦予承租人異議的權利，使當事人能夠自我協調紛爭，以疏解訟源。

然而不論為何，如何避免承租人頻繁更換居所，實為保護承租人穩定的使用租賃物之利益所在，但在《租賃住宅管理條例》仍舊僅停留在維持當事人間權益間平衡，未能貫徹國家對於履行人民居住權益的決心，稍嫌可惜。考量我國實務運作多以定期租賃情形較多，且定期租賃確實較能夠提供當事人對於未來的可預期性，仍建議租賃存續期間仍交由當事人自主決定。不過，實應對於租期屆滿後續約問題有周延的政策規畫，國家似可以透過給予出租人租稅優惠等補償措施，以換取承租人追求穩定持續住宅租賃關係。

綜合上述，新條例《租賃住宅管理條例》之立法特色可以發現主要致力於保障當事人雙方權益及健全租賃住宅市場發展兩大面向，以降低租賃交易成本為手段，達到維護人民居住權益的立法目的。在保障當事人雙方權益之部分，除了調整過去法律適用的問題，以貼合現實交易的運作外，並且嚴格管控契約內容，平衡住宅租賃契約當事人之權利義務關係。而在健全租賃住宅市場發展之部分，則以建構租賃住宅服務業之管理制度為主要內容。然而，細觀新條例內容可以窺探立法政策的態度，包含：租賃人格性的強化、租稅優惠的賦予，似仍以鼓勵發展租賃住宅服務業為重，讓住宅租賃政策從保護經濟弱勢之「社會法」體系，拉回以私法自治為核心之「市民法」體系。新條例固然回應了過去人民追求居住正義的需求，但此種以自由經濟市場發展來達到維護人民居住權的政策手段，其結果容易在「維護人民居住權」之效果上大打折扣，實屬可惜。至於，新法對於未來實務適用的態度及整體租賃住宅市場發展成效，以及租賃住宅市場發展對於承租

人居住權益的保障的貢獻為何，由於新法施行不久，則尚須觀察。



參考文獻

中文文獻

一、專書

- 【1】 王澤鑑，民法學說與判例研究第二冊，自版，2009 年 12 月。
- 【2】 王澤鑑，民法學說與判例研究第六冊，自版，2009 年 12 月。
- 【3】 王澤鑑，民法總則，自版，2011 年 8 月。
- 【4】 王澤鑑，法律思維與民法實例－請求權基礎理論體系，自版，2011 年 8 月。
- 【5】 王澤鑑，債法原理：基本理論債之發生，自版，2012 年 12 月增訂 3 版。
- 【6】 王錦村，土地法實用，自版，1984 年 6 月。
- 【7】 吳啟賓，租賃法論，新學林，2018 年 3 月 2 版。
- 【8】 李淑明，債法各論，元照，2013 年 1 月 6 版。
- 【9】 李鴻毅，土地法論，自版，1984 年 5 月增訂 8 版。
- 【10】 林誠二，債編各論新解－體系化解說（上），瑞興，2007 年 3 月 2 版。
- 【11】 法治斌、董保城，憲法新論，元照，2012 年 9 月 5 版。
- 【12】 邱聰智，新訂債法各論（上），自版，2008 年 8 月。
- 【13】 孫森焱，民法債編總論(上冊)，三民，2012 年 2 月修訂版。
- 【14】 國立臺灣大學法律學院、財團法人台大法學基金會，德國民法(上)——總則編、債編、物權編，元照，2016 年 10 月 2 版。
- 【15】 陳自強，契約之內容與消滅，元照，2016 年 3 月。
- 【16】 陳自強，契約之成立與生效，元照，2014 年 2 月 3 版。
- 【17】 黃立（編），民法債編各論（上），元照，2004 年 10 月。
- 【18】 黃立，民法債編總論，元照，2006 年 11 月 3 版。
- 【19】 黃茂榮，契約法各論-買賣法，植根，2004 年 12 月 6 版。
- 【20】 溫豐文，土地法，自版，2013 年 3 月修訂版。
- 【21】 詹森林，民事法理與判決研究(三)消費者保護法專論，元照，2003 年 8 月。
- 【22】 詹森林，民事法理與判決研究(四)消費者保護法專論(2)，元照，2003 年 8 月。
- 【23】 詹森林，民事法理與判決研究，元照，1998 年 11 月。
- 【24】 劉春堂，民法債編各論(上)，自版，2014 年 10 月。
- 【25】 鄭冠宇，民法債編總論，新學林，2017 年 9 月 2 版。
- 【26】 謝哲勝，土地法，翰蘆，2013 年 9 月 3 版。
- 【27】 謝哲勝，房租管制法律與政策，五南，1996 年 9 月。
- 【28】 楊松齡，實用土地法精義，五南，2017 年 9 月 17 版。

二、期刊論文

- 【1】 王增勇，以住宅「社會化」對抗貧窮「污名化」，台灣社會研究季刊，第 81 期，頁 491-499，2011 年 3 月。
- 【2】 王澤鑑，買賣不破租賃：民法第四二五條規定之適用、準用及類推適用，軍法專刊，第 35 卷 8 期，頁 2-19，1989 年 8 月。
- 【3】 王澤鑑，意思表示詐欺與侵權行為，法學叢刊，第 23 卷第 4 期，頁 1-5，1978 年 12 月。
- 【4】 王鴻源、林鼎鈞，我國租金管制問題之研究，土地問題研究季刊，第 4 卷 3 期，頁 130-136，2005 年 9 月。
- 【5】 朱柏松，論廣告媒體業者之損害賠償責任兼評最高法院九十年度台上字第二二七號判決，月旦法學雜誌，第 91 期，頁 8-27，2002 年 12 月。
- 【6】 朱慶倫，社會住宅新作為，國土及公共治理季刊，第 5 卷第 3 期，頁 122-129，2017 年 9 月。
- 【7】 江明芸，社會住宅，從民間倡議到政府爆衝，新社會政策，第 14 期，頁 8-12，2011 年 2 月。
- 【8】 江穎慧，社會住宅迷思，新社會政策，第 15 期，頁 30-31，2011 年 4 月。
- 【9】 吳啟賓，租賃物所有權移轉與押租金之關係，法令月刊，第 37 卷 5 期，頁 13-14、24，1986 年 5 月。
- 【10】 吳從周，不定期租賃出租人收回房屋重新建築土地法第一百條第一款「收回重新建築」之意涵，月旦法學教室，第 112 期，頁 18-20，2012 年 2 月。
- 【11】 吳從周，民法上之法律漏洞、類推適用與目的性限縮，東吳法律學報，第 18 卷第 2 期，頁 103-140，2006 年 12 月。
- 【12】 吳從周，租賃關係存續中押租金之返還與租金之預付—簡評最高法院 99 年度台上字第 633 號判決，台灣法學雜誌，第 195 期，頁 13-22，2012 年 3 月。
- 【13】 吳從周、鄭聆苓，不定期租賃出租人收回房屋之限制—土地法第 100 條第 1 款「收回自住」之實務案例類型化，台灣法學雜誌，第 174 期，頁 89-95，2011 年 4 月。
- 【14】 李子瑋、李長晏，社會住宅政策問題建構與對策提出，中國地方自治，第 66 卷第 6 期，頁 20-60，2013 年 6 月。
- 【15】 李永然，我國如何落實「居住權」的保障？—從台灣實施《租賃住宅市場發展及管理條例》談起，人權會訊，第 131 期，頁 8-11，2019 年 1 月。
- 【16】 李忠雄，論買賣不破租賃與逃避債務，法令月刊，第 44 卷第 5 期，頁 11-12，1993 年 5 月。
- 【17】 李震山，基本權利之衝突，月旦法學雜誌，第 1 期，頁 60-61，1995 年 5 月。
- 【18】 周伯峰，論對「不受期待之契約」的法律上處理——以締約上過失為中心，政大法學評論，第 155 期，頁 219-295，2018 年 12 月。
- 【19】 林旺根，論制定住宅租賃專法之必要性，月旦法學雜誌，第 245 期，頁

168-187，2015 年 10 月。

- 【20】林柏安，台日自用房屋租賃法規比較研究—以傳統借家制度為中心，德明學報，第 41 卷第 1 期，頁 87-105，2017 年 6 月。
- 【21】林清汶，兩岸房屋租賃法制比較與效益研究，臺灣土地研究，第 21 卷第 1 期，頁 1-22，2018 年 5 月。
- 【22】林誠二，買賣不破租賃原則限制規定之溯及力問題，台灣本土法學雜誌，第 84 期，頁 127-140，2006 年 7 月。
- 【23】林誠二，買賣不破租賃規定之目的性限縮與類推適用，台灣本土法學雜誌，第 97 期，頁 143-149，2007 年 8 月。
- 【24】姚志明，租賃物移轉後，租金請求與押租金返還之問題，月旦法學教室，第 163 期，頁 15-17，2016 年 5 月。
- 【25】姚志明，概覽「租賃住宅市場發展及管理條例」，月旦法學雜誌，第 277 期，頁 5-25，2018 年 6 月。
- 【26】胡天賜，買賣不破租賃制度之法律經濟分析，臺大法學論叢，第 33 卷 1 期，頁 131-182，2004 年 1 月。
- 【27】胡勝正，從房價所得比看臺灣的社會不公，臺灣經濟預測與政策，第 45 卷第 2 期，頁 23-43，2015 年 3 月。
- 【28】胡華泰，消費定型化契約條款之行政規制，消費者保護研究，第 17 輯，頁 97-152，2011 年 12 月。
- 【29】徐婉寧，住居租賃轉租之效力，月旦法學教室，第 192 期，頁 15-17，2018 年 10 月。
- 【30】高欽明，不動產契約要式性與公證制度關聯性之研究——以民法第 166 條之 1 之施行作為探討，月旦法學雜誌，第 277 期，頁 176-199，2018 年 6 月。
- 【31】張金鶚，住者適其屋-我國住宅政策與問題之探討，律師通訊，第 181 期，頁 12-18，1994 年 10 月。
- 【32】張雅惠，國民住宅轉型社會住宅之課題分析，土地問題研究季刊，第 8 卷第 2 期，頁 79-88，2009 年 6 月。
- 【33】張嘉麟，行政機關對定型化契約內容管制之探討—以定型化契約應記載或不得記載事項為中心，消費者保護研究，第 20 輯，頁 109-146，2016 年 2 月。
- 【34】許宗力，2013 年憲法發展回顧，臺大法學論叢，第 43 卷第 S 期，頁 1031-1074，2014 年 11 月。
- 【35】陳立夫，租賃住宅市場發展及管理條例解說，月旦法學雜誌，第 277 期，頁 26-47，2018 年 6 月。
- 【36】陳忠五，不誠實廣告與夾層屋買賣契約—實務上相關判決之綜合評釋(下)，台灣本土法學雜誌，第 3 期，頁 70-91，1999 年 8 月。
- 【37】陳怡伶、黎德星，新自由主義化、國家與住宅市場—臺灣國宅政策的演變，地理學報，第 59 期，頁 105-131，2010 年 8 月。

- 【38】 陳明燦，城市房屋租金管制之簡析—兼評最高法院九五年臺上字第一九〇七號民事判決，台灣本土法學雜誌，第 92 期，頁 243-248，2007 年 3 月。
- 【39】 陳冠甫，評租賃住宅市場發展及管理條例——以健全住宅租賃關係法為中心，月旦法學雜誌，第 277 期，頁 48-63，2018 年 6 月。
- 【40】 陳冠甫，新租賃法—關於房屋押租金問題之初探，土地問題研究季刊，第 17 卷第 4 期，頁 73-78，2018 年 12 月。
- 【41】 陳聰富，社會問題與契約管制的界限，月旦法學雜誌，第 125 期，頁 82-93，2006 年 07 月。
- 【42】 陳聰富，契約自由與定型化契約的管制，月旦法學雜誌，第 91 期，頁 51-62，2002 年 12 月。
- 【43】 曾明遜、陳明燦，預售屋不實廣告責任之法律經濟分析，公平交易季刊，第 14 卷第 3 期，頁 1-25，2006 年 7 月。
- 【44】 曾品傑，論不動產不誠實廣告之契約效力(上)—最高法院相關判決評釋，台灣本土法學雜誌，第 81 期，頁 67-88，2006 年 4 月。
- 【45】 曾品傑，論不動產不誠實廣告之契約效力(下)—最高法院相關判決評釋，台灣本土法學雜誌，第 82 期，頁 33-57，2006 年 5 月。
- 【46】 程明修，契約自由與國家之保護義務，憲政時代，第 30 卷第 2 期，頁 195-227，2004 年 10 月。
- 【47】 華昌宜、賴碧瑩，我國租賃住宅市場之發展與推動，住宅學報，第 10 卷第 1 期，頁 67-76，2001 年 2 月。
- 【48】 黃立，契約自由的限制，月旦法學雜誌，第 125 期，頁 5-22，2005 年 10 月。
- 【49】 黃立，買賣不破租賃的鐵則不再，月旦法學教室，第 1 期，頁 14-15，2002 年 11 月。
- 【50】 黃健彰，房屋承租人優先購買權的承認與建構，政大法學評論，第 128 期，頁 79-142，2012 年 8 月。
- 【51】 黃麗玲，社會住宅政策與社會轉型的新視野，新社會住宅政策，第 14 期，頁 13-16，2011 年 2 月。
- 【52】 楊宏暉，加盟業主先契約資訊揭露義務之建構，政大法學評論，第 144 期，頁 227-314，2016 年 3 月。
- 【53】 楊宏暉，市場經濟秩序下的契約失靈調整模式，法學新論，第 25 期，頁 67-101，2010 年 8 月。
- 【54】 楊宏暉，契約準備階段的資訊揭露與廣告規制—以我國法及德國法為中心，公平交易季刊，第 18 卷第 3 期，頁 41-82，2010 年 7 月。
- 【55】 楊宏暉，對預售屋廣告的契約期待與保護，財產法暨經濟法，第 25 期，頁 29-80，2011 年 3 月。
- 【56】 溫豐文，民法第四二五條修正條文評析--論租賃權物權化之範圍，東海大學法學研究，第 19 期，頁 195-205，2003 年 12 月。

- 【57】 詹森林，定型化契約條款效力之規範—最高法院 90 年臺上 2011 號、91 年臺上 2220 號、92 年臺上 39 號判決之商榷，律師雜誌，第 239 期，頁 21-40，2004 年 2 月。
- 【58】 詹森林，消費者保護法發展專題回顧：定型化契約之理論與實務發展，國立臺灣大學法學論叢，第 43 卷特刊期，頁 1345-1389，2014 年 11 月。
- 【59】 詹森林，消費者保護法與預售屋買賣定型化契約，臺大法學論叢，第 27 卷第 4 期，頁 99-105，1998 年 7 月。
- 【60】 鄭惠佳，對我國不動產租金管制法律規定之建議，真理財經法學，第 2 期，頁 207-235，2009 年 3 月。
- 【61】 蕭文生，行政機關公告行為之法律性質，月旦法學教室，第 40 期，頁 22-23，2006 年 2 月。
- 【62】 謝宗憲，不實廣告法律責任之研究—以預售屋廣告為中心，公平交易季刊，第 23 卷第 1 期，頁 51-100，2015 年 1 月。
- 【63】 謝哲勝，出租人收回房屋之限制，月旦法學雜誌，第 6 期，頁 43-45，1995 年 10 月。
- 【64】 謝哲勝，契約自治與管制，月旦法學雜誌，第 125 期，頁 23-30，2005 年 10 月。
- 【65】 謝哲勝，請求返還押租金，月旦法學教室，第 22 期，頁 14-15，2004 年 8 月。
- 【66】 簡資修，讓與(買賣)不破租賃及其類推適用：長期投資保障觀點之分析，政大法學評論，第 78 期，頁 121-147，2004 年 4 月。
- 【67】 蘇永欽，關於租賃權物權效力的幾個問題—從民法第四二五條的修正談起，律師雜誌，第 241 期，頁 19-30，1999 年 10 月。

三、專書論文

- 【1】 花敬群、呂秉怡、郭曜達，租賃住宅市場需求行為與市場區隔，載：中華民國住宅學會第十二屆年會論文集，中華民國住宅學會，頁 189-216，2003 年 12 月。

四、博（碩）士論文

- 【1】 王啟旭，房屋租賃問題之理論與實用，國防管理學院法律學研究所碩士論文，1996 年 6 月。
- 【2】 馬翊峰，房屋租賃契約之交易成本分析，立德大學地區發展管理研究所論文，2008 年 6 月。
- 【3】 陳冠璋，憲法上居住權之建構與實現——以司法審查為核心，國立台灣大學法律學院法律學系碩士論文，2016 年 8 月。
- 【4】 陳佩妤，適足居住權於我國司法裁判之建構與落實，國立政治大學法律學系碩士班碩士論文，2017 年 2 月。

- 【5】 陳政君，論買賣不破租賃之修正與公證制度之引進，國立成功大學法律學研究所碩士論文，2003 年 7 月。
- 【6】 曾義權，尋找台灣住宅市場中潛藏的鍊節－專業租屋企業，國立臺灣大學建築與城鄉研究所碩士班論文，2002 年 6 月。
- 【7】 鄧文明，不動產租賃之默示更新，國立臺北大學不動產與城鄉環境學系碩士論文，2018 年 2 月。

德文文獻

一、專書

- 【1】 Schulze, Reiner/Dörner, Heinrich/Ebert, Ina/Hoeren, Thomas/Kemper, Rainer/Saenger, Ingo/Scheuch, Alexander/Schreiber, Klaus/Schulte-Nölke, Hans/Staudinger, Ansgar/Wiese, Volker: Handkommentar-BGB, 10. Aufl., 2019.
- 【2】 Blank, Hubert/Börstinghaus, Ulf: Miete, 5. Aufl., 2017.
- 【3】 Lindner-Figura, Jan/Oprée, Frank/Stellmann, Frank: Geschäftsraummiete, 4. Aufl., 2017.
- 【4】 Schmidt-Futterer, Wolfgang/Blank, Hubert: BGB, 13. Aufl., 2017.
- 【5】 Wetekamp, Axel: Mietsachen, 4. Aufl., 2007.

二、期刊論文

- 【1】 Börstinghaus, Ulf, Zusätzliche Mietsicherheit infolge Änderung des Mietvertrags im Mieterwunsch?, NZM. 2008, S. 558-563.